

Con referencia concreta al codificador argentino, el romanista Schipani señala que en su obra "el derecho romano constituye la primera guía: 'la ley romana dice' cita innumerable veces, por ejemplo el codificador argentino, D. Vélez, cuando fundamenta los artículos de su código, también respecto a las lecturas del derecho romano del momento, en ocasiones fruto del 'ideario del racionalismo iusnaturalista' o de los desarrollos pandectísticos"⁽³¹⁾. Finalizando el tema, el maestro italiano puntualiza que "estos códigos se preocupan por garantizar su permanente y propia relación con el derecho romano, de un modo renovado y más pleno respecto del precedente sistema de fuentes"⁽³²⁾.

A lo expuesto por los maestros romanistas citados sólo puedo añadir brevemente mi opinión al respecto, en cuanto a que el derecho romano ha sido recepcionado por la obra codificadora de Vélez Sarsfield, quien magníficamente lo reelabora, transfigurándolo en derecho vigente.

La transmutación del derecho romano en derecho vigente lo encontramos en el actual Código Civil y Comercial, que sigue la tradición romana, destacando su importancia e influencia en el derecho argentino, según dan cuenta sus propios "Fundamentos".

La línea de pensamiento que sostengo en cuanto a que el derecho originado en Roma arriba fundamentalmente al derecho argentino a través de la legislación española y francesa, ambas de incuestionable tradición romana, se advierte en la coherencia jurídica de los autores del nuevo Código Civil y Comercial, preservando, respetando y sosteniendo la importancia e influencia del derecho romano como fundamento del derecho argentino.

FRANJA
MORADA

PARTE SEGUNDA - DERECHO PRIVADO ROMANO

CAPÍTULO IX - FAMILIA Y PERSONA⁽¹⁾

I. LA FAMILIA ROMANA. FUNDAMENTO Y ORIGEN HISTÓRICO

El origen de la familia romana se remonta al mismo nacimiento de Roma como ciudad-estado (civitas), e incluso se supone anterior, en donde gens y familia son conceptos prácticamente similares. El instituto "familia" es probablemente una de aquellos que más ha evolucionado en el transcurso del devenir histórico, despojándose de su estructura primitiva, ampliándose con el paso del tiempo hasta convertirse en la acepción actual. Incluso actualmente se habla de la necesidad de revisar el concepto ante lo que se considera las "nuevas formas de familia", devenidas como efecto de la problemática de la "fecundación in vitro" y la contemplación legislativa de los "nuevos modos de matrimoniar". Si bien su estudio presenta un marcado interés histórico debido a la evolución referida, es importante conocer la estructura primitiva y su posterior adecuación para acercarnos mejor al conocimiento del espíritu romano, y esencialmente a otro aspecto de Roma, aquel que le permite sobrevivir a lo largo del tiempo, su pragmatismo. La familia evoluciona, se transforma, crece, se perfecciona a la par de la misma evolución social de Roma, pero se decanta lentamente hasta finalizar, cristianismo mediante, en la configuración de nuestra familia actual. Conocer en extenso la primitiva familia romana, su evolución, composición y los lazos de parentesco en ella imperantes, nos da el conocimiento cabal de su comportamiento social y una mirada introspectiva al romano como ser humano y a su mundo de relación privado e individual. Entonces, el concepto de la primitiva familia romana dista del actual, puesto que aquél se refiere a otro momento histórico, con otro sistema de agrupación social, y el derecho aplicable lo es en función de éste.

1. Las distintas acepciones del vocablo familia en Roma⁽²⁾

El vocablo familia sugiere en Roma distintas acepciones mediante la idea de "comunidad de vida, bienes e intereses dentro de una misma casa", aproximándose a la idea de "corporación". Familia significa, según pasajes de la jurisprudencia romana, "el patrimonio del jefe de la casa", y también, "los bienes que mediante la relación habida entre consanguíneos se consideran pertenecientes a la familia". Pero, por lo general, este vocablo se refiere al pater familias y a las personas que dependen de él, tanto aquellas que gozan del "estado de libertad" (status libertatis) como el hijo (filius), y los esclavos, o ambos a la vez.

El Digesto indica a través de Ulpiano diversas acepciones de la palabra familia, enseñando que en la ley de las XII Tablas se aplica dicho concepto "al patrimonio de un jefe de familia con la inclusión de los esclavos que le pertenecen"⁽³⁾. También se advierte que "la familia se refiere a la significación de cierto cuerpo, del cual se desprende el derecho propio de las personas que lo conforman. Por derecho propio llamamos familia a todas las personas que están bajo la potestad de uno, sujetas por naturaleza o por derecho, y los que suceden a éstos"⁽⁴⁾. El mismo Ulpiano más adelante completa la noción de familia, señalando que "por derecho común decimos que son de la familia todos los agnados, pues muerto el pater familias cada uno de sus hijos constituye familia propia. Pero con la particularidad de que todos los que estuvieron bajo la potestad del pater con

razón se consideran miembros de una misma familia, por proceder todos de una misma casa y familia"⁽⁵⁾.

Arribado a este punto, tras analizar las fuentes citadas, puedo efectuar una primera aproximación al concepto de la "familia primitiva romana" diciendo que se trata de "las personas que se encuentran bajo la autoridad de un jefe único, relacionadas entre sí por el parentesco "agnaticio". Y, como bien señala Ulpiano cuando emplea la palabra "cuerpo", la familia primitiva romana es "corporativa", todos sus miembros forman parte de ella, sujetos a la voluntad del "jefe de familia". En este sentido, la familia llamada de "propio derecho" (propio iuri) es el sometimiento de todos los miembros a la autoridad (manus, potestas) de un jefe llamado pater familias. Es el grupo de personas unidas entre sí pura y simplemente por la autoridad que una de ellas ejerce sobre las demás para fines que trascienden el orden doméstico"⁽⁶⁾.

Los miembros sujetos a la familia y a la autoridad del pater reciben el nombre de alieni iuris, es decir que están bajo la potestad de otro, v.gr., los hijos. Éstos, aun muerto el pater familias, conservan entre sí el vínculo "agnaticio" por ser todos lo que estaban sometidos a su autoridad (potestas). De tal modo, los "agnados" constituyen la "familia de derecho común propiamente dicha" (comuni iuri dicta), definida por Ulpiano como "el conjunto de todos aquellos individuos que estarían sometidos a la misma autoridad del pater familias si no hubiese muerto"⁽⁷⁾. Es decir que la familia "agnaticia" es el grupo de personas sujetas al poder doméstico del pater familias.

A la luz de lo expuesto puedo afirmar que en Roma la idea de familia se encuentra relacionada con su propio devenir histórico. Si bien en un principio nace juntamente con la ciudad (civitas), luego varía con el paso del tiempo hasta asemejarse a la familia actual. La familia romana primitiva en sus comienzos constituye una especie de organismo político para fines de orden y defensa social. Para ello se vale de una figura dominante, poderosa, la de un "jefe" (pater familias) con plenos poderes (potestas), que aglutina bajo su autoridad a todas las personas y bienes que tienen un interés con él.

Entonces puedo decir que la primitiva familia romana (agnaticia) es el conjunto de personas y bienes sometidos a la voluntad, o poder, de un "jefe" llamado pater familias, brindando la idea "de cuerpo" al cual pertenecen todos sus miembros y del cual éste es la parte visible, conductiva, y autoridad.

FRANJA
MORADA

2. Las relaciones derivadas de la familia romana primitiva⁽⁸⁾

Para emprender mejor el estudio de esta institución primitiva debe considerársela desde tres aspectos diversos: parentesco, integración y formas de ingreso y egreso a la misma.

3. El parentesco

Se define como aquel vínculo por el cual un conjunto de personas se consideran integrantes de una misma familia. Al hablar de parentesco en Roma se deben tener en cuenta que existen distintas clases, de acuerdo con el momento histórico y su evolución. Ellos son los vínculos "agnaticio" y "cognaticio". A posteriori, se analizará el parentesco por "afinidad" y el de "gentilidad".

3.1. La familia agnaticia

El vínculo de parentesco por el cual se estructura "la familia romana primitiva" es exclusivamente la "agnación". Ésta se transmite sólo por "vía masculina", subsistiendo únicamente entre aquellos que descienden de un antepasado común a través de "individuo varón" de la familia. Es un "vínculo

civil" que une a la familia y que subsiste aun después de la muerte del pater familias. Por eso es pasado, actual y potencial. Su rasgo dominante es el régimen patriarcal a través del ejercicio "de la soberanía del padre o abuelo paterno"⁽⁹⁾. El vínculo "agnaticio" comprende a los parientes por vía masculina que han estado anteriormente bajo la misma potestad de un "jefe de familias", y que continuarían estándolo de estar todavía éste vivo. De allí las cualidades indicadas de "pasado", "actualidad" y "potencialidad".

Advierto dos tipos de "familia agnaticia". Por un lado, la que se encuentra directamente aglutinada alrededor del pater familias, llamada "familia de propio derecho" (propio iure); y por el otro, la denominada "familia de derecho común" (comuni iure), que surge fragmentada ante la muerte del pater familias, ya que, al desaparecer éste, "cada uno de los hijos varones que se encuentran bajo su patria potestad se convierte en cabeza de su propia familia"⁽¹⁰⁾.

El "vínculo agnaticio" se computa por "grados" (gradus), configurando "cada generación un grado", encontrándose en la cima el antepasado común. Éste puede ser en línea "recta" (hijo, padre, abuelo, etc.), o "colateral" (hermanos, primos, etc.). En el parentesco en "línea recta" tenemos el "primer grado", padre a hijo; y el "segundo", abuelo a nieto, y así sucesivamente. En el parentesco en "línea colateral", cada grado se obtiene ascendiendo de "generación en generación", partiendo de un "agnado" hasta el primer "antepasado común" y descendiendo después hasta el otro agnado, v.gr., hermanos (segundo grado), tío y sobrino (tercer grado), primos (cuarto grado), etc. También por fuera de los grados y líneas de parentesco indicados tenemos la "estirpe", que está compuesta por todos los descendientes de un antepasado común que llevan, o bien "el mismo nombre de la gens a la cual pertenecen" (nomen gentilium) o "el mismo apellido familiar que indica la rama particular de la gens a la cual pertenece" (cognomen).

FRANJA

3.2. La familia cognaticia

Si bien el rasgo característico de la primitiva familia romana es el "parentesco civil" (agnaticio), también se conoce en Roma el "vínculo de sangre" (cognaticio), que subsiste junto a aquél. En un principio carece de relevancia jurídica, puesto que los juristas romanos, basándose en el "derecho civil" (ius civile), consideran sólo el "agnaticio", pero después, gracias a la actividad incesante del pretor, con el transcurso del tiempo cae en desuso, y el "cognaticio" lo reemplaza por completo, solucionando de tal modo verdaderas situaciones injustas al equiparar "la familia de sangre con la civil sin distinción de sexo". Actualmente, "el vínculo cognaticio" es el que aglutina a la familia moderna. Es, por lo tanto, un parentesco que resulta de la misma naturaleza. En nuestro derecho este parentesco es suficiente para constituir la familia, pero en el derecho romano primitivo es diferente, lo primordial es el "vínculo agnaticio", el único que jurídicamente cuenta. En la familia "agnaticia", quien sólo posee la calidad de "cognato" no forma necesariamente parte de ella, ya que para ello debe poseer también el carácter de "agnado". El "derecho civil" (ius civile) concede importantes prerrogativas a los "agnados" que componen la familia, tanto en materia de tutela y curatela, como en las cuestiones testamentarias o de herencia.

La reacción contra esta organización primitiva de la familia es muy lenta. El primero que comienza a tomar algunas decisiones favorables hacia los "cognados", como dijera, es el pretor, concediéndoles en diversas oportunidades los "derechos de sucesión" que el derecho civil reserva sólo a los "agnados". Luego los "senadoconsultos" y las "constituciones imperiales" continúan el camino iniciado por el pretor, pero es recién con Justiniano, después de las novelas 118 y 121, cuando desaparecen definitivamente los privilegios de la "agnación" sobre la "cognación", siendo esta última suficiente en lo sucesivo para transmitir los "derechos de familia"⁽¹¹⁾.

3.2.1. Los grados de parentesco derivados de la familia cognaticia

Dentro del vínculo de sangre (cognaticio) existen los parentescos denominados "natural" y por "afinidad".

En el "natural" se distinguen el parentesco en "línea directa" y el parentesco en "línea colateral". El parentesco en "línea directa" es aquel que une a dos personas de las cuales una desciende de la otra. También éste, a su vez, puede ser "ascendente" o "descendente". El parentesco en "línea colateral" une a dos personas que descienden de un mismo antepasado común sin que la una descienda directamente de la otra.

El parentesco por "afinidad" es originado por el matrimonio, constituido, o bien por los esposos entre sí, o entre cada cónyuge y los parientes del otro, o entre los parientes de uno de los cónyuges con los parientes del otro.

Al igual que la familia "agnaticia", la proximidad del parentesco "cognaticio" se mide por el "número" de grados. Éstos se determinan de acuerdo con el principio de que cada generación representa un grado⁽¹²⁾.

En la "línea directa", cuando se quiere saber en qué grado son parientes dos personas, se cuenta el número de generaciones que es necesario en forma ascendente o descendente, según el caso. Así tenemos, siguiendo a Gayo, en la "línea directa ascendente", a los padres en primer grado, a los abuelos en segundo grado y a los bisabuelos en tercer grado, y así sucesivamente. Por su parte, en la "línea directa descendente", tenemos a los hijos en el primer grado, a los nietos en el segundo grado, a los bisnietos en tercer grado, etc.⁽¹³⁾. Para contar la "línea colateral" es menester remontarse al "tronco común", y de allí descender hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en el segundo grado (el tronco común es el padre); tío y sobrino en el tercer grado (el tronco común es el abuelo); los primos hermanos en el cuarto grado (el tronco común es el abuelo), etc. En igual sentido se cuenta en nuestro derecho.

3.3. La gentilidad

Es otro tipo de parentesco que tiene su apogeo en los comienzos de Roma, con aplicación al patriciado. Abarca "a todos los descendientes de un antepasado común", que no es otra cosa que un verdadero "organismo jurídico-político". La gentilidad es un lazo de parentesco que une a los miembros que pertenecen a la misma gens. De este vínculo familiar tan antiguo tenemos vestigios en la "ley de las XII Tablas", en donde se fundamenta el sistema sucesorio en el parentesco civil (agnaticio). La mencionada ley ordena "que si muere sin dejar testamento un pater familias, deberá llamarse a heredar primero a los herederos directos o forzosos, y a falta de éstos, al agnado más próximo, y si no hubiese agnados, al gentil"⁽¹⁴⁾.

Es decir, en otras palabras, que la "ley de las XII Tablas" considera jurídicamente al vínculo "gentilicio", ya que se lo tiene expresamente en cuenta en el orden sucesorio. Posteriormente, como se dijera, el parentesco producto de la "gentilidad" cae en desuso, al igual que el vínculo "agnaticio", perdurando tan sólo el "cognaticio".

II. EL PADRE DE FAMILIAS (PATER FAMILIAE)⁽¹⁵⁾

Es la figura aglutinante y fundamental de la familia "agnaticia". A su alrededor gira toda la familia, puesto que "es el dueño de las personas y los bienes" que la componen. El pater familias no tiene otro ascendiente vivo sobre sí por vía masculina; puede ser entonces, según el caso, padre, abuelo o bisabuelo, de los miembros nacidos en dicha familia.

Ser padre de familias no implica forzosamente connotaciones de ascendencia o descendencia biológica—porque puede no tenerlas— sino que refiere a una situación de "independencia económica y jurídica", al decir del maestro Yan Thomas, una cuestión propia de "soberanía"⁽¹⁶⁾. Es quien presenta "ausencia de subordinación", el que no tiene otro ascendiente vivo por línea masculina sobre sí, aquel que no se encuentra sometido a la "potestad" de nadie.

De lo expuesto puede decirse que en Roma se llama patria potestas al conjunto de poderes emanados del pater familias y que éste ejerce sobre las personas libres que constituyen su grupo

familiar, a saber, hijos legítimos de uno u otro sexo, descendientes legítimos de los varones, los extraños que ingresan a la familia por adopción y adrogación, y los hijos naturales legitimados.

Este "poder" (potestas) en que se fundamenta la "familia primitiva romana" es siempre el mismo plexo de facultades que emana de una sola persona, el "padre de familias", que conlleva distintas denominaciones según recae en la mujer (manus), o en el resto de las demás integrantes (patria potestas).

El "jefe de familias" posee la categoría jurídica de sui iuris, que significa "suyo propio", y sus hijos, que se encuentran bajo su "potestad", son considerados justamente por esta razón aliena iuris⁽⁴⁷⁾.

El vínculo familiar no es meramente biológico, sino que se crea por "el principio de autoridad", o de poder emanado del pater. La familia se constituye por el solo hecho de encontrarse "sometida al poder del pater", sin importar que sus miembros sean o no sus descendientes por vínculo de sangre. La "autoridad" que el pater ejerce sobre los integrantes de su familia es absoluta, y, como dije, no se diferencia en intensidad según la persona sobre quien recae, limitándose tan solo a variar su denominación, según cada caso. Así, tenemos patria potestas para los aliena iuris; manus maritales para la mujer sujeta por la conventio in manu y dominica potestas para los esclavos.

Entonces, el "poder" del "padre de familias" es absoluto, vasto, ilimitado; y como consecuencia de ello, tiene sobre el "hijo de familia" (filius familias) el "derecho de vida y muerte" (ius vitae et necis), puede venderlo como esclavo (ius vendendi) y castigarlo entregándolo a la víctima de un delito como reparación (ius noxae dandi).

Empero, lo cierto es que este régimen tan severo no es llevado a la práctica con asiduidad, sino sólo en casos excepcionales, puesto que no hay que olvidar el grado de afecto, aproximación y convivencia del pater con los filii, a semejanza de la familia moderna. Relacionado con esto, en forma lenta pero constante, primero los pretores, y luego los emperadores, se preocuparon por atenuar y cambiar este sistema. Así tenemos la decisión de Trajano, obligando a un pater a emancipar un filius al que maltrata; otra de Adriano ordenando la deportación de un "pater" que ordena la muerte de su hijo sin tener en cuenta la opinión de la asamblea familiar, compuesta por los miembros más antiguos; y la derogación del ius noxae dandi en época de Justiniano.

III. LA CIUDADANÍA ROMANA⁽¹⁸⁾

El ciudadano romano lo es "por pertenecer" a la civitas, o sea a "la ciudad de Roma". El concepto de ciudadanía difiere del moderno, en virtud de que en la actualidad se habla de ciudadano con "referencia a un Estado", el cual necesariamente tiene que tener una capital. En el mundo antiguo, y concretamente en el romano, no existe el Estado en el sentido moderno, sino "la ciudad de Roma" (la civitas Romana), que constituye por sí sola el Estado, y todo aquel que "perteneciera a ella" adquiere el "reconocimiento de ciudadano". Los individuos de otras comunidades ajenas a Roma, por más que ésta las haya anexado a raíz de las conquistas territoriales, no son considerados ciudadanos. Sólo con el transcurso del tiempo, a medida que Roma les concede a estos territorios por circunstancias especiales la extensión de la ciudadanía, son considerados como "pertenecientes a la civitas", y por ende "ciudadanos romanos", hasta que finalmente esta evolución eclosiona durante el gobierno del emperador Caracalla, que concede la ciudadanía a todos los habitantes del imperio en el año 212. De este modo Roma deja de ser "la ciudad-estado" para erigirse en "capital de un imperio"⁽¹⁹⁾. Es menester señalar, en cuanto a este último aspecto, que la medida política de Caracalla debe considerarse como una de las "medidas de globalización" más antiguas que se conoce.

La ciudadanía romana basa sus principios en el "derecho de sangre" (ius sanguinis), es decir que el hijo de un ciudadano romano también es ciudadano romano, independientemente del lugar de su nacimiento, gozando de los derechos de su lugar de origen, puesto que la ley que lo rige sigue a la persona, cualquiera fuera el lugar en que se encuentre. De lo explicitado se infiere claramente el fundamento del plexo de facultades que posee el ciudadano romano por pertenecer a la ciudad de Roma, que le brinda exclusividad y privilegios (status civitatis). Todos aquellos individuos que no poseen el status civitatis son considerados extranjeros (peregrini). Además, entre ambos extremos existe un grupo intermedio, los latinos (latini).

1. Los modos de adquisición de la ciudadanía⁽²⁰⁾

La ciudadanía romana se adquiere por las siguientes causas, a saber: a) nacimiento; b) manumisión; c) ley; d) concesión del poder público.

a) Nacimiento. Adquiere la ciudadanía romana el nacido de ambos padres que gozan de la ciudadanía. Si bien en estos casos no existen problemas de interpretación, es menester formular algunas apreciaciones para el caso en que alguno de los progenitores no sea ciudadano, y aun en esta circunstancia debe considerarse si la unión se lleva a cabo mediante "justas nupcias" (*iustae nuptiae*). La diferencia se debe a que, en principio, sólo posee la facultad de contraer "justas nupcias" el ciudadano romano (*ius connubium*), y luego se extiende a otras comunidades, v.gr., los latinos veteres. En el caso de que alguno, o ambos, progenitores no sean ciudadanos romanos, pero posean el derecho a contraer "justas nupcias", el hijo adquiere la condición que el padre tiene al momento de la concepción. En cambio, cuando los padres no gozan de esta facultad, el hijo habido por los mismos sigue la condición de la madre al momento del nacimiento.

b) Manumisión. Es la adquisición de la ciudadanía mediante la "concesión de la libertad al esclavo". Al respecto, en un principio, son considerados ciudadanos romanos sólo aquellos esclavos liberados por alguna de las formas solemnes (requerimiento, testamento o censo). Luego, durante el derecho bizantino, se extiende la ciudadanía a todos los "liberados" (manumitidos) sin distinción alguna⁽²¹⁾.

c) Ley. Es la adquisición de la ciudadanía por imperio de la ley. Así, la que otorga la ciudadanía al peregrino que acuse, o hiciera condenar, a un magistrado romano por el delito de concusión (*lex Acilia repetundarum*) u otras que benefician a los latinos que cumplan destacados servicios militares o sociales, que desempeñen magistraturas locales, cargos curiales, etc.⁽²²⁾.

d) Concesión del poder público. Por medio del poder público le corresponde a los comicios en la época republicana otorgar la ciudadanía como premio a actuaciones destacadas. También hacen lo propio los generales victoriosos y los encargados de fundar colonias. Después, es potestad exclusiva de los emperadores, hasta la decisión tomada por Caracalla, cuando extiende la ciudadanía a todos los habitantes del imperio⁽²³⁾.

2. Los derechos del ciudadano romano⁽²⁴⁾

Únicamente los ciudadanos romanos son quienes pueden gozar de todos los derechos, tanto los de carácter "público" como "privado".

2.1. Los derechos de carácter público

El ciudadano romano goza de los siguientes derechos: a) Desempeñar la "carrera de las magistraturas" (*ius honorum*). b) Votar las leyes y elegir los magistrados (*ius suffragii*). c) Apelar la pena capital que le ha sido impuesta delante de los comicios durante la República, o más tarde delante del Emperador (*ius provocationis ad populum*). d) Acceder a la justicia como litigante (*ius actionis*). e) Uso del nombre (*tria nomina*). El nombre consta de las siguientes partes, a saber, "nombre propio" (*praenomen*); "apellido familiar", que indica la rama particular de la gens a la que pertenece (*cognomen*); nombre de la gens a la que pertenece (*nomen gentilium*). Todo lo cual importa, en conjunto, un verdadero árbol genealógico que demuestra el verdadero linaje del individuo.

2.2. Los derechos de carácter privado

El ciudadano romano goza de los siguientes derechos: a) Contraer "justas nupcias" (ius connubium) y formar, por ende, una familia legítima con todo el poder que sobre sus integrantes ejerce el pater. b) Ejercer el comercio, que implica adquirir y enajenar de acuerdo al ius civile, gozar de los derechos patrimoniales y llevar a cabo todos los actos relacionados con ellos (ius commercium). c) Otorgar testamento y ser instituido heredero (ius testamenti factio).

3. Los no ciudadanos. Latinos. Peregrinos. Bárbaros⁽²⁵⁾

Los habitantes de los territorios dominados por el mundo romano que no gozan de la ciudadanía son considerados "no ciudadanos" y se encuentran comprendidos en distintas categorías, con goce de derechos inferiores. Es el caso de latinos, peregrinos y bárbaros. Con esto se infiere de modo sutil que el derecho romano reconoce de algún modo la existencia de "diversas clases de ciudadanos", que bien pueden individualizar como de "primera clase" (ciudadanos romanos); "segunda clase" ("latinosveteres"); "tercera clase" ("latinos colonarii y junianos"); "cuarta clase" (peregrinos); etc.

a) Latinos. Se dividen en veteres, colonarii y "junianos". Los "latinos veteres" son los habitantes de la región conocida como Antiguo Lacio⁽²⁶⁾. Gozan del ius commercium y del ius connubium, y sólo del ius suffragi si habitan o se encuentran en Roma al momento de la votación. Estos latinos son los que tienen las mejores posibilidades de adquirir la ciudadanía, a la cual acceden por diversas causas, v.gr., por tener hijos, construir naves, transportar trigo, ejercer el oficio de panadero o molinero en la ciudad de Roma, construir casas de envergadura en Roma, por propia decisión del príncipe, etc. Los "latinos veteres" desaparecen como tales cuando se concede la ciudadanía romana a todos los habitantes de Italia (lex Plautia Papiria, del 89 a.C., y Julia, del 90 a.C.).

Los "latinos colonarii" son los habitantes de las colonias romanas fundadas en los territorios conquistados. A estos habitantes se les concede a modo de extensión la "latinidad", siendo equiparados a los nacidos en el Lacio⁽²⁷⁾.

Los "latinos junianos" son aquellos esclavos manumitidos por alguno de los modos no solemnes (inter amicos, per epistolam, per mensam), asimilados luego también a los latinos (lex Iunia Norbana)⁽²⁸⁾.

Los "latinos colonarii y junianos" gozan solamente del ius commercium, aunque también gozan del ius connubium cuando expresamente se les concede. También se les otorga facilidades para adquirir la ciudadanía.

Finalmente, en el año 212, cuando el emperador Antonino Caracalla otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, estas categorías desaparecen (Constitución Antonina)⁽²⁹⁾.

b) Peregrinos. Son todos los demás extranjeros que habitan dentro del dominio romano, y que pertenecen a ciudades que no se encuentran en guerra con Roma. No se ajustan al ius civile sino al ius gentium, y a las leyes dictadas específicamente para ellos. No gozan del ius commercium, ni tampoco del ius connubium, salvo que expresamente les fueran concedidos. Amparados por las normas del ius gentium, pueden casarse, tener su familia, ejercer la patria potestad, testar, adquirir la propiedad, litigar, etc.

Distinto es el caso de los "peregrinos dedicticios", que son los integrantes de aquellas ciudades o pueblos sometidos a Roma que se sublevan a su autoridad y son vencidos nuevamente. Luego se agregan a esta categoría aquellos que por aplicación de una pena pierden la ciudadanía y los manumitidos, conforme a la aplicación de la lex Aelia Sentia, pero que mantienen una pésima conducta durante el cautiverio. No gozan de ningún tipo de derechos.

La distinción fundamental entre los "peregrinos simples" y los "peregrinos dedicticios" es que mientras a los primeros se les permite el goce del ius gentium y que en condiciones especiales pueden acceder a la ciudadanía, los segundos tienen una condición inferior aún, sujetos a la autoridad de los magistrados romanos que ejercen el gobierno en la provincia en la cual están asentados y nunca pueden acceder a la ciudadanía⁽³⁰⁾.

c) Bárbaros" (hostes). Son los habitantes o miembros de las ciudades o pueblos contra quienes Roma se encuentra en guerra y están situados fuera de los límites de Roma. Se los considera sin patria y sin posibilidad de invocar derecho alguno. Son asimilados, de algún modo, a los "peregrinos dedicticios"⁽³¹⁾.

**FRANJA
MORADA**

Capítulo X - El Sujeto de Derecho

CAPÍTULO X - EL SUJETO DE DERECHO⁽¹⁾

Como lo sostengo desde hace tiempo, considero menester tratar el "sujeto de derecho en Roma" relacionado directamente con el "padre de familia", debido a la particular configuración de la familia romana primitiva, puesto que prácticamente ambas cualidades recaen en el mismo individuo⁽²⁾. Efectuada la aclaración previa, puedo decir que el derecho romano conoce la distinción entre "persona de existencia visible" (corpórea o física) y "persona de existencia ideal" (jurídica o moral). La primera es conocida desde muy antiguo, y luego, ante la evolución del pensamiento jurídico, surge la segunda. Los juristas romanos tienen la idea en sentido moderno de que el "sujeto de derecho" es titular de derechos y obligaciones y trabajan acertadamente el tema.

I. LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE O PERSONA FÍSICA

Etimológicamente persona significa "máscara", "carácter", "personaje de teatro", etc.; empleándose como un derivativo para indicar el rol que un individuo lleva a cabo en la sociedad como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero además en Roma, para que una persona se considere "sujeto de derecho", tiene que gozar de una situación jurídica especial. Esta última resulta cuando posee los llamados "tres estados" (status), a saber: familia (status familiae), libertad (status libertatis) y ciudadanía (status civitatis).

Con esto quiero señalar el carácter restrictivo reservado para el sujeto de derecho, por cuanto no basta con ser simplemente persona para ser considerado "sujeto de derecho", sino que además tiene que gozar de los indicados estados. Los juristas romanos saben desde antiguo que todos los hombres (homo) son personas, incluso los esclavos, pero únicamente consideran "sujeto de derecho" a quienes unen a su condición de persona la situación jurídica emanada de poseer los estados de familia, libertad y ciudadanía⁽³⁾.

De este concepto se desprende claramente que el esclavo es persona simplemente en la faz física (homo), pero se lo considera jurídicamente "una cosa". Los romanos emplean el término persona como sinónimo de "ser humano" (homo). Por tal motivo Gayo, al tratar el tema, enseña que la división del "derecho de personas" (iura personarum) es dada entre todos los hombres que pueden ser libres o esclavos⁽⁴⁾.

1. El comienzo de la existencia de la persona física⁽⁵⁾

El momento en que la persona física es considerada jurídicamente como tal ha dado motivo a la doctrina romanista para hablar sobre el tema. Lo concreto es determinar en qué momento los juristas romanos consideran el comienzo de su existencia. Producto de la investigación que vengo efectuando desde hace tiempo, puedo señalar que en principio sólo el nacimiento marca el inicio de la existencia. Luego el concepto varía, abriendo camino la idea de "que existe persona a partir del momento de la concepción en el seno materno". Esto último es gravitante en cuestiones tales como determinar la libertad, considerar el inicio de la personalidad, etc.

Los juristas romanos, fieles a su estilo práctico, realista, consideran en un principio que la existencia de la persona está dada por el hecho biológico incontestable y fácilmente comprobable del nacimiento. El "nacer" implica el comienzo a la vida de modo empírico y jurídico. Con el paso del tiempo, y tras la evolución firme y constante de la jurisprudencia romana, esencialmente la clásica, lentamente comienza a variar dicho concepto mediante lo que inicialmente se consideran excepciones que confirman la regla esencial. De tal modo se continúa estimando el comienzo de la persona a partir del nacimiento, pero con el fin de paliar situaciones jurídicas que, de mantenerse, convalidan verdaderas inequidades (v.gr., hijo póstumo, cuestiones de alimentos, etc.). Los juristas lentamente comienzan a señalar con notable acierto que la vida se inicia a partir de la concepción, y se prolonga al momento del nacimiento, siendo este último una ratificación en

definitiva del proceso de gestación de vida iniciado en el seno materno. O sea que mediante la contemplación de excepciones destinadas a solucionar situaciones que merecen ser acogidas, puesto que de lo contrario se tornan injustas, se comienza a admitir el inicio de la existencia de la persona a partir del momento de la concepción en el seno materno. Es decir que la jurisprudencia romana clásica, fiel a su estilo, no elabora al respecto una "teoría general de las personas", sino que a través de la solución de "casos concretos" considera de manera cada vez más precisa y concordante que la persona tiene inicio como tal a partir del momento de la concepción y no con el nacimiento. Este último, de producirse con vida, no es otra cosa que la ratificación de la personalidad de quien se ha gestado en el vientre materno.

Esto me permite aseverar que ambas posturas tienen acogida en el derecho romano en razón de su carácter casuista, hasta que la más justa desplaza a la primera, amalgamando ambos conceptos en uno solo. Lo que significa que se conocen en Roma ambos presupuestos de inicio de la existencia de la persona, en primer lugar con el nacimiento y luego extendiéndolo al momento de la concepción. Esta última tendencia se mantiene sin abandonar la posición primitiva, dado que siguen considerando el nacimiento, de producirse con vida, como ratificación de la persona iniciada en la concepción.

Advierto claramente que la solución adoptada es una enseñanza positiva de la riqueza de los juristas romanos, que evolucionan permanentemente, legándonos instituciones acabadamente elaboradas que, por su justeza, han pasado intactas a nuestro derecho, como es el caso de la persona por nacer. La cuestión debe analizarse para su mejor comprensión y estudio desde la óptica tradicional y moderna⁽⁶⁾.

2. La teoría tradicional sobre el comienzo de la persona física

Quienes sostienen la presente teoría consideran que en Roma se es persona a partir del nacimiento, sin perjuicio de admitir que "el que ésta por nacer" (*nasciturus*) debe ser protegido jurídicamente, lo que da en llamarse excepciones que confirman el principio general. Se basan para fundarla en algunos pasajes limitados del Digesto que concretamente no se refieren en verdad al *nasciturus* como persona, ni tampoco sobre los derechos que le corresponden, sino, por el contrario, a situaciones tan dispares como "el fruto del vientre de una esclava"; "legados que tienen como objeto los frutos de un fundo y de una esclava"; y la consideración de que "el feto es parte de las entrañas de la mujer"⁽⁷⁾.

De una lectura atenta de las fuentes indicadas se advierte que ninguna se refiere "a la persona por nacer y sus derechos". Por el contrario, en un caso se habla del "fruto del vientre de una esclava"; y está claro que la distinción entre ésta y una mujer libre es absoluta. Por tal motivo, al considerar a una esclava jurídicamente como "una cosa", el concebido por ésta⁽⁸⁾ lo es de modo similar. De aquí la comparación y asimilación con los otros casos que lo consideran "objeto de legados". Por otra parte, el pasaje del Digesto que habla de la "persona por nacer como parte integrante de las entrañas de la mujer", debe ser interpretado como aquello que está en el vientre de la madre formando parte de su intimidad, integridad y pudor. La cita se refiere puntualmente a un caso de "inspección de vientre" y "custodia del parto" motivada por un requerimiento del padre a causa de un divorcio, y no relacionado con la persona por nacer en sí. De aquí infiero que ésta es una interpretación forzada de las fuentes que no se compadece con la tendencia del estudio moderno del derecho romano que tiene en mira "la defensa del más débil", o del "marginado del sistema jurídico". Por estos motivos he denominado a esta postura "tradicional".

II. LA TEORÍA MODERNA SOBRE EL COMIENZO DE LA PERSONA FÍSICA. EL NASCITURUS

A la luz de la evolución que efectúa el derecho en Roma comienza a surgir la tendencia cada vez más constante de excepcionar el principio general anteriormente expuesto, en tal medida que puedo

señalar que esta postura necesariamente debe tenerse en cuenta como una nueva teoría al respecto. Los fundamentos de lo expuesto son los siguientes.

En principio, aparece la figura del "póstumo" y la preocupación de los juristas romanos en nombrarle tutor para después del nacimiento, lo cual implica el reconocimiento de su condición de persona⁽⁹⁾.

También se encuentran pasajes que aluden al nasciturus concretamente como persona, teniéndoselo en cuenta como si hubiera ya nacido⁽¹⁰⁾, y coherentemente con esto, los juristas romanos lo consideran persona desde el momento de la concepción, preservando su vida al diferir la aplicación de la pena capital impuesta a la madre hasta el momento en que hubiera nacido⁽¹¹⁾.

Otras fuentes aluden al momento de la concepción como determinante del "estado familiar", desplazando así al nacimiento⁽¹²⁾.

Asimismo, en cuanto a la posesión, se toman importantes decisiones a favor de "la persona por nacer", facultándola a través de sus curadores, o de la madre, a ejercerla⁽¹³⁾.

En materia de alimentos, se dictan resoluciones destinadas a su percepción por propio derecho del nasciturus, con absoluta independencia del derecho que tuviera la madre en este aspecto⁽¹⁴⁾.

Con respecto a instituir curadores, también se tiene en cuenta a "la persona por nacer" para protegerla y administrar sus bienes, considerándola "incapaz de hecho"⁽¹⁵⁾. Incluso se avanza notoriamente respecto de la personalidad del nasciturus, dado que se decide que el curador debe pagar las deudas contraídas en ocasión de la curatela, lo cual significa que se extiende la responsabilidad ante las deudas de la persona por nacer por intermedio de su curador. Es decir, se convalida "el deber de cumplir con las obligaciones contraídas en ocasión de la curatela una vez nazca el nasciturus"⁽¹⁶⁾.

Finalmente, y para demostrar fehacientemente lo expuesto ut supra, sujetan a "la persona por nacer" a que nazca con vida (condición resolutoria), contrariamente a la teoría tradicional que, al considerar que la personalidad comienza a partir del nacimiento, la sujeta a "condición suspensiva"⁽¹⁷⁾.

FRANJA
MORADA

III. REFLEXIÓN RESPECTO DE LA PERSONALIDAD DEL NASCITURUS EN EL DERECHO ROMANO. SU POSICIÓN EN LA DOCTRINA ACTUAL⁽¹⁸⁾

La problemática del nasciturus es una de las tantas cuestiones que me permite aseverar que el derecho romano se encuentra vivo y en permanente estado de ebullición. Una cuestión aparentemente finiquitada origina nuevas investigaciones⁽¹⁹⁾, que determinan precisamente lo contrario a lo que se viene sosteniendo y repitiendo, metódica y sistemáticamente, desde fines del siglo XIX. Esto me permite afirmar que las investigaciones sobre las instituciones romanas de manera permanente traen luz y nuevos cambios que benefician, sin lugar a dudas, la mejor comprensión de las instituciones de derecho privado.

A modo de reflexión diré que la cuestión de la "persona por nacer" es considerada desde antiguo en Roma, pero con el paso del tiempo, ante el crecimiento de la urbe y el incremento de las complejidades sociales, la consideración sobre el tema ha ido variando. En un primer momento, los juristas romanos deciden que la personalidad comienza con el nacimiento; luego, ante la necesidad de tener en cuenta otras cuestiones atinentes al nasciturus, v.gr., herencia, alimentos, responsabilidad, etc., deben modificar el principio general a fin de evitar injusticias mediante excepciones. Posteriormente, gracias a la actividad fundamental, primero de los pretores y luego esencialmente de los juristas clásicos, se comienza a prever un cambio de postura respecto de la condición jurídica del nasciturus, puesto que las excepciones comienzan lentamente a trastocarse en principio general, dando lugar a la teoría moderna contemplada en numerosas legislaciones que sostiene "que la personalidad comienza desde el momento de la concepción en el seno materno con la condición de que el nacimiento se produzca con vida".

Esta opinión, que en nuestro país tiene origen en el trabajo que oportunamente he iniciado hace dos décadas aproximadamente⁽²⁰⁾, luego ha sido objeto particular de profundización en la investigación que he desarrollado respecto del tema, enriqueciéndolo, madurándolo, exponiéndolo, hasta conformar la postura que sustento y cuyos fundamentos he desarrollado a lo largo del presente⁽²¹⁾.

1. La cuestión del nasciturus en el Código Civil argentino

Como es sabido, Vélez Sarsfield, siguiendo al ilustre jurista brasileño Teixeira de Freitas, establece que el comienzo de la existencia de la persona se produce para la legislación argentina desde la concepción en el seno materno. Se ha señalado al respecto que el codificador argentino es un verdadero adelantado para su época, puesto que decide extender el comienzo de la existencia de la persona al momento de su concepción, adoptando una realidad incontestable. Sin embargo, se ha demostrado⁽²²⁾ que Vélez no incursiona en ningún sistema de avanzada, sino que aplica directamente las conclusiones que la jurisprudencia romana clásica alcanza un par de milenios antes, trasladándolas a nuestro derecho⁽²³⁾.

Vélez Sarsfield es considerado uno de los mayores romanistas latinoamericanos del siglo XIX junto a Andrés Bello y Teixeira de Freitas en Brasil⁽²⁴⁾. La persona por nacer en el Código Civil argentino se encuentra legislada en los artículos 63 a 78; y justamente, en la nota del artículo 63 (oportunamente me he referido ampliamente al valor que tienen las notas del Código de Vélez) señala el codificador que "las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Si fuesen personas futuras, no habría sujeto que representar [...]; pero si los que aún no han nacido no son personas, ¿por qué las leyes penales castigan el aborto premeditado? ¿Por qué no se puede ejecutar una pena en una mujer embarazada? En el derecho romano había acciones sobre este punto...". En la nota citada se encuentran sabias referencias al derecho romano, citas de códigos de marcada influencia romanista, v.gr., Luisiana (art. 29), Prusia (T. 1, art. 10, parte 1a.), y Chile (art. 74). Es menester destacar la decisiva influencia que ha tenido en nuestro codificador la postura asumida por el jurisconsulto brasileño Augusto Teixeira de Freitas, ya que, por coincidir plenamente con ella, la sigue acertadamente.

Finalmente, quiero señalar que la solución adoptada por Vélez es absolutamente producto del derecho romano, quedando claramente demostrada la vigencia e influencia de este último, no de modo histórico, sino "trasmutado" en derecho actual⁽²⁵⁾.

El actual Código Civil y Comercial mantiene la línea expuesta hablando de "persona humana" en reemplazo de "persona de existencia visible", estableciendo puntualmente que la existencia comienza con la concepción en la mujer (arts. 19, 21 y 24 CCyCN), manteniendo la vigencia de la teoría romana moderna del nasciturus en cuanto considera humano al concebido en el seno materno, presumiendo su nacimiento con vida y la irrevocabilidad de la adquisición de sus derechos en este caso (art. 21 CCyCN).

2. El nacimiento. Condiciones

Si bien, como lo expresara anteriormente, la jurisprudencia romana considera que "se es persona desde el momento de la concepción", también establece que ella se encuentra sujeta a la condición de que nazca con vida, lo que técnicamente se trata de una condición de carácter resolutorio⁽²⁶⁾. Similar solución adopta Vélez en el Código Civil argentino⁽²⁷⁾.

Para que el nacimiento se reputa como tal debe cumplir los siguientes requisitos, a saber: a) total separación del vientre materno; b) que el nacimiento se produzca con vida; c) que el recién nacido tenga forma humana.

a. Separación del vientre materno. Se obtiene mediante el corte del cordón umbilical que mantiene unido al feto con la madre, puesto que hasta ese momento permanece biológicamente unido a ella⁽²⁸⁾.

b. Nacimiento con vida. Una vez producida la separación con el vientre materno, el recién nacido tiene "que tener vida propia", es decir "que respire por sí mismo"⁽²⁹⁾. En circunstancias normales no existe motivo alguno que induzca establecer si el nacimiento se produce con vida, pero en casos extremos, dudosos, conflictivos, se hace imperioso determinarlo, por cuanto es necesario para ratificar la calidad de "sujeto de derecho" que nazca con vida, debido a la lógica incidencia que

ello tiene en la adquisición, modificación o pérdida de derechos. En la casuística romana tenemos al respecto el parecer jurídico de las dos grandes escuelas jurídicas, proculeyana y sabiniana. Los proculeyanos sostienen una posición más restringida, exigiendo que el recién nacido brinde muestras evidentes de existencia, v.gr., gritos, llantos, movimientos. Por su parte, los sabinianos tienen una consideración más amplia sobre el tema, estableciendo que basta "cualquier signo de vida", que puede consistir desde un simple movimiento a la leve respiración. Posteriormente, Justiniano se inclina por la solución propuesta por la escuela sabiniana⁽³⁰⁾.

c. Forma humana. Se exige además que el recién nacido tenga "forma humana". Requisito lógico, consonante con la época, dado el espíritu sumamente religioso y supersticioso del pueblo romano, ya que el hecho de que una mujer dé a luz de sus entrañas un portento evidencia que los dioses no lo auspician⁽³¹⁾.

IV. REFLEXIÓN SOBRE LA DEBIDA CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA EN ROMA. EL CASO EN PARTICULAR DEL HERMAFRODITISMO⁽³²⁾

He señalado en diversas oportunidades que el derecho creado por Roma reboza de humanismo y gira en pos de la defensa del más débil; y si se me permite una mayor justeza en la apreciación, soy de la opinión de referirme con mayor propiedad a la situación del "desprotegido" en lugar del "más débil", simplemente porque considero que la "desprotección trae consigo la debilidad". Por ende, no advierto, en principio, "débiles protegidos", dado que si logran tener la cobertura jurídica apropiada, dejan de serlo; en cambio, "aquel que necesita protección" es porque "está inmerso en una indefensión que lo torna débil". Justamente, "la debilidad se encuentra en la falta de protección jurídica". Lo expuesto está dicho con el ánimo de resaltar el fino espíritu del jurista romano, que avizora en modo excelente la verdadera esencia del derecho, "generando protección para aquellos que lo necesitan", demostrando un claro sentido humanista, por lo cual y con toda justeza, los prestigiosos maestros Schipani y D'Ors los elevan a la consideración de "fundadores del derecho" (iuris conductores)⁽³³⁾.

Lo expuesto permite introducirme en la evolución de la consideración de la persona en el derecho romano. Supra me he referido al tema de "la persona por nacer" y cómo ha ido variando la apreciación jurídica de los juristas en cuanto a ella, deviniendo a la postre en fuente directa de nuestro derecho actual⁽³⁴⁾. A ello habré de añadirle el caso del hermafrodita, que demuestra a las claras que la evolución humanista de la jurisprudencia romana sobre "la consideración de la persona como tal" ha sido constante y coherente.

Es evidente que el derecho antiguo, entendiendo por éste la "ley de las XII Tablas", no contempla la situación del hermafrodita en particular; lo que me permite señalar que el nacimiento de un ser humano portador de los dos sexos no es un signo bien visto en la comunidad, y, de verificarse dicha situación, en el mismo momento del parto el niño "debe ser muerto". Esto se condice con la concepción primitiva de la sociedad romana, puesto que un recién nacido con señales evidentes de ambigüedad en cuanto a la determinación del sexo seguramente es señal de los dioses de mal presagio, tanto para su familia como para el resto de la comunidad⁽³⁵⁾. Por dicho motivo, y circunscribiéndome al "derecho quirritario", entiendo que en el caso del nacimiento de un hermafrodita se aplica la disposición de la "ley decenviral", que ordena que "el hijo deforme o monstruoso debe ser muerto inmediatamente"⁽³⁶⁾. Posteriormente, durante el transcurso del derecho clásico, la situación cambia y hallamos pasajes de Ulpiano⁽³⁷⁾ y Paulo⁽³⁸⁾ que nos dan la razón, puesto que hablan del hermafrodita con naturalidad, demostrando que el alumbramiento de "un ser portador de ambos sexos" que, de acuerdo con las viejas costumbres, significaba "un mal presagio" y que debía "purificarse mediante su muerte en agua", no produce la misma consideración a juicio de los citados prudentes. En otras palabras, lo consideran persona y lo protegen como tal; sólo inquierien respecto del sexo que éste debe tener, pero en momento alguno seexpiden en darle muerte. Es más, avanzando aun en el tema, ambos juristas son contestes en afirmar "la prevalencia del sexo" en el hermafrodita, lo que, dicho en otras palabras, significa lo que él "se siente ser". En este sentido, ambos juristas hablan de "la calidad del sexo predominante". Y realmente la solución que brindan los prestigiosos juristas Paulo y Ulpiano, en mi opinión, es asombrosamente admirable por lo actual. La ciencia médica hoy considera que "el hermafroditismo puede presentar dos aspectos"; por un lado, la presencia de "genitales externos ambiguos", y, por otro "genitales que pueden no corresponder con la composición genética de la persona", v.gr., "genitales femeninos en un paciente genéticamente masculino", o viceversa. Está claro entonces que el hermafrodita, en el segundo de los supuestos indicados, necesariamente debe adoptar "el sexo que él mismo siente". En estos casos, en mi opinión, no se puede aceptar otra solución en contrario, por cuanto una persona hermafrodita que se siente mujer porque presenta "órganos genitales femeninos", aunque genéticamente es un hombre, o viceversa, no puede la ley, ni tampoco el orden público, imponerle

sexo, dejando en claro, por supuesto, que tampoco consiste en otra calidad distinta de sexo. En definitiva, y repitiendo las mismas palabras de los célebres maestros Ulpiano y Paulo, "el hermafrodita debe adoptar el sexo que en él prevalece". Lo admirable es el sentido común y sabiduría de ambos juristas clásicos al resolver la cuestión, por cuanto habremos de tener en cuenta que si cotejamos las aseveraciones de la ciencia médica actual y las soluciones de Ulpiano y Paulo, advertimos que refieren lo mismo, ninguno cuestiona la calidad de persona del hermafrodita y son contestes en afirmar que éste en definitiva debe "tener el sexo que siente", porque en el "derecho moderno de la persona" lo que importa es su bienestar e integridad, lo que quiere decir, cuerpo y alma. Entonces, las soluciones de Paulo y Ulpiano demuestran un grado de progreso y madurez que bien pueden considerarse de nuestro tiempo, con la diferencia de que los citados prudentes no contaron con la ayuda de la tecnología moderna, lo cual torna su labor aún más meritoria.

V. LA CAPACIDAD⁽³⁹⁾

La capacidad jurídica, entendida como "la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones", sólo la tiene en Roma aquel individuo que goza de los llamados "tres estados". Estos "estados" (status) son el de familia (status familiae), el de libertad (status libertatis) y el de ciudadanía (status civitatis). El individuo que goza de ellos es considerado "sujeto de derecho" y, por ende, capaz jurídicamente (caput).

En la práctica, como lo adelantara oportunamente, quien aglutina la totalidad de los "tres estados" indicados es el pater familias. Éste es el verdadero "sujeto de derecho de existencia visible", quien ejerce únicamente la capacidad jurídica para sí y para la totalidad del núcleo familiar. De aquí la importancia de su estudio en la Roma primitiva y su desarrollo dentro de la familia, puesto que al evolucionar ésta, también de algún modo hace lo propio aquél, deviniendo, depuración mediante en el tiempo, en "el sujeto de derecho moderno".

1. La capacidad y sus diversas clases. La incapacidad

En Roma, como también en nuestro derecho, la capacidad puede ser de derecho o de hecho. La primera es "la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones", mientras que la segunda "es la aptitud para ejercerlos". Sabido es que la "capacidad de derecho" es primordial para la existencia del "sujeto de derecho", ya que la "capacidad de hecho" puede no acompañarlo, aunque, claro está, puede ser suplida, v.gr., designación de tutores y curadores.

Lo contrario a la capacidad es la "incapacidad". O sea que esta última es "la falta de aquélla". La incapacidad puede ser entonces tanto de "hecho" como de "derecho y además tanto una como la otra pueden ser absoluta o relativa. En Roma, dado que se admite la esclavitud, "existe la incapacidad absoluta de derecho", lo cual no acontece en nuestra legislación, por cuanto ella ha sido abolida definitivamente en el año 1813.

La "capacidad de derecho" en Roma se encuentra ligada estrechamente a la condición de pater familias. De tal modo, según la jurisprudencia romana, el "padre de familia" mayor de edad (25 años) que goza del pleno uso de sus facultades mentales y de los derechos del ciudadano romano es plenamente capaz, tanto jurídicamente como de hecho.

Esto significa que el "hijo de familia" (filius familias), en su condición de aliena iuris, sólo tiene aptitud para ser capaz de derecho cuando fallece el pater, al cual pertenece. Mientras tanto, es considerado incapaz de derecho, aunque posteriormente, con la evolución de los "peculios", se produce un cambio de criterio, el cual será analizado oportunamente.

Ahora bien, si el "padre de familia" fallece estando concebido el hijo o una vez producido su nacimiento, el hijo adquiere la calidad jurídica de "padre de familias" (sui iuris) y desde ese momento es considerado plenamente capaz de derecho, pero lógicamente es reputado incapaz de hecho en razón de la edad.

2. La pérdida de la capacidad

La pérdida de la capacidad es conocida como "disminución o pérdida de la cabeza" (*capitis deminutio*). Las fuentes dan cuenta de ella, entre otros términos, como "el cambio de la primera posición"⁽⁴⁰⁾, "cambio del estado anterior"⁽⁴¹⁾, "variación de estado"⁽⁴²⁾, etc.

Esta institución de antigua data evoluciona con el transcurso del tiempo, ya que se diferencia según la época. Primitivamente, la "pérdida de la capacidad" sólo se da cuando es expulsado un individuo del grupo familiar, lo que implica su exclusión del sistema social y jurídico. Luego, cuando se consolida la *civitas*, y con ella la idea de ciudadanía, la "disminución de cabeza" se perfila en dos aspectos, uno referido a la pérdida de la ciudadanía y el otro continúa siendo la expulsión del grupo familiar. Finalmente, en el período clásico se le añade la afectación de la libertad del individuo y se encuentra entonces configurada la "disminución de cabeza" según tres grados: máxima, media y mínima⁽⁴³⁾.

La "disminución de cabeza máxima" (*capitis diminutio maxima*) se produce cuando la persona pierde la libertad y se convierte en esclavo, v.gr., por no pagar sus deudas y es vendido por su acreedor una vez agotadas todas las instancias. La caída en esclavitud trae consigo las pérdidas de la ciudadanía y la familia, es decir, la pérdida de la condición de sujeto⁽⁴⁴⁾.

La "disminución de cabeza media" (*capitis diminutio media*) significa la pérdida de la ciudadanía romana, v.gr., cuando un ciudadano romano se exilia por haber cometido un delito, o se convierte en ciudadano de otro Estado. Esta situación implica también la pérdida del vínculo familiar (agnación) y de la patria potestad⁽⁴⁵⁾.

La "disminución de cabeza mínima" (*capitis diminutio minima*) importa la interrupción del vínculo agnaticio. Esto implica que se produce una modificación en el vínculo familiar. No significa siempre "una disminución", puesto que en ciertas oportunidades puede comprender un ascenso, una mejora. Por ello se habla de "interrupción" o "ruptura" del vínculo familiar en lugar de pérdida, por ejemplo cuando un "jefe de familia" (*sui iuris*) es adoptado (adrogado) por otro "jefe de familias" y se convierte en hijo de éste (*aliena iuris*); lo mismo acontece con la legitimación de un hijo, y en el matrimonio *cum manu*. Pero en los casos de "emancipación" se produce el caso inverso, puesto que el hijo que tiene la condición jurídica de *aliena iuris* pasa a *sui iuris*.

VI. LA ESCLAVITUD⁽⁴⁶⁾

Los romanos, inmersos en su tiempo, no pueden sustraerse de la institución de la esclavitud, conocida y utilizada en demasía por todos los pueblos de la Antigüedad. Soy de la opinión de que si bien hoy en día se afirma que se encuentra superada, entiendo que ello no es del todo cierto, por cuanto existen "modernas formas de esclavitud" que asemejan una lamentable y sofisticada evolución, pese a los denodados intentos de la humanidad por abolirla totalmente.

En Roma las guerras nutren continuamente de esclavos a la sociedad mediante el aporte de gran número. La esclavitud es necesaria en Roma por varios motivos. En primer lugar, implica la utilización de mano de obra barata. El desconocimiento de máquinas complejas hace que se las supla mediante la actividad humana; así, agro, canteras, minas, industrias, navegación, construcciones civiles y públicas, etc., demandan gran cantidad de mano de obra. En segundo lugar, la falta de capital circulante, puesto que la acuñación oficial es escasa para cubrir la totalidad de requerimientos, hace que muchas veces se supla mediante la utilización de esclavos, empleados como parámetro económico. En tercer lugar, aprovechar el conocimiento o experiencia de los pueblos conquistados, ya que aquellas personas que se destacan por su cultura, profesión o inteligencia, v.gr., médicos, ingenieros, juristas, educadores, cocineros, etc., son utilizados para que continúen desarrollando, bajo esclavitud, la sabiduría y aptitud adquirida como hombres libres.

Lo dicho implica que si bien en Roma existe gran cantidad de esclavos, también los hay de distintas clases. No es lo mismo la vida de un esclavo destinado a trabajar en las minas, canteras, galeras, etc., que la de aquel que por su conocimiento o profesión (médico, maestro, escritor, cocinero, sastre, etc.) se encuentra prácticamente conviviendo con el amo. Esto permite aseverar

que el romano sabe apreciar el valor de la persona sometida a esclavitud, utilizando de un modo racional sus conocimientos, valiéndose de ellos para el mejor provecho del interés del grupo familiar. Debe recordarse que por el "carácter corporativo" de la familia primitiva romana, es necesario que el "jefe de familia" cuente con la ayuda valiosa de gente capacitada, y de confianza, para aprovecharla convenientemente en el desarrollo de sus "factores económicos de producción". En este sentido, es frecuente que un hijo o un esclavo se encuentren al frente de las posesiones económicas, v.gr., astilleros, minas, transportes, canteras, industrias, campos, etc. Ello apunta a que no todos los esclavos son tratados del mismo modo; los valiosos reciben un trato preferencial que incluso les permite tener su propia familia (contubernio).

La expansión militar y económica de Roma motiva el auge de la esclavitud. En la época primitiva, las familias patricias sólo tienen esclavos (unos pocos) cuando les es indispensable para ayudar al amo, tanto en los quehaceres de la ciudad como en los del campo. Al constituir un número reducido, ligados al amo y su familia, pertenecen a esta última como si formaran parte de ella, y si bien el amo tiene sobre el esclavo todos los derechos inherentes a la propiedad, no hace falta, por lo general, su aplicación. Además, la clientela del pater familias también contribuye a paliar las necesidades económicas y de mano de obra que tiene la familia primitiva. En las familias plebeyas la situación al principio es distinta. Por lo general no tienen esclavos, dado que sus necesidades primarias son cubiertas por el grupo familiar y su parentela (hijos, yernos y nueras).

Más tarde, con la expansión territorial que se inicia durante la República, se masifica la esclavitud dentro de la sociedad romana. El lujo, el ocio, la necesidad de figurar, lleva a que los "jefes de familias" adquieran gran cantidad de esclavos vendidos por el Estado a causa de las guerras (prisioneros). Ello aparea un cambio dentro de la sociedad romana, ya que en muchos casos se pasa de un trato casi familiar y directo, que hasta ese momento mantiene el amo con el esclavo, a una relación prácticamente anónima, distante, llevada a cabo por intermedio de terceros (capataces), que aplican los medios de coerción en nombre del amo ante cualquier atisbo de sospecha, v.gr., la vara (ferula), la correa de cuero (scutica), el aguijón (stimulus), etc.

1. La condición jurídica del esclavo

Los juristas romanos saben perfectamente que el esclavo es "un ser humano" (homo) similar al hombre libre, pero debido a su condición lo consideran jurídicamente "una cosa", y como tal debe ser tratado, aunque esto último en definitiva es responsabilidad pura y exclusiva del amo, quien puede ser duro o benigno con él. Siendo el esclavo "una cosa", carece de titularidad de derechos. Este rígido principio deriva de la aplicación del "derecho quiritaro". Luego, por influencia del cristianismo, se atempera este precepto, arribándose mediante la aplicación de las "acciones de responsabilidad" (acciones adiecticiae qualitatis) a que el esclavo pueda obligarse, responsabilizando al amo por el ejercicio de su actividad.

Efectuadas estas primeras consideraciones, puedo afirmar que la esclavitud es una institución del "derecho de gentes" por la cual un hombre privado de su libertad se encuentra destinado permanentemente al servicio de otro. Los juristas romanos son conscientes perfectamente de que todos los hombres nacen libres y que luego, por contingencias de la vida, v.gr., guerras, deudas, delitos, etc., pueden perder tal cualidad y caer en esclavitud⁽⁴⁷⁾. Esto debe entenderse en el sentido de que si bien el esclavo es considerado "una cosa", lo es de un modo especial, por cuanto las fuentes hacen notar que es "una cosa con raciocinio", puesto que no pueden soslayar absolutamente su condición humana, configurándose por tal motivo paliativos a su dura condición.

En principio, como he dicho, el esclavo no posee derechos; por el contrario, es objeto de ellos. El amo ejerce sobre el esclavo todos los derechos inherentes a la propiedad, v.gr., vender, donar, castigar, ejecutar, entregar como reparación de un daño a cambio de indemnización, etc.⁽⁴⁸⁾. Pero por la propia condición humana del esclavo ("una cosa que piensa"), comienzan a emerger atenuaciones a este rígido principio. Así, desde el punto de vista religioso, la sepultura del esclavo es respetada; y además en vida se le permite tomar parte en los cultos religiosos. También puede realizar casi todos los negocios jurídicos que lleva a cabo un hombre libre, pero siempre a nombre de su amo, convirtiéndose en un instrumento de adquisición de éste, con la salvedad de que sólo puede obligarlo en cuanto mejore su condición patrimonial, careciendo de valor jurídico todo aquello que importa una pérdida para su amo. Como este sistema trae a la larga una verdadera situación de injusticia para quien contrata con el esclavo, se mitiga ésta, como se dijo, mediante la

implementación de las denominadas "acciones de responsabilidad del padre de familia" (actionis adiecticiae qualitatis).

También el dueño puede asignarle un peculio al esclavo, por medio del cual éste responde ante aquél y ante extraños. Si bien el propietario del peculio continúa siendo el amo, que puede revocar directamente el peculio asignado, o recibirlo nuevamente ante el fallecimiento del esclavo, en la práctica, la sociedad romana considera que aquél le pertenece al esclavo, de modo tal que con sus beneficios pueda adquirir hasta su propia libertad.

Merecen considerarse también algunos importantes principios en pro del esclavo que derivan de su contemplación de su condición de ser humano. Así, durante el Imperio, y con la influencia del cristianismo, se decide: a) prohibir que los esclavos fueran arrojados a las fieras sin la anuencia del magistrado; b) al amo que abandona al esclavo enfermo o viejo se lo castiga con la pérdida de la propiedad sobre éste; c) se considera homicida al amo que lo mata sin motivo; d) se obliga al amo excesivamente cruel con sus esclavos a venderlos⁽⁴⁹⁾. Todo lo cual demuestra la mutación que sufre esta institución a medida que la sociedad romana evoluciona con el transcurso del tiempo. En ello ha tenido mucho que ver con este cambio la labor de los juristas influenciados por la doctrina del cristianismo. Este último provoca una verdadera revolución, que hace mella en la sociedad romana, profundizando sabiamente la transformación que comenzara a atisbarse en las postrimerías de la República.

2. Las fuentes de la esclavitud

En Roma se puede ser esclavo por nacimiento o por un hecho sobreviniente a la condición de hombre libre⁽⁵⁰⁾.

El primer supuesto (por nacimiento) significa que el hijo sigue la condición de la madre, siendo el principio rector que "el hijo de madre esclava sigue su misma condición jurídica". Luego, la rigidez de esta norma se atempera, considerándose libre al hijo si la madre hubiera gozado de libertad en algún momento durante la concepción⁽⁵¹⁾.

El segundo (por hecho sobreviniente) consiste en realidad en hechos regulados expresamente por la ley, siendo de variada índole según provengan del "derecho de gentes" o del "derecho civil". En cuanto al ius gentium, la principal fuente es la guerra, dado que los tomados como prisioneros pueden ser vendidos como esclavos sin ningún miramiento. El mismo principio se aplica en la situación inversa cuando un ciudadano romano cae cautivo de sus enemigos. La excepción consiste en ser tomado prisionero por piratas, ladrones o en una guerra civil, puesto que todos estos supuestos no convalidan la caída en esclavitud⁽⁵²⁾. Con relación al ius civile, proviene de las siguientes causas: a) la venta del deudor insolvente ejecutado por medio de la manus iniectione ejercitada por el acreedor; la venta del hijo por su padre; la venta por ladrones y desertores al ejército; etc.; b) el hombre libre que se hace pasar por esclavo para ser vendido como tal y engañar así al comprador, participando en la ganancia obtenida con la venta; c) la mujer que mantiene relaciones íntimas con un esclavo haciendo caso omiso a la oposición del dueño del esclavo en tres oportunidades; d) el liberto que incurre en ingratitud con su ex amo, volviendo así a caer en esclavitud; e) aquel que ofende a embajadores o representantes extranjeros, en estos casos el ofensor es abandonado a su suerte y entregado para su castigo al país del ofendido; f) los condenados a la pena capital o al trabajo en las minas, en donde se da la particularidad de que los condenados son considerados "esclavos sin dueño", o mejor dicho "siervos de la pena misma"; h) el que no cumple con los requerimientos del censo; i) el que es sorprendido robando in fraganti⁽⁵³⁾, etc.

3. La extinción de la esclavitud

Un esclavo deja de serlo por "decisión del amo" o "por la ley". El primer supuesto recibe el nombre de "manumisión", y consiste en el acto voluntario del amo mediante el cual le otorga la

libertad al esclavo⁽⁵⁴⁾. El segundo supuesto comprende aquellos casos en que la ley dispone la libertad del esclavo.

a) Manumisión por decisión del amo. Puede concederse mediante dos formas, una "solemne" y otra "no solemne, que generan efectos dispares. Encuentro en esta institución una vez más el fino sentido jurídico del jurista romano, quien comprende perfectamente la importancia del "principio de la publicidad del acto y su oponibilidad a terceros". Por tal motivo, el derecho romano, consciente de la magnitud del "acto de manumisión", puesto que a través de él se modifica la condición jurídica de un ser humano que pasa de esclavo a hombre libre, rodea al acto de formalidades extremas en un caso (solemne), y en otro las deja de lado (no solemne), para brindar mayor certeza y seguridad a la sociedad, indicando de este modo el alcance de la "manumisión".

Por lo tanto, la "manumisión solemne" tiene como efecto primordial otorgarle "la libertad al esclavo" y, al mismo tiempo, la "condición de ciudadano romano", adquiriendo los derechos inherentes a "la libertad" y a "la ciudadanía" en igual grado que su manumisor (ex amo), por cuanto no puede adquirir una mejor condición que la de aquel que le concede la libertad.

La "manumisión no solemne", en cambio, le brinda al manumitido una "libertad de hecho" y no "de pleno derecho". Esta condición precaria genera inseguridad, ya que puede ser revocada por voluntad de su ex amo cuando éste así lo quiera. Por supuesto que esta forma de manumisión no otorga la ciudadanía romana.

— Los modos solemnes de manumitir. Se lleva a cabo per vindicta, "censo" y "testamento"⁽⁵⁵⁾. La "manumisión per vindicta", en su versión primitiva, se lleva a cabo mediante "la simulación de un juicio ante el magistrado". De común acuerdo concurren ante el magistrado el amo, el esclavo y otra persona amiga (adsertor libertatis). Una vez ante el magistrado, generalmente el pretor, aunque también puede ser el cónsul y en las provincias el gobernador, se instrumenta el acto a través de la in iure cesio. El tercero (adsertor libertatis) reclama la libertad del esclavo, a lo cual el amo no se opone, siendo allí que el magistrado la convalida. Posteriormente el acto se simplifica, bastando solamente "la manifestación de voluntad del amo ante el magistrado"⁽⁵⁶⁾. La "manumisión por censo" se formaliza cuando el amo "inscribe en el censo" al esclavo como "hombre libre". La "manumisión por testamento" se concreta cuando el amo establece en el testamento la voluntad de dar la libertad al esclavo. A su vez, este tipo de "manumisión" se puede llevar a cabo de modo directo o indirecto. Es directo cuando el amo inserta la voluntad de darle la libertad al esclavo o nombrarlo heredero. El esclavo así manumitido se convierte en "liberto del difunto". El modo indirecto es cuando el testador le encarga a su heredero que manumita al esclavo. Éste debe formalizar la manumisión en cumplimiento de la voluntad del difunto mediante alguna de las formas solemnes. Se considera en estos casos al esclavo liberto del heredero. También en este supuesto el magistrado puede actuar en defensa del derecho del esclavo a ser declarado libre si el heredero se niega a cumplimentar la voluntad del testador⁽⁵⁷⁾.

Las indicadas "formas solemnes de manumisión" tienen auge durante la época antigua y clásica. Más tarde, en el Bajo Imperio, con Constantino, se agrega otro modo solemne de manumisión conocido como "manumisión ante las autoridades eclesiásticas" (manumisión in ecclesia), o también como "manumisión ante los fieles reunidos en la iglesia (in ecclesia), quienes son los encargados de receptor la voluntad del amo de manumitir al esclavo.

— Los modos no solemnes de manumitir. Se configuran cuando el amo le da la libertad al esclavo en los siguientes casos, ya sea directamente ante amigos que ofician como testigos del hecho (inter amicos), o bien cuando el amo le otorga la libertad a través de una carta dirigida al propio esclavo (per epistolam), o cuando el amo le concede autorización al esclavo para sentarse junto a él en su mesa (per menam)⁽⁵⁸⁾.

Estos modos "no solemnes" nacen con posterioridad a la época republicana, desplazando en muchos casos a los "solemnes" cuando las costumbres comienzan a cambiar y a relajarse respecto del vetusto sistema anterior. Sin embargo, originalmente no tienen plena validez legal, considerándose al esclavo manumitido de dicho modo como "hombre libre de hecho y no de derecho". El manumitido goza de libertad, pero el ex amo puede revocar su decisión en cualquier momento.

b) Manumisión por imperio de la ley. La esclavitud se extingue cuando se concede la libertad al esclavo como recompensa por su conducta ante casos concretos, v.gr., cuando gracias a la intervención del esclavo se descubre al asesino del amo; cuando se comporta valientemente en beneficio de la comunidad en momentos de guerra o calamidad pública; cuando el manumitido "de buena fe" se cree hombre libre y ha vivido como tal por espacio de veinte años, etc. Y, en otros supuestos, la libertad se concede al esclavo como castigo a la conducta indigna del amo, v.gr., cuando lo abandona por estar viejo o enfermo⁽⁵⁹⁾.

3.1. Las restricciones a las facultades de manumitir

El pater familias, como único "sujeto de derecho" y por ende responsable del patrimonio familiar, es quien decide y efectiviza las "manumisiones", gozando de amplia voluntad para proceder a la libertad de su plantel de esclavos. Si bien en principio las manumisiones se realizan de modo prudente, luego, por distintas razones, entre otras, el afán de ser recordado como buena persona una vez acaecida la muerte, lucrar excesivamente, querer contar con una nutrida clientela, se abusa de esta institución. Ello origina fuertes efectos económicos y sociales. Así, en primer lugar, el hecho de otorgar la libertad a gran cantidad de esclavos produce un vaciamiento dentro del "patrimonio corporativo de la familia". No se debe olvidar que los esclavos son de alguna manera un capital que se emplea para múltiples funciones, como ser, la realización de distintas tareas y profesiones, su utilización en los trueques a falta de dinero, etc. En segundo término, las excesivas manumisiones permiten el acceso a la ciudadanía a gran cantidad de personas que no se encuentran preparadas para ello debido a sus propias condiciones naturales.

Esta situación genera en tiempos de Augusto "restricciones o limitaciones a la facultad de manumitir". Es decir, el poder público, corporizado en la voluntad del Príncipe, "interfiere y prevalece sobre la propia voluntad de los individuos". Las leyes propuestas en tal sentido son lex Fufia Caninia y la "lex Aelia Sentia de manumissionibus".

La primera de las leyes es propuesta por los cónsules C. Fufius Geminus y L. Caninius Gallus, en el año 2, a pedido de Augusto, y dispone la limitación testamentaria de las manumisiones, estableciendo una escala proporcional de acuerdo con la cantidad de esclavos que el propietario tiene bajo su dominio, agregándole un tope. Sólo en función de ella se puede otorgar la libertad. Dispone que aquel que tiene de tres a diez esclavos sólo puede liberar la mitad; de once a treinta esclavos, la tercera parte; de treinta y uno a cien esclavos, la cuarta parte, y de ciento uno a quinientos esclavos, la quinta parte. Además, fija el tope de cien esclavos manumitidos, es decir que en definitiva, cualquiera fuera el número de esclavos que se tenga, nunca se puede sobrepasar el tope de cien manumisiones. También exige que éstas deban ser nominativas, o sea que debe figurar el nombre del esclavo a quien se quiere beneficiar⁽⁶⁰⁾.

La segunda de las leyes es a propuesta de los cónsules Sexto Elio y Cayo Sentio, en el año 4, también a pedido de Augusto, y restringe severamente la facultad del propietario de esclavos de manumitirlos, dado que dispone en sus distintos apartados que los libertos que con anterioridad al acto de su liberación hubieran padecido "penas de azotes" o "trabajos forzados" no alcanzan la categoría de "latinos", sino de "dedicticios", por lo que son considerados súbditos de Roma, pero no ciudadanos. Asimismo establece que el propietario menor de 20 años no puede manumitir a sus esclavos, salvo que lo haga por medio de la vindicta ante un consejo formado por diez jueces y fundando la causa de la decisión. Además, prohíbe que el propietario manumita a los esclavos menores de 30 años, a menos que lo efectúe del modo descripto anteriormente. En ambos casos, lo dispuesto es bajo apercibimiento de la "nulidad del acto", siendo considerado el liberto como "latino juniano", es decir "libre", pero con limitaciones en sus derechos de ciudadanía. Finalmente el acto es nulo si está dirigido a cometer fraude en perjuicio de los acreedores del propietario⁽⁶¹⁾.

Posteriormente, Justiniano suprime prácticamente estas limitaciones, implementando la plena libertad de manumitir, con la condición de que el propietario tenga como mínimo 17 años de edad, tope que después reduce a 14 años, pero manteniendo la prevención del "fraude a los acreedores"⁽⁶²⁾.

4. La situación jurídica del liberto. Diferencias con el ingenuo. El Patronato

Se llama "ingenuo" (ingenuus) al que nace y vive siempre libre. El "liberto" (libertus), por el contrario, es el esclavo manumitido. Existen diferencias notorias entre ambos, tanto en lo que concierne al derecho público como al privado.

En el campo del derecho público, el "liberto" tiene vedado el acceso a las magistraturas y al Senado. Respecto del derecho privado, en principio, el "liberto" no puede casarse con "ingenuos", luego se limita esta prohibición respecto de los miembros de la clase senatorial. Finalmente, Justiniano suprime esta disposición.

Dentro del campo del derecho privado resulta necesario hacer también referencia al "patronato", que consiste en la particular relación que continúa involucrando al liberto con su ex amo y aun con los descendientes de éste. Ello acarrea distintas consecuencias, que paso a ameritar: 1) el liberto no puede demandar a su patrono sin autorización del magistrado; 2) tampoco puede exigir el pago de una condena mayor de lo que su patrono buenamente puede pagar; 3) el patrono y sus descendientes tienen derechos hereditarios ab intestato respecto del liberto; 4) el patrono tiene derecho de ejercer tutela sobre los libertos púberes y las libertas; 5) el patrono exige al liberto mediante "juramento" (iusiurandum liberti) la realización de distintas "tareas y servicios gratuitos" (operae), debiendo en muchos casos intervenir el magistrado como consecuencia de los abusos cometidos por los patronos a dicho respecto; 6) el patrono debe pasar alimentos a su liberto; 7) el patrono no puede acusar al liberto por aquellas cuestiones sancionadas con la pena capital.

Es decir que los esclavos manumitidos "quedan ligados" a su ex amo, a quien en su carácter de patrono continúan de algún modo sometidos, aunque con diferencias respecto de su estado anterior, dado que les asisten determinados derechos. Esta particular situación que se da en llamar "patronato" es una de las fuentes de la "clientela". Esta última forma parte de la familia romana y está constituida por los "libertos" y también por "hombres libres" que desean someterse a "la protección de un jefe de familias". Este antiguo sistema tiene su auge durante la Monarquía y la República. Más tarde, durante el Principado, se comienza a equiparar a los libertos e ingenuos mediante la utilización de dos formas, una más atenuada, en la cual la igualdad se realiza, pero manteniendo el "patronato" (ius anulorum aureorum), y otra concreta, en la cual el liberto se convierte totalmente en ingenuo (restitutio natalium).

FRANJA

5. Otra situación afín a la esclavitud. El colonato

El colonato es la singular relación que existe entre "un hombre libre y su condición de adscrito a la tierra que trabaja". Aparece nítidamente como institución durante el Bajo Imperio, y si bien puede ser considerada como una "situación jurídica afín a la esclavitud", mantiene sutiles diferencias con ésta. Se origina en la necesidad de los grandes latifundios de tierras en ser explotados, y como la institución de la esclavitud se resiente, resulta necesario otro tipo de relación que ubique a quien trabaja la tierra en un estado intermedio entre la libertad y la esclavitud, esto es, el colonato. De hecho, el colono es un hombre libre que puede obligarse, adquirir bienes y contraer matrimonio, pero en cambio no puede realizar actos de disposición, ni tampoco ejercer cargos públicos. Si bien se lo considera un hombre libre y es respetado como tal por el propietario de la tierra, se encuentra ligado a ésta de modo perpetuo, y cuando ésta se vende, también se transfiere al colono junto con ella. Entonces, el colonato es una institución económica destinada a paliar la falta de mano de obra para cultivar las grandes extensiones de tierra, dado que si bien el afectado a tal situación es libre, se encuentra ligado a la tierra donde vive y está obligado a trabajarla. Tiene derecho a satisfacer sus necesidades con lo producido y anualmente debe pagar un canon al propietario, que puede ser en dinero o en especie. Esto es importante, ya que el propietario soluciona de dicho modo el problema fiscal, puesto que las grandes extensiones de tierra tributan y, al hacerlas producir y percibir el canon, cumple con la carga impositiva.

La condición de colono se adquiere por distintas causas; la principal es el nacimiento, pero también se puede serlo por decisión mutua entre propietario y hombre libre, disposición imperial, las guerras, por practicar la mendicidad, etc. Asimismo se deja de ser colono cuando éste adquiere la propiedad de la tierra, ejerce el sacerdocio, ingresa al ejército, se lo nombra decurión⁽⁶³⁾, etc.

El primer motivo por el cual se adquiere la calidad de miembro de una familia romana, quedando sujeto al poder del jefe de ésta, es la procreación en legítimas nupcias mediante individuo varón de la familia. Igual valor tiene el ingreso a la familia cuando el individuo es adoptado por el pater familias mediante cualquiera de sus formas, es decir, cuando se trata de un filius ajenos (adopción propiamente dicha) o cuando se trata de otro pater familias (adrogatio).

El pater familias es el único capaz de figurar como sujeto a nombre propio en las relaciones de negocio y las controversias jurídicas. Aquellos sometidos a su potestad no son otra cosa sino meros instrumentos suyos de adquisición, prolongaciones de su personalidad, para quien adquieren los bienes económicos destinados a cumplimentar la evolución de la entidad doméstica.

1. Las relaciones patrimoniales con el pater familias

En Roma sólo el pater familias tiene derechos patrimoniales. El que está bajo la potestad de otro no tiene nada propio. El titular de los derechos patrimoniales, de acuerdo con el ius civile, sólo puede ser el pater familias. Esto es consecuencia natural de la "posición autónoma" que tiene la familia frente al Estado y en orden a su propio derecho. El patrimonio determina la calidad de la persona, a la inversa de lo que acontece en nuestros días, que se considera que es un atributo de la condición de sujeto de derecho.

La "teoría de la personalidad jurídica" entre los romanos es puramente objetiva, patrimonial, corporativa, puesto que cualquier cosa, derecho real, crédito, herencia, que adquiriera el hijo se entiende adquirido por el padre, y éste es quien se hace propietario, o titular, por el derecho civil. Durante la República, la situación del filius familias cambia con la aparición del peculio, modificándose este sistema de incapacidad en el cual se encuentra inmerso.

VIII. EL PECULIO Y SUS DISTINTAS CLASES⁽⁶⁵⁾

El peculio es una pequeña suma de dinero o masa de bienes que el pater familias le concede al hijo en goce y administración, pero que éste no puede donar ni disponer por acto de última voluntad⁽⁶⁶⁾. En Roma se conocen cuatro clases de peculios: profecticio, castrense, cuasicastrense y materno (bona adventicia).

1. Peculio profecticio

Es el primero que se admite. Se puede otorgar no sólo al hijo (filius), sino también al esclavo. Son los bienes concedidos por el pater familias que, ante la muerte del hijo o del esclavo, retornan automáticamente al patrimonio de aquél. Además, la concesión del peculio es revocable. Estos bienes entregados por el pater al filius o al esclavo son utilizados por lo general en ejercicio del comercio o industria. El propietario del peculio es siempre el pater familias y el hijo solamente tiene facultades de disfrute y administración, no pudiendo disponer de ellos.

2. Peculio castrense

Consiste en los bienes adquiridos por el hijo en ocasión del servicio militar. En principio, también le pertenecen al pater. Recién a partir de Augusto y sus sucesores se admite que el filius familias es

también el propietario de esos bienes, conformando un verdadero patrimonio. El hijo militar puede disponer libremente de este peculio, hacer donaciones y transmitirlo por disposiciones de última voluntad (mortis causa), cualquiera sea su género, se trate de sueldos, botines de guerra, distribución de tierras, etc.⁽⁶⁷⁾. Si bien en un principio sólo forman parte de él los bienes de origen estrictamente militar, luego el concepto se amplía, contemplando, además del botín obtenido en la guerra, las herencias, los legados otorgados por los compañeros de armas y las liberalidades entregadas por amigos y parientes con motivo de partir el filius a la guerra. Como ya dijera ut supra, el hijo posee plena libertad sobre estos bienes, pudiendo enajenarlos, donarlos o disponerlos mortis causa, pero aun así y todo, si lo sorprende la muerte sin que hubiera dispuesto respecto de ellos, pasan en forma inmediata al pater familias, sin que sean objeto de sucesión ab intestato.

3. Peculio cuasicastrense

Se origina por iniciativa del emperador Constantino en el año 320. Está constituido por los bienes que el hijo adquiere por sueldos y retribuciones relacionadas con sus funciones en el palacio imperial, y más tarde por los que percibe en el ejercicio de la función pública, las profesiones liberales, la carrera eclesiástica y las donaciones del emperador o la emperatriz⁽⁶⁸⁾. Este tipo de peculio tiene un régimen jurídico similar al anterior.

FRANJA

4. Peculio bona materna o adventicia

Surge en el año 319, también inspirado por Constantino, quien dispone exclusivamente para los hijos la reserva de los bienes heredados de la madre, prohibiéndole al padre el derecho de enajenarlos según su voluntad. Recién con Justiniano triunfa el concepto de que la propiedad corresponde al hijo, teniéndose al padre por un simple administrador y usufructuario⁽⁶⁹⁾. A partir de este peculio se amplía la capacidad del filius familias, ya que no sólo recibe herencias, legados y donaciones nupciales dispuestos por la madre, sino que también incluye los bienes recibidos de ascendientes por vía materna. Esta evolución es plasmada finalmente por Justiniano, quien cambia el principio original, otorgando al hijo la plena facultad de disposición sobre todos los bienes que adquiere por cualquier modo y procedencia, restándole al padre tan sólo la facultad de administración y disfrute. Este nuevo sistema, implantado definitivamente por Justiniano, presenta dos excepciones: a) cuando se trata de bienes adquiridos con dinero, o similar equivalencia, perteneciente al padre; b) cuando se trata de bienes entregados por un tercero con motivo de gratitud o consideración al padre. Para estos dos supuestos se continúa aplicando el sistema anterior. Sin embargo, la principal consecuencia de este nuevo régimen patrimonial surgido a través del peculio bona materna, radica en que deja de ser un peculio en el sentido antiguo, para convertirse en un verdadero patrimonio, y, como consecuencia de ello, al producirse la muerte del hijo, los bienes no vuelven al padre, debiéndose abrir la correspondiente sucesión testamentaria o ab intestato para otorgarle su posesión a los herederos del hijo.

IX. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EMERGENTES DE LA PATRIA POTESTAD

El régimen patrimonial emergente del ejercicio de la patria potestas da lugar a las siguientes consecuencias jurídicas: 1. El pater familias es el único titular de derechos reales y obligaciones. 2. El hijo no tiene facultades de disposición o gravamen, sino sólo las relativas al uso y goce, salvo que el negocio llevado a cabo sirva para que el pater familias adquiera derechos de propiedad u obligaciones, o en aquellos casos en que el propio hijo quede obligado como deudor. De esto

se infiere que el hijo es un meroinstrumento de adquisición del pater, ya que de éste son las cosas, derechos y obligaciones que se obtienen por actos de los hijos. 3. El padre no es responsable por las deudas contraídas por el hijo, quedando el filius civilmente obligado respecto de ellas.

Estos principios surgen del primitivo régimen romano por aplicación del derecho civil (ius civile), pero posteriormente, a la vez que evoluciona el sistema patrimonial de peculios, la injusta situación del hijo lentamente se revierte hasta quedar totalmente paliada. Como consecuencia de esta evolución, surge un nuevo régimen patrimonial, que importa otro tipo de régimen jurídico; así tenemos: a. Se le otorga al pater responsabilidad por las deudas contraídas por el hijo, aunque con algunas limitaciones. Esto se alcanza mediante las llamadas acciones adiecticiae qualitates creadas por el pretor. b. Se le concede al hijo cada vez más la posibilidad de ser titular de derechos patrimoniales. El peculio bona adventicia o bona materna es prueba de ello.

X. LAS ACCIONES PRETORIANAS DE EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD AL PADRE DE FAMILIA (ACCIONES ADIECTICIAE QUALITATES)

Estas acciones son producto de la jurisprudencia romana a través de la actividad del pretor. Tienen como objetivo solucionar el grave déficit existente en materia de responsabilidad debido a que, con la intensificación de la vida romana, es habitual que el "jefe de familia" destine parte de su patrimonio mediante peculio a favor de un hijo o de un esclavo para que lleven a cabo determinada actividad. Este sistema no presenta dificultad alguna para el caso en que se produzcan ganancias, ya que éstas benefician directamente al pater. Los inconvenientes comienzan a surgir en el caso de deudas, especialmente si la actividad no funciona, convirtiéndose en muchos casos el responsable del peculio, hijo o esclavo, en un fallido. En este caso, la responsabilidad del pateres nula y los acreedores no pueden accionar contra éste. Por tal motivo, es precisamente a través de las acciones adiecticiae qualitates que los pretores comienzan lentamente, pero sin pausa, a extender la responsabilidad al pater.

Las principales acciones, entre otras, son las siguientes⁽⁷⁰⁾:

1. Actio in rem verso. Tiene lugar cuando el pater constituye un peculio a favor del hijo o de un esclavo para que lleven a cabo una actividad. En caso de fracaso, los acreedores accionan contra el pater familias hasta la medida de las ganancias, que incrementan su patrimonio las deudas contraídas por el filius o el esclavo. Se trata de una "acción procesal" con dos condenas: una para el pater, llamada "de peculio", que lo hace responsable por las deudas contraídas, y otra, denominada in rem verso, que determina su responsabilidad en la medida del enriquecimiento patrimonial que experimenta.
2. Actio quod iussi. Se otorga a favor de los acreedores cuando el hijo o el esclavo contratan con un tercero con el consentimiento del pater. Por medio de ella, este último responde por la totalidad de la deuda.
3. Actio exercitoria. Tiene lugar en los casos en que el pater es naviero o armador de buque y coloca al frente de la nave como capitán (magister navis) a un hijo o a un esclavo, haciéndolo responsable al primero ante los acreedores por las obligaciones contraídas por éstos en uso de sus funciones.
4. Actio de peculio. Se aplica en los casos en que el pater le entrega al hijo o al esclavo una parte de su patrimonio para que lo administre. Por esta acción los acreedores pueden ejecutar su crédito hasta donde alcance el monto de la constitución del peculio, previa deducción de la suma que el pater invierte para ello. En este caso, pese a la extensión de la responsabilidad al pater, se lo beneficia como un acreedor privilegiado.
5. Actio tributaria. Esta acción nace como una evolución de la acción anterior, dado que se comienza a aplicar también cuando el pater constituye a favor del hijo o de un esclavo un peculio. Como se indicó, el pater tiene el privilegio sobre los demás acreedores, ya que está facultado a retirar lo suyo ante cualquier eventualidad. Pero el justo criterio de los juristas romanos determina que este privilegio queda sin efecto cuando el hijo o el esclavo destinan el peculio para ejercer el comercio con el consentimiento del pater. En este supuesto, y por intermedio de la actio tributaria, se realiza una especie de "concurso de acreedores", en el cual todos cobran a "prorrata", incluido el pater, por el crédito invertido en la constitución del peculio.
6. Actio institoria. Se ejerce en los supuestos en que el pater coloca al hijo o a un esclavo al frente de un comercio o industria (institor). Esta acción ejercida por los acreedores hace responsable al pater por las obligaciones contraídas por aquéllos.

XI. EL INGRESO A LA FAMILIA ROMANA⁽⁷¹⁾

Se ingresa a la familia romana por nacimiento o por un acto jurídico (adopción).

El nacimiento es el modo natural por el que se ingresa a la familia. Se hace miembro el procreado en justas nupcias por individuo varón perteneciente a la familia⁽⁷²⁾. El hijo concebido en justas nupcias es "justo" (iustus). Se considera así al nacido después de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos de su disolución⁽⁷³⁾. Esta presunción luego pasa a las legislaciones modernas, aunque admitiendo prueba en contrario⁽⁷⁴⁾. El esposo puede reconocer como hijo al nacido antes de los ciento ochenta días y no hacerlo después, alegando ausencia, enfermedad u otra causa⁽⁷⁵⁾. Los hijos nacidos fuera del matrimonio reciben el nombre de "naturales" (época justinianeana), cuando nacen de un concubinato, y "espurios" (spurii) cuando nacen de uniones no estables.

La adopción es el acto jurídico en virtud del cual un extraño ingresa como hijo en una familia, sometiéndose a la patria potestas del pater en calidad de filius familias. Esta sumisión es inmediata cuando se trata de un hijo, o mediata en el caso del nieto. Por su parte, según el adoptado tenga la calidad de aliena iuris o sui iuris, se distinguen dos formas distintas de adopción: por un lado, la "adopción propiamente dicha" (adoptio) y, por el otro, la "adrogación" (adrogatio).

1. La adopción (adoptio)

La adopción (adoptio) es una institución jurídica muy arraigada en Roma. Presenta dos etapas distintas en su evolución, según se la estudie en los períodos: a) antiguo y clásico, y b) justiniano.

a) En el derecho antiguo y clásico, el padre que vende tres veces al hijo pierde la patria potestas sobre él, ocasionando su emancipación. Este principio, vigente desde la ley de las XII Tablas⁽⁷⁶⁾, comienza a aplicarse a manera de castigo para evitar abusos cometidos por los "padres de familias". Pero se valen de él los juristas romanos para fundamentar el procedimiento de la adopción mediante una ficción legal.

Por cierto, siendo el derecho antiguo un derecho formal y absolutamente rígido, la adoptio está rodeada de una serie de formalidades que deben cumplirse inexorablemente para considerarla consumada. Éstas se llevan a cabo ante el magistrado y en dos etapas. En la primera, el adoptado (aliena iuris) es liberado de la patria potestas del pater originario a través de la triple venta ficticia; y en la segunda, mediante la in iure cesio, el nuevo pater familias (adoptante) simula reivindicar su derecho de patria potestas sobre el adoptado, como si éste le perteneciera con anterioridad. En otras palabras, durante el primer tramo, el padre originario vende a su hijo por "dos veces" consecutivas al adoptante, quien en ambas circunstancias lo remite (in mancipatio) a su padre natural. Pero a la "tercera vez", en lugar de que el padre natural lo vuelva a vender al adoptante, con lo cual el hijo queda definitivamente emancipado según la ley de las XII Tablas, el adoptante interpone la in iure cesio, simulando un juicio ante el magistrado, reclamando la patria potestas sobre el adoptado como si le perteneciera figurativamente con anterioridad. Ante ello, el padre natural no se opone, quedando el acto consumado y la adopción concretada. Este sistema se aplica en aquellos casos en que se trata de la adopción de un hijo varón. En los casos de una mujer o de un nieto, supuestos no contemplados por la ley de las XII Tablas, las formalidades se simplifican notoriamente, pues basta una sola venta del padre natural seguida de la acción ante el magistrado.

b) Posteriormente, en el derecho justiniano, la adopción se realiza directamente ante el magistrado, suprimiéndose el paso previo de la triple venta y la mancipación⁽⁷⁷⁾. Simplemente acuden ante el magistrado los interesados, es decir, el padre natural, el futuro adoptado y el adoptante, dándose forma al acto.

1.1. Los requisitos de la adopción

Durante el período antiguo y clásico es primordial el consentimiento del pater familias del adoptado y el del nuevo adoptante. No importa, en principio, la voluntad del adoptado; luego, basta solamente con que éste no se oponga.

En el caso de que un pater adopte a una persona como nieto y lo asigne a uno de sus hijos, se exige que este último otorgue su consentimiento, porque no parece justo, señala la jurisprudencia romana, que al hijo se le imponga un extraño sin que preste su conformidad. Si, por el contrario, el pater dispone la entrega en adopción de un nieto suyo, no se exige el consentimiento del padre de este último⁽⁷⁸⁾.

El adoptante tiene que ser capaz para adoptar, es decir, debe ser sui iuris. Quedan exceptuados para adoptar los tutores y curadores respecto de sus pupilos mientras éstos sean menores de 25 años, con el fin de evitar que la adopción tenga como propósito oculto soslayar la responsabilidad del tutor o del curador en la rendición de cuentas por la gestión⁽⁷⁹⁾.

Las mujeres tampoco están capacitadas para adoptar, dado que no poseen la patria potestas sobre sus hijos. Sin embargo, las mujeres pueden ser dadas en adopción por el pater familias. Más tarde, y en forma excepcional, se le concede a la mujer la posibilidad de adoptar por rescripto imperial cuando ha perdido a sus propios hijos, a modo de consuelo. Pero esta adopción no le otorga la patria potestas sobre el adoptado, sino que sólo le concede los derechos hereditarios, estableciendo un parentesco ficticio⁽⁸⁰⁾.

También a partir de Justiniano se prohíbe a los padres el derecho de adoptar a sus hijos naturales, puesto que para ello tienen la institución de la legitimación⁽⁸¹⁾. Por su parte, no pueden adoptar quienes se encuentren impedidos de engendrar (castratii).

Los menores de 18 años tampoco pueden hacerlo, ya que es requisito para la adopción que entre el adoptante y el adoptado mediara una diferencia de edad mínima de dieciocho años, con el fin de preservar el principio basado en la imitación de la naturaleza en la relación paterno filial. De tal modo se conserva la autoridad del padre adoptivo sobre el adoptado⁽⁸²⁾.

1.2. Los efectos de la adopción

El adoptado, como consecuencia de la adopción, experimenta una "disminución de cabeza mínima" (capitis deminutio minima), pues pierde el parentesco de agnación con su familia natural y con ello los derechos de sucesión ab intestato, y pasa a formar parte de la familia del adoptante, quien adquiere sobre el adoptado la patria potestas⁽⁸³⁾.

Ahora bien, si el nuevo padre (adoptante) lo emancipa, el adoptado queda totalmente desamparado, puesto que ha roto su vínculo agnático con la familia de origen. Por ello Justiniano decide reparar la injusticia, diferenciando expresamente dos casos: 1º) que el adoptante sea un extraño (extraneus) o sea una persona que no es ascendiente del adoptado; 2º) que el adoptante no sea un extraño sino, por el contrario, un ascendiente del adoptado, v.gr., ascendiente materno.

En el primer supuesto (extraneus), el adoptante no adquiere la patria potestas sobre el adoptado, es decir que éste no sale de su primitiva familia y adquiere tan sólo derecho a la sucesión ab intestato del adoptante. Ello se llama "adopción menos plena" (adoptio minus plena). Mediante la reparación propuesta por Justiniano se evita la injusta situación planteada ante el supuesto de que el adoptado sea emancipado o desheredado por su padre adoptivo, pues de tal modo el adoptado permanece siempre bajo la potestad de su padre natural, y eventualmente puede reclamar sus derechos hereditarios derivados de la muerte de éste o del resto de su familia natural. Esto último, además de los derechos hereditarios en la sucesión ab intestato del padre adoptivo⁽⁸⁴⁾.

El segundo caso, denominado "adopción plena" (adoptio plena), se produce cuando la adopción se lleva a cabo por un ascendiente natural. Entonces la adopción conserva sus efectos originarios,

ya que el adoptado se desliga de la familia natural y pasa a la familia del padre adoptivo, pero sus derechos están protegidos porque, en caso de emancipación posterior, puede concurrir por su vínculo de sangre a la sucesión del adoptante⁽⁸⁵⁾.

2. La adrogación (adrogatio)

La adrogatio consiste en la absorción de una familia por otra. Es una de las especies de la adopción por la cual un sui iuris es adoptado por otro sui iuris. Es muy probable que se trate de la forma de adopción más antigua conocida en Roma, en razón de que prácticamente su origen se confunde con la fundación misma de la ciudad debido a las formalidades y características primitivas que la rodean. Esto es así por cuanto el origen de la "ciudad-estado" (civitas) se encuentra profundamente ligado con las gens y familias primitivas. Precisamente, estas solemnidades especiales son exigidas para preservar las importantes consecuencias que produce la desaparición del grupo familiar del adoptado, incluido su culto doméstico. Por ello, en ella participan los comicios (Estado) y los pontífices (religión). Estas formalidades varían de acuerdo con la evolución histórica y pueden distinguirse tres épocas.

En la primera, es importante la función del Colegio de los Pontífices en el acto, puesto que le corresponde estudiar el proyecto de la adrogación para comprobar si se cumplen los requisitos de la edad, si no se trata de una especulación pecuniaria, y si es necesaria para perpetuar una familia. De ello se infiere que la participación del Colegio de los Pontífices es fundamental. El paso siguiente, una vez evaluado el proyecto, es el sometimiento de este último a la voluntad de los comicios curiados para su aprobación. Es necesario formular tres preguntas (rogationes) por parte del presidente de los comicios. Probablemente el nombre de la institución se debe al término rogaciones o rogatios, aunque no deja de ser una presunción, debido a la falta de datos fehacientes al respecto. Las rogaciones son dirigidas al adrogante, al adrogado, y al pueblo (comicios), en los siguientes términos: Al arrogante (adoptante) se le pregunta: ¿Quieres tener al adrogado por "hijo legítimo" (iustus filius)?; al adrogado (adoptado) se le requiere: ¿Consientes en que el adrogante adquiera sobre ti la patria potestas?; al pueblo, representado por los comicios curiados, se lo interroga para que consagre la voluntad otorgada por las partes que intervienen en el acto⁽⁸⁶⁾. Este proceso va acompañado por otro, en el cual se desvincula al adrogado del culto privado de la familia del cual es Supremo Sacerdote (detestatio sacrorum).

En una segunda época, cuando los comicios curiados comienzan a perder importancia, su presencia en el acto es asumida por treinta lictores (agentes del Estado) que simbolizan a las antiguas curias romanas. Entonces resulta evidente que sólo resulta decisiva la voluntad de los pontífices. Incluso la presidencia de la asamblea, representada formalmente por los lictores, la ejerce el Gran Pontífice, quien decide por sí sólo la adrogación.

Finalmente, durante el Principado, la voluntad del Príncipe comienza a imponerse, sustituyendo lentamente a los pontífices y la adrogación se lleva a cabo mediante "rescripto imperial"⁽⁸⁷⁾.

En las dos primeras etapas mencionadas, la adrogación sólo puede ser llevada a cabo dentro de la ciudad de Roma, siempre que se cumpla con las formalidades exigidas. También se encuentran excluidos de la adrogación los menores impúberes y las mujeres⁽⁸⁸⁾.

Por su parte, Antonino Pío permite que se adrogue a los impúberes mediante rescripto imperial, pero antes debe llevarse a cabo una exhaustiva investigación para determinar que la adrogación no sea justamente propiciada por el tutor del menor impúber para liberarse de la tutela.

Posteriormente, con la finalidad de proteger mejor los intereses del menor impúber y de sus herederos, se ordena cumplir las siguientes garantías: a) el adrogante debe prometer y garantizar la devolución de los bienes del adrogado si éste muere impúber⁽⁸⁹⁾; b) para el caso en que el adrogado alcanza la pubertad y comprueba que no le conviene la adrogación, puede efectuar gestiones ante el magistrado para romper con ella; c) si el adrogado es emancipado luego por el adrogante sin ningún motivo valedero, este último tiene que devolverle el patrimonio, ya que es muy común que el adrogante lo acepte con sus bienes y después lo emancipe, liberándose de él, pero quedándose con sus bienes, consumando un injusto despojo; d) se le concede al adrogado el derecho de percibir la cuarta parte de la sucesión del arrogante (quarta antoniana).

2.1. Los requisitos de la adrogación

Para que la adrogación se lleve a cabo es necesario cumplir con los requisitos generales exigidos para la adopción, esto es, capacidad del adrogante para adoptar; consentimiento de las partes; diferencia mínima de dieciocho años de edad entre adrogante y adrogado. Además, en modo particular se añade durante los primeros tiempos que los Pontífices deben establecer que la adrogación tiene justa causa y favorece al adrogado. Por tal razón se añade como circunstancias inconvenientes para la adrogación, a saber, que una persona empobrecida quiera adoptar a una persona rica, salvo si consta que este último no es pródigo, pero igualmente tiene que dar fianza al respecto⁽⁹⁰⁾. También se considera causa inconveniente que el tutor quiera adrogar a su pupilo, o un padre a un extraño, con la intención de perjudicar a sus hijos naturales o adoptivos⁽⁹¹⁾. Por demás, se exige que el adrogante, además de ser dieciocho años mayor que el adrogado, tenga al momento del acto la edad de 60 años como mínimo, ello para no apartar a los ciudadanos del matrimonio y de la procreación natural. Es decir, la edad a partir de la cual las "leyes caducarias de Augusto" consideran que el hombre pierde la aptitud para procrear. También se requiere que no tenga hijos nacidos de justas nupcias (ex iustis nuptiis), ni tampoco hijos de una anterior adrogación.

2.2. Los efectos de la adrogación

La adrogación produce los siguientes efectos: a) El adrogado cae bajo la patria potestad del adrogante con la misma calidad de un descendiente nacido en justas nupcias. Es decir que el adrogado padece una "disminución mínima de cabeza" (capitis deminutio minima) y deja de ser sui iuris para convertirse en aliena iuris. Tampoco el adrogado continúa siendo jefe de su propia familia, sino que se somete a la potestas del adrogante, junto con todo su núcleo familiar, perdiendo los derechos de agnación inherentes a su familia original. b) El adrogado toma el nombre de la gens y de la familia del adrogante, adquiriendo también su culto (sacra familiae). c) Los bienes del adrogado, ya sean materiales (propiedades) e inmateriales (créditos) pasan a pertenecer al adrogante en su totalidad, originándose lo que se conoce como sucesión universal inter vivos. Sólo quedan excluidos las deudas del adrogado y los derechos constituidos por éste en favor de terceros contraídos con anterioridad al acto. Las fuentes indican que para preservar estos derechos se dota a los interesados de "acciones especiales" que autorizan el cobro de los créditos⁽⁹²⁾. Luego Justiniano dispone con buen tino que el adrogado continúe teniendo la "nuda propiedad" sobre los bienes y el adrogante el usufructo.

3. La legitimación

Es la forma por la cual se adquiere la legalidad de los hijos habidos fuera del matrimonio. Se refiere a los hijos nacidos de un concubinato. Este último, en Roma, no es una unión transitoria, sino estable. El concubinato es para el derecho romano una verdadera relación de convivencia, a la cual le falta solamente la intención de contraer matrimonio (affectio maritales), requisito fundamental de esta última institución. La legitimación tiene auge por la influencia del cristianismo cuando el parentesco de sangre (cognaticio) comienza a prevalecer sobre el civil (agnaticio). Ahora bien, sólo pueden ser legitimados aquellos que son fruto de una unión de concubinato, y no de cualquier unión extramatrimonial. Estos hijos toman el nombre de naturales. Existen en Roma los siguientes tres modos para legitimar a los hijos naturales:

a) Por matrimonio posterior de los padres del legitimado (subsequens matrimonium). Exige que ambos contrayentes vivan en concubinato, es decir, que estuviesen en condiciones de contraer matrimonio al tiempo de la concepción del legitimado. Que instrumenten el acto de legitimación mediante un "contrato nupcial" en el que se dispone una dote con el fin de formalizar la existencia de

la unión (*instrumentum dotale*)⁽⁹³⁾. Que el legitimado no se oponga al acto de legitimación⁽⁹⁴⁾, puesto que como hijo natural es de por sí *sui iuris*, y al ser legitimado se convierte en *aliena iuris*, sufriendo una *capitis deminutio minima*. Si es incapaz para manifestar su oposición, tiene reservado el derecho para efectuarla hasta el momento en que recobre su capacidad⁽⁹⁵⁾.

b) Por voluntad imperial (*rescripto imperial*). Esta modalidad se debe a Justiniano, que la introduce en las Novelas. Según las fuentes, tiene lugar cuando no es posible la legitimación mediante el primer modo por existir impedimentos legales entre los padres para concretar matrimonio. Entonces, es la voluntad del emperador, quien suple el casamiento, con idénticos efectos legales que el anterior, ordenando la legitimación de los hijos habidos en concubinato, haciéndolos ingresar a la familia agnaticia del pater, y sometiéndolos a su potestas con igual rango que los hijos legítimos. La petición al emperador puede ser solicitada directamente por el padre o mediante testamento. También se le concede el derecho de pedir el favor del emperador a los propios interesados (hijos) cuando el padre los instituye herederos como si fueran hijos legítimos, debido a que con su actitud demuestra la intención de legitimarlos.

c) Por razones fiscales (*oblationem curiae*)⁽⁹⁶⁾. Esta institución persigue fines fiscales. Las curias en el período imperial son una clase social que por derecho propio forma parte administrativa de los municipios (una especie de senado) y nada tienen que ver con las antiguas asambleas populares del tiempo monárquico y republicano. Sus integrantes se conocen como *decuriones* y se encuentran asimilados a la clase de los senadores. Precisamente en este período los funcionarios imperiales destinados a percibir impuestos son elegidos entre los *decuriones*, y se les imputa plena responsabilidad en los casos de contribuyentes morosos o insolventes. Ello motiva que nadie quiera ejercer tales cargos, con los consabidos perjuicios al fisco. Los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, preocupados por esta situación, buscan solucionarla intentando favorecer a estas curias o senados de las ciudades a través de la concesión del derecho a los progenitores de legitimar a sus hijos varones naturales mediante la donación de un patrimonio que sea suficiente como para admitirlos dentro de la categoría social de los *decuriones*; y a sus hijas, mediante la constitución de una dote que le permita al esposo ser considerado elegible para tales funciones. Posteriormente, Justiniano confirma esta forma de legitimar. Este acto puede llevarse a cabo incluso mediante testamento. Si bien a los fines fiscales esta modalidad soluciona el problema de la percepción de impuestos, es necesario dejar en claro que en cuanto a sus consecuencias jurídicas, guarda disímiles efectos respecto de las formas anteriormente descriptas. El lazo de parentesco derivado de la legitimación está solamente dado entre padre e hijo, y ante el resto de la familia el legitimado continúa siendo un extraño.

4. La extinción de la patria potestas. La emancipación⁽⁹⁷⁾

En Roma existen distintas causas que ponen fin a la patria potestas. Éstas deben ser agrupadas del siguiente modo: por un lado, aquellas provenientes de acontecimientos fortuitos y, por otro, las que surgen de actos solemnes.

Entre las derivadas de acontecimientos fortuitos se encuentran las siguientes: a) muerte, pérdida de ciudadanía o reducción a esclavitud del pater familias; b) elevación del hijo o la hija a determinadas dignidades políticas o religiosas; c) caída en esclavitud del hijo; d) matrimonio de la hija celebrado por la *conventio in manu*.

El análisis de estas causales no ofrece mayores inconvenientes. Veamos.

La muerte del pater familias ocasiona de puro derecho la disolución del vínculo de autoridad, convirtiéndose todos los hijos varones bajo su potestad en *sui iuris*. En aquellos casos en que el pater familias pierde su condición de ciudadano (*capitis deminutio media*) o su libertad (*capitis deminutio maxima*) también se disuelve de puro derecho (*ipso iure*) el poder de autoridad sobre su familia. Asimismo, parece justo que cuando el hijo o la hija alcancen altos cargos (v.gr., flamen diales, vestal, etc. —derecho antiguo—; cónsul, *praefectus praetorii*, *praefectus urbi*, etc. —Imperio—; obispo —cristianismo—), se liberen del poder del pater y sean considerados *sui iuris*. Finalmente, la caída en esclavitud del hijo acarrea la pérdida de sus derechos y, por ende, también los inherentes a la patria potestas. Además, cuando la hija es desposada a través de la *conventio in manu*, rompe los lazos con la familia agnaticia, pasando a depender de la potestas del pater, a quien está sometido su esposo.

Entre los actos solemnes que ponen fin a la patria potestas se cuentan: a) la entrega en adopción; b) la emancipación.

La adopción, como se ha visto, es uno de los modos solemnes que ponen fin a la patria potestas. En cuanto a la emancipación, debe ser considerada a lo largo de su devenir histórico. El más remoto antecedente se encuentra en la ley de las XII Tablas, en la cual se decreta la pérdida de la patria potestas respecto del pater familias que vende tres veces consecutivas a su hijo⁽⁹⁸⁾. Éste es un castigo ordenado por la ley para frenar los abusos cometidos por los padres de familias respecto de sus hijos, y los juristas romanos se valen de él para crear "ficticiamente" un modo de emancipar a los hijos. De tal modo, el padre que quiere emancipar a su hijo se pone de acuerdo con otro pater familias de su amistad y lleva a cabo la emancipación mediante la venta ficticia del hijo. El procedimiento consiste en que el padre vende ante el magistrado ficticiamente a su hijo mediante la mancipatio a otro pater amigo. Éste, de acuerdo con lo convenido, lo libera en forma inmediata, cayendo nuevamente en forma automática el hijo en poder del pater originario, quien nuevamente lo vuelve a ceder a su amigo. La operación se repite tres veces y al cabo de ellas el hijo queda finalmente emancipado por la citada disposición de la ley de las XII Tablas. Esta modalidad se lleva a cabo durante la época antigua y clásica. Para los casos de las hijas y los nietos basta una sola venta para emanciparlos. Como se aprecia, el término "emancipación" deriva del antiguo modo de contratación mancipatio. Posteriormente, en la época imperial, durante el siglo VI, aparece en Oriente otro modo, llamado "Emancipación Anastasiana" (Emancipatio Anastasiana), denominada así en honor del emperador Anastasio, quien dispone que la emancipación del filius también se puede llevar cabo mediante rescripto imperial para los casos en que el hijo se encuentre ausente. Justiniano, por su parte, decreta como forma única la comparecencia ante el magistrado declarando la voluntad de emancipar al hijo.

5. El fin de la persona física

La persona física llega a su fin mediante la muerte. Este hecho biológico apareja distintas consecuencias de carácter sucesorio, familiar, patrimonial, etc. Lo correcto, en sentido metodológico, es que ellas se estudien con detenimiento en el momento en que se profundice el derecho sucesorio, pero, no obstante ello, indicaré las consecuencias más importantes y notorias a efectos de que se tenga noción más o menos acabada.

En primer lugar, ante la muerte del sujeto de derecho se abre su sucesión. Si éste ha dejado testamento, cosa habitual en la época primitiva y clásica, dado que lo excepcional es morir intestado, se debe cumplir sus dictados, siempre que éstos sean válidos. Para el caso de que no lo sean o no exista testamento, se abre la sucesión intestada (ab intestado).

A nivel familiar, en el derecho primitivo, todos los hijos varones pasan a ser cabeza de su propia familia. Cada uno de ellos deja de ser aliena iuris para erigirse en sui iuris. El acervo hereditario se divide entre ellos. Si son mayores (25 años) y sanos física y mentalmente, ejercen su capacidad plenamente; de lo contrario se les nombra curador.

Éstas son las consecuencias más comunes y elementales que trae consigo el deceso del jefe de familias, pero debe señalarse también que su muerte acarrea la extinción de todo acto jurídico de carácter personal, tales como matrimonio, tutela, curatela, mandato, etc.

Capítulo XI - Las Instituciones de Guardaduría de los Incapaces. La Tutela y la Curatela

CAPÍTULO XI - LAS INSTITUCIONES DE GUARDADURÍA DE LOS INCAPACES. LA TUTELA Y LA CURATELA⁽¹⁾

En Roma se considera incapaz de hecho por razón de la edad a los sui iuris impúberes. Precisamente, la tutela tiene origen en la necesidad de suplir esta incapacidad. Similar postura se adopta para la mujer sui iuris, sin distinción de edad, aunque tan sólo durante el derecho antiguo y clásico, dotándolas de tutela perpetua bajo el argumento de que no pueden conducirse por sí solas debido a su ligereza de espíritu⁽²⁾. El patrimonio de la persona incapaz se coloca bajo la protección de otro sui iuris denominado tutor.

La curatela, por su parte, tiene origen en conceptos análogos, pero se refiere en principio a la incapacidad que deriva de la afectación del estado mental del individuo, v.gr., la locura, luego se amplía su aplicación a otros casos, como el de los pródigos y los menores púberes.

Ambas instituciones tienen origen remoto y representan el régimen tuitivo de los incapaces de hecho. Mientras la tutela se destina a la protección de los menores impúberes y mujeres, la curatela se ocupa de velar por los intereses de las personas por nacer (nasciturus), los pródigos, los menores púberes menores de 25 años, los dementes y los débiles mentales.

No se encuentra en las fuentes la razón por la cual ambas se diferencian. Se trata, por supuesto, del régimen de protección de los incapaces para obrar, a quienes necesariamente, por ser titulares de derechos, se debe proteger. En unos casos se designan tutores y en otros curadores. Desde antiguo se intenta diferenciar la cuestión señalándose que el tutor está destinado a velar por la protección de la persona del incapaz y el curador por el patrimonio de éste⁽³⁾, pero esto no es tan así en Roma, por cuanto ambas instituciones se entrecruzan en su finalidad, protegiendo en determinados casos a la persona y en otros al patrimonio, o incluso a los dos al mismo tiempo. La diferencia se funda, al parecer, en razones más generales u homogéneas, como la edad y el sexo en caso de la tutela, mientras que la curatela obedece a distintas situaciones puntuales o accidentales, v.gr., el caso de los dementes, los pródigos, los débiles mentales y las personas por nacer. Probablemente ambas instituciones tienen un mismo origen, siendo la tutela la destinada a cubrir las incapacidades propias de la falta del adecuado discernimiento. Al mismo tiempo, quedan fuera del sistema los otros incapaces que no pueden ser protegidos mediante la tutela. Posiblemente estas incapacidades de obrar, que no resultan pasibles de ser contempladas en razón de parámetros generales como la edad y el sexo, necesitaron la protección de otra institución, la curatela, que si bien tiene similitud con la anterior, también tiene rasgos que la diferencian.

En la práctica cotidiana, el tutor asiste al pupilo para subsanar la deficiencia de su insuficiente personalidad mediante la gestión o la auctoritas, según el caso, mientras que el curador actúa solamente por la gestión para administrar el patrimonio del incapaz.

I. LA TUTELA

Corresponde al jurista Servio, citado por Paulo, la primera definición más acabada sobre la tutela dentro de la jurisprudencia romana⁽⁴⁾. Se refiere a ella como "la fuerza y la potestad sobre una cabeza libre, dadas y permitidas por el derecho civil, para proteger a aquel que por su edad no puede defenderse"⁽⁵⁾. Dicho en otras palabras, se trata del ejercicio por parte del tutor del poder y la potestad sobre una persona menor sui iuris para protegerla, en razón de que no puede valerse por sí misma a causa de la edad.

Destaco primordialmente que la tutela surge originariamente en el derecho romano para los menores impúberes, es decir, hasta que alcanzan la aptitud biológica para procrear, estimada esta última a los 14 años. De aquí en más, y hasta que arribe a la mayoría de edad (25 años), se suple la tutela por una curatela, que consiste en un régimen menos riguroso que el anterior.

La razón fundamental de la tutela radica, en principio, en la necesidad de proteger los intereses del menor impúber, o sea su patrimonio. No debe olvidarse el concepto de la primitiva familia romana, caracterizado por la idea de una verdadera "corporación de intereses", tanto de personas como de bienes. Proteger al "jefe de familia" es proteger a la familia misma. La cabeza visible de

ésta debe gobernar perfectamente a sus miembros y al patrimonio, que en definitiva es el de todos. Por lo tanto, si el pater familias no se encuentra por su edad en condiciones de hacerlo, es necesario suplir su incapacidad nombrándole un tutor⁽⁶⁾. Por esto, originalmente, el nombramiento del tutor se funda más en razón de protección de la familia que del incapaz en sí mismo⁽⁷⁾. Luego el criterio varía, cediendo a la idea de la protección del interés del menor, perfilándose el concepto moderno de la institución⁽⁸⁾.

La tutela en tiempos primitivos tiene gran importancia, dado que su ejercicio implica controlar más el destino de la familia que la representación de la persona del incapaz, debido a que el tutor se comporta como el verdadero jefe de la misma. Por tal motivo, el ejercicio de la tutela se considera una función pública, lo que significa que es irrenunciable si se cumple con los requisitos exigidos para la designación, aunque se admiten excusas que sólo puede esgrimir el designado.

II. LOS REQUISITOS PARA SER DESIGNADO TUTOR

En principio no se solicitan condiciones especiales para ser designado tutor, dado que todo aquel que es considerado sujeto de derecho (por gozar de los tres estados) puede serlo. Con el transcurso del tiempo, estos requisitos se perfeccionan y amplían, aunque esencialmente continúan siendo los mismos. La jurisprudencia romana es meticulosa al respecto, por cuanto el ejercer la tutela implica una actividad ardua, compleja, de importancia extrema, exigiendo dedicación completa e idoneidad suficiente para llevarla a cabo. No debe olvidarse que el tutor, en la práctica, es el "jefe de la familia" en representación del pupilo. Por tal motivo, lentamente se regula cada vez más sobre las exigencias para ser designado tutor. Con el avance del tiempo y el cambio de las costumbres, los requisitos para ser nominado tutor se perfeccionan, exigiéndose que éste debe ser: a) Jefe de familias (sui iuris); b) hombre libre. Va de suyo que una persona esclava no puede ejercer la tutela, pero existe la excepción cuando dicho hombre es nombrado tutor mediante testamento por su amo, puesto que el nominarlo implica su manumisión; empero, si el esclavo nombrado tutor es ajeno, aunque se instrumente la designación por testamento, queda excluido, salvo que el propietario le otorgue la libertad, con lo cual no media impedimento para cumplir con el cargo. c) Ser ciudadano romano. d) Ser varón. A las mujeres les está expresamente vedado ejercer la tutela. Mas luego, en el Bajo Imperio (año 390), este rígido principio comienza a debilitarse cuando se admite que la madre puede ser tutora respecto de sus hijos si a la muerte del padre no existe tutor legítimo o testamentario. Finalmente, en el año 530 se le permite ejercer la tutela a la madre de hijos naturales⁽⁹⁾. e) Ser mayor de 25 años. Este requisito varía fundamentalmente según las épocas. En el período clásico no es impedimento tener menos de dicha edad para ser tutor, pero sí causal de excusa por parte del nombrado. En cambio, durante el Bajo Imperio se exige tenerlos cumplidos⁽¹⁰⁾. f) Ser una persona sana, mental y físicamente⁽¹¹⁾, lo que implica que no pueden ser tutores los insanos, los sordomudos y los ciegos. g) No debe encontrarse ejerciendo funciones de alta responsabilidad o privilegio, v.gr., militares, obispos y monjes⁽¹²⁾. h) No haber tenido enemistad con el padre del pupilo. i) No haber sido excluido expresamente por el padre para ejercer el cargo en el testamento. j) Mantener buena conducta.

III. LA EXCUSACIÓN DE LA TUTELA

La persona designada tutor puede excusarse de aceptar el cargo mediante causa fundada. Se acepta la excusación debido a la suma importancia que tiene el ejercicio de la función. Las causales varían según las épocas y, entre otras, son las siguientes: a) ser tutor o curador de tres pupilos o curados al momento de la designación; b) tener problemas de salud; c) la ignorancia; d) el exilio; e) la pobreza; f) desempeñar determinadas profesiones (médicos, filósofos, gramáticos, etc.); g) vivir muy alejado del pupilo; h) tener una edad mayor de 70 años; i) ser padre de un mínimo de hijos determinados, etc.⁽¹³⁾.

Las distintas causales enunciadas no son producto de una legislación directa, sino que, por el contrario, surgen de casos concretos resueltos por los magistrados, y más tarde por rescriptos imperiales.

IV. LAS DISTINTAS CLASES DE TUTELA

Se encuentran relacionadas principalmente con las distintas formas de designación del tutor; de tal modo, las clases de tutela son: testamentaria, legítima y dativa.

— La tutela testamentaria. Es cuando la designación de tutor es llevada a cabo por el pater familias respecto de su hijo impúber, que a su muerte se convertirá en jefe de familia mediante testamento⁽¹⁴⁾. Tiene origen en las antiguas disposiciones de la ley de las XII Tablas⁽¹⁵⁾.

— La tutela legítima. Es la otorgada por la ley a falta de tutor testamentario. Cuando ello ocurre, no se puede dejar desamparado al menor sui iuris y a todo su grupo familiar; entonces, se aplica el orden sucesorio ab intestato dispuesto por la ley de las XII Tablas. Éste es el orden sucesorio ab intestato más antiguo que se conoce en el derecho romano y dispone que, a falta de tutor testamentario, debe ser designado el "agnado" más próximo del menor impúber, y a falta de éste, se requiere por parentesco a los "gentiles"⁽¹⁶⁾.

— La tutela dativa. Es la dispuesta por el magistrado. Tiene lugar cuando surge la imposibilidad de designar tutor por testamento o mediante el remedio legal del orden sucesorio ab intestato. En estos supuestos se suple la dificultad a través de la voluntad del magistrado, que designa al tutor. La llamada lex Atilia, posiblemente de comienzos de la época clásica, ya que no se conoce su fecha con precisión, es la primera disposición que confiere a los magistrados la facultad de designar tutor a falta de disposición testamentaria o legítima al respecto⁽¹⁷⁾.

V. LAS FUNCIONES DEL TUTOR

Tiene a su cargo dos funciones fundamentales, que hacen a la finalidad de la institución, a saber: la "gestión del negocio" (gestio negotiorum) y la "autorización interpuesta" (auctoritas interpositio). La diferencia entre ambas radica en la edad del pupilo, ya que si es "menor infante" (minor infans) (hasta 7 años), la función del tutor es la gestio. En cambio, si ya es "infante" (infans) (7 a 14 años), el tutor actúa mediante la auctoritas.

— La "gestión del negocio" (gestio negotiorum). El tutor reemplaza al pupilo, quien por su edad no puede valerse en absoluto, dado que es incapaz absoluto de hecho. Comprende la administración directa del patrimonio del pupilo. El tutor actúa por sí solo, sin la presencia o colaboración del pupilo ante su evidente incapacidad de obrar. Consiste en una representación indirecta o impropia, semejante a un "gestor de negocios", puesto que toda adquisición u obligación contraída por el tutor es efectuada a título propio hasta que finaliza la tutela, momento en que los derechos y obligaciones se transmiten al pupilo⁽¹⁸⁾.

— La "autorización interpuesta" (auctoritas interpositio). El tutor completa la insuficiente capacidad de su pupilo, quien está presente en el acto. El tutor aporta su experiencia y le hace saber la conveniencia o no de la operación. La auctoritas se requiere fundamentalmente para todo aquello que implica una disminución del patrimonio del pupilo, pero no se exige cuando se acrecienta dicho patrimonio. El tutor brinda su parecer de acuerdo con la ventaja o perjuicio que el negocio jurídico le puede ocasionar a su pupilo y por lo general se acata su decisión⁽¹⁹⁾.

1. Las facultades y obligaciones del tutor

El tutor centra su actividad fundamentalmente en el patrimonio del pupilo. La educación y el cuidado personal de este último se encuentran a cargo de otra persona, que bien puede ser la madre, otros parientes o un extraño seleccionado para ello. El tutor debe velar por el patrimonio, suministrando los medios para que el pupilo sea bien instruido y cuidado. No debe olvidarse lo expuesto precedentemente, cuando señalé el concepto "corporativo de la familia primitiva romana". Mucha gente depende económicamente del buen funcionamiento de la familia. Una vez nombrado el tutor para subsanar la incapacidad de su titular, resulta necesario que aquél haga las cosas bien a efectos de velar por el bienestar de todo el grupo familiar. Congruentemente, las facultades del tutor son amplias y variadas, ya que su comportamiento es similar al verdadero y legítimo dueño del patrimonio del pupilo. Puede administrar y disponer de las inversiones del capital que posee este último, enajenar los inmuebles, gravarlos, realizar y percibir pagos, etc.⁽²⁰⁾. Más tarde, con el correr del tiempo, las facultades del tutor se van limitando para cercenar su inmenso poder, y salvaguardar el patrimonio del pupilo, debido a que con asiduidad se dilapida por gestiones poco transparentes. Así, diré brevemente que durante el período clásico se le veda al tutor la facultad de efectuar donaciones de importancia, y luego se le prohíbe también efectuar disposiciones y todo tipo de gravámenes sin autorización del magistrado⁽²¹⁾. Durante el gobierno de Claudio se le comienza a exigir al tutor la obligación de prestar caución con el fin de asegurar la conservación de los bienes pupilares y su íntegra restitución al finalizar la tutela⁽²²⁾. Justiniano dispone el debido cuidado respecto de las inversiones de los capitales de los pupilos, dado que el tutor no puede realizarlas según su parecer, sino orientarlo efectivamente hacia la adquisición de propiedades o hacia la colocación de préstamos con interés. También se le exige al tutor, como requisito previo a la aceptación, el juramento de desempeñarse con buena dedicación, como si el patrimonio le perteneciera⁽²³⁾. Finalmente, se le exige al tutor la realización de un completo inventario ante funcionario público respecto de la totalidad del patrimonio pupilar y el depósito en lugar seguro de toda la documentación relacionada con éste. El incumplimiento de esto último presume dolo en su gestión, recayendo sobre él la "tacha de infamia" y la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al pupilo⁽²⁴⁾.

2. La responsabilidad del tutor

Partiendo del principio de que la tutela debe ser ejercida con honradez con el fin de salvaguardar los derechos del pupilo, desde temprano la ley de las XII Tablas dispone dos procedimientos contra aquellos que no se desempeñen correctamente como tutores⁽²⁵⁾.

El primero consiste en lograr la destitución del tutor mediante la "acusación de sospecha" (acusatio suspecti tutoris); y el segundo otorga el ejercicio de la "acción de sustracción de bienes" (actio de rationibus distrahendis) de carácter penal, que sanciona al tutor con la condena a devolver el doble de los bienes sustraídos⁽²⁶⁾. Después, durante la República, los magistrados le conceden al pupilo otra acción más completa denominada "acción de tutela" (actio tutelae), mediante la cual éste puede exigirle al tutor la rendición de cuentas al finalizar su función y la posterior devolución de los bienes con los frutos e intereses percibidos, o los que hubiera dejado de percibir⁽²⁷⁾. También faculta al pupilo a reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la incorrecta gestión del tutor, y a este último a reclamarle al pupilo el reintegro de los gastos que su función le demandara⁽²⁸⁾.

VI. LA TUTELA DE LA MUJER (TUTELA MULIERUM)

Dentro del tema de la tutela en general, es menester ocuparme del caso especial de la tutela de la mujer. En el derecho romano antiguo, la mujer no puede ser sujeto de derecho por disposición del vínculo agnaticio, y, como consecuencia lógica, tampoco cabeza de su propia familia (sui iuris), puesto que de acuerdo con el sentir de la época se la considera incapaz de hecho a causa de su ligereza, la debilidad de su sexo, su ignorancia y la falta de experiencia en los negocios⁽²⁹⁾, y por lo tanto debe estar sujeta a tutela perpetua⁽³⁰⁾.

Tras lo expuesto, el régimen tutelar para la mujer es el siguiente. En principio, hasta el momento en que alcanza la pubertad (12 años), queda sujeta a una tutela similar a la de cualquier menor impúber, asistiéndola su tutor a través de la gestio. Alcanzada la pubertad, la mujer continúa bajo tutela, pero ésta deja de ser la habitual para llamarse, justamente, "tutela de la mujer" (tutela mulierum) y el tutor completa la incapacidad relativa de la mujer para obrar mediante la auctoritas. La condición jurídica de la mujer púber sui iuris es similar a la del "infante mayor" (maior infans), ya que puede llevar a cabo cualquier tipo de acto por sí misma, siempre que no implique una disminución patrimonial. En cuanto al resto de las características de la institución, son similares a las expuestas anteriormente respecto del modo de designación del tutor y sus responsabilidades.

La dureza de la tutela perpetua de la mujer sui iuris (tutela mulierum) desaparece con el tiempo, especialmente con el avance cada vez más pronunciado de la aplicación del vínculo de sangre (cognaticio) en reemplazo del vínculo civil (agnaticio)⁽³¹⁾.

VII. EL FIN DE LA TUTELA DE LOS MENORES

La tutela del menor llega a su fin únicamente en alguno de los tres siguientes supuestos, a saber: el pupilo alcanza la pubertad; muerte del pupilo; disminución de cabeza del pupilo (capitis diminutio). Estudiando cada caso en particular, tenemos:

La pubertad del pupilo pone fin a la tutela, pasando el menor a ser protegido mediante curatela hasta la mayoría de edad (25 años). La muerte del pupilo también da fin a la tutela, abriendo la correspondiente sucesión del menor. La capitis diminutio del menor acaecida en cualquiera de sus formas aparea también la desaparición de la tutela.

Como se puede apreciar, la tutela sólo se extingue por causa del menor, puesto que en definitiva su protección y la de su familia es el verdadero objeto de la institución⁽³²⁾. Sin perjuicio de lo expuesto, puede considerarse la posibilidad de que aquélla finalice a causa del tutor, v.gr., muerte o disminución de cabeza, mal desempeño, etc. Pero es menester dejar en claro que, de continuar la incapacidad del pupilo, la tutela en sí no finaliza, dado que necesariamente habrá de designarse nuevo tutor para garantizar la protección del menor⁽³³⁾.

Por fin, una vez que la tutela se extingue por alguna de las causas indicadas, el tutor está obligado a rendir cuentas de su gestión ante el menor. En esta circunstancia, siendo el menor todavía incapaz desde los 14 a los 25 años, tiene lugar la designación de curador, que debe asistir obligatoriamente al acto. El tutor debe hacer entrega de la propiedad de todos los bienes muebles e inmuebles que hubiera recibido al comienzo de su función bajo inventario por parte de la familia del pupilo. También debe transmitirle todos aquellos bienes que hubiera adquirido con motivo de su gestión, como así también todos los derechos y créditos de los cuales es titular en representación del pupilo.

Por su parte, el pupilo debe reintegrar al tutor o sus sucesores el reembolso de los gastos que ha efectuado en ocasión de la administración de la tutela y cumplir frente a terceros con las obligaciones contraídas por el tutor en interés del menor⁽³⁴⁾.

VIII. LA CURATELA. REQUISITOS PARA SER DENOMINADO CURADOR Y SU RESPONSABILIDAD

Siendo la curatela una institución de guarda de los derechos de los menores e incapaces, lentamente se extienden los mismos requisitos, excepciones, facultades, obligaciones y responsabilidades que alcanzan a los tutores⁽³⁵⁾, por lo que ambos sistemas son similares y todo aquello que he señalado respecto de la tutela se aplica a la curatela.

1. La curatela del demente (cura furiosi)

La curatela del demente (cura furiosi) es la más antigua que se conoce en el derecho romano. Ésta ya se contempla en la ley de las XII Tablas⁽³⁶⁾. Se entiende por demente (furiosi) a aquella persona afectada en su sana razón y discernimiento que lo imposibilita de valerse por sus propios medios. El curador vela o cuida por la persona del insano, a la vez que administra su patrimonio, protegiendo tanto su persona como a este último⁽³⁷⁾. El curador realiza su cometido a través de la gestio negotiorum, reemplazando al insano en la gestión de sus negocios, pero sin descuidar la realización de los medios necesarios que estén a su alcance para procurar su restablecimiento⁽³⁸⁾. Esta institución evoluciona con el tiempo. En la ley de las XII Tablas se la concede a cargo de los parientes agnados más próximos y luego a los gentiles del incapaz⁽³⁹⁾. Más tarde, se permite la curatela dativa otorgada por el pretor durante el período clásico, siendo perfeccionada durante el derecho justiniano al reemplazarse el vínculo civil (agnaticio) por el de sangre (cognaticio).

2. La curatela del pródigo (cura prodigi)

La curatela del pródigo (cura prodigi) es, con la anterior, una de las más antiguas instituciones de guarda del derecho romano, puesto que sus primeros antecedentes se remontan también a las disposiciones de la ley de las XII Tablas.

En Roma se entiende por pródigo a aquel "jefe de familia" que dilapida mediante gastos inútiles y vanos los bienes heredados de sus ascendientes agnaticios, comprometiendo el patrimonio de la familia⁽⁴⁰⁾. Efectivamente, mediante la interdicción se busca la protección del patrimonio de la familia agnaticia, el cual se traspasa de padres a hijos, de generación en generación. Lo importante es preservarlo de una disminución injustificada, ya que a su vez debe ser heredado por sus descendientes. La protección apunta a aquellos "gastos inútiles, vanos y superfluos que comprometen el patrimonio". La conducta irresponsable del pródigo debe ser ameritada por el magistrado, que, de constatar la "manía nociva de dilapidación", debe "interdicar" (interdictio) mediante una declaración formal al efecto. También le corresponde al magistrado levantar la interdicción si el pródigo deja de serlo, demostrando que se ha curado de su hábito peligroso que pone en peligro el acervo familiar. La jurisprudencia del período clásico trabaja sobre el tema, regulando de manera más acabada la institución, hasta que finalmente Antonino Pío dispone que la interdicción por prodigalidad abarca todo tipo de bienes, sin distinción de origen, ya sea testamentario o materno⁽⁴¹⁾. El pródigo sometido a curatela puede realizar cualquier acto que mejore su situación patrimonial, quedando invalidado de efectuar aquellos que disminuyan o comprometan su patrimonio⁽⁴²⁾.

3. A propósito de la situación del pródigo en el Código Civil y la vigencia del derecho romano

Siempre me ha interesado la particular situación del pródigo en el Código Civil, puesto que Vélez Sarsfield originalmente no lo contempla, aunque en sus notas da sobrado fundamento de que conoce perfectamente el instituto a través del derecho romano. Ello originó una "laguna del derecho" que durante mucho tiempo ha sido restañada por la labor de la jurisprudencia, hasta la sanción de la reforma de la ley 17.711, que incorpora expresamente la figura del pródigo⁽⁴³⁾. Entonces he aquí, justamente en el caso del pródigo, un claro ejemplo de una institución que los romanos conocen desde muy antiguo, legislando sobre ella y sus efectos, y que nuestro codificador, siguiendo la política legislativa del momento, suprime. Más tarde surge la necesidad jurídica de cubrir dicha omisión, que genera una "laguna del derecho", y se debe volver al derecho romano, legislando entonces sobre la protección de la prodigalidad.

Lo expuesto es, a mi entender, uno de los tantos ejemplos concretos que reafirman el criterio que sostengo en cuanto a que el "derecho romano es derecho vigente". No se puede interpretar el tema de otro modo, puesto que el propio autor del Código ha dejado de lado el derecho romano omitiendo el instituto, y años después hubo que acudir nuevamente a él para dar solución a una situación que pone en "peligro a la persona y a su familia". El derecho romano se impone, en el caso del pródigo, por cuanto se encuentra vivo y no se puede acallar, y la reforma aludida tan sólo lo ha tenido que encorsetar mediante la necesaria técnica legislativa, pero intrínsecamente no es otra cosa que derecho romano, cualquiera fuese la óptica que se emplee para tratar el tema.

El actual Código Civil y Comercial continúa con la protección del pródigo siguiendo el derecho romano cuando trata el tema de los inhabilitados (art. 48 CCyCN). Es decir, mantiene la posición del derecho romano introducida en el código velezano por la reforma de la ley 17.711, que subsanó en su momento la incomprensible omisión de Vélez en el caso.

4. La curatela del menor de 25 años

No pasa inadvertida para los juristas romanos la particular situación de los menores púberes varones durante el lapso comprendido entre el momento en que se los considera de tal modo (14 años) y aquel en que alcanzan la mayoría de edad (25 años). Los menores adquieren la plenitud de su capacidad a una hora temprana, y tal circunstancia puede ser aprovechada por los inescrupulosos de turno, que se valen de su falta de madurez e inexperiencia para inducirlos en negocios y transacciones que los perjudican. De dicho modo, se protege al menor varón que cumple 14 años hasta que alcanza su mayoría de edad (25 años). La solución no es inmediata, sino que tiene distintas etapas, hasta llegar a la curatela del menor (cura minorum).

En un primer momento rige al respecto la llamada *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*, cuyo origen se puede estimar entre los años 186 y 191 a.C., aproximadamente. A través de ella se aplican distintas sanciones a aquellos que engañen en los negocios a los menores, pero sin invalidar tales actos. Luego el sistema se complementa durante la República con una acción concedida por el pretor al menor, denominada "acción de restitución" (*actio in integrum restitutio*). Esta acción sólo se puede hacer valer una vez alcanzada la mayoría de edad, teniendo un año para su ejercicio, plazo que luego Justiniano eleva a cuatro años⁽⁴⁴⁾. Por esta acción el menor perjudicado solicita la "restitución íntegra del acto" ante el pretor, quien debe verificar que éste hubiera sufrido efectivamente un perjuicio provocado por aquel que se aprovechara de su juventud e inexperiencia, y además que la víctima no tenga a su alcance otro remedio para lograr su reparación. El magistrado entonces declara la necesidad de que las cosas vuelvan a su "estado originario", retrotrayendo íntegramente el acto atacado a su estado anterior. Esta solución propiciada a través de la acción aludida procura, sin lugar a dudas, proteger al menor, pero a costa de otro grave perjuicio para su familia o grupo económico que representa, puesto que no debe olvidarse que por lo general el menor es "jefe de familia", y entonces nadie quiere negociar con él, ya que teme que con posterioridad el negocio jurídico (negotio) sea anulado por motivo de la edad. Esto ocasiona una parálisis económica de la familia. Para paliar esta situación comienza a imponerse la práctica de nombrar a una persona (curador) para que asista al menor en cada caso de contratación, con la finalidad de salvaguardar sus derechos, brindándole así legitimidad al acto para que después no pueda ser revocado⁽⁴⁵⁾. Finalmente, después de Marco Aurelio se dispone la designación del curador estable en reemplazo del ocasional, quedando así perfilada definitivamente la institución.

Capítulo XII - La Persona de Existencia Ideal

CAPÍTULO XII - LA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL⁽¹⁾

Se entiende por persona de existencia ideal en sentido moderno "la abstracción jurídica derivada de un conjunto de individuos que persiguen el logro de un interés lícito común de modo independiente a sus componentes con aptitud para contraer derechos y obligaciones".

El derecho romano tiene en mira desde siempre aquello que los sentidos observan y a quien está destinado, es decir, el hombre. Pero el fino sentido de los juristas lentamente capta la particularidad de que en el seno de la sociedad, paralelamente a los sujetos de derecho de existencia visible, se encuentran otros entes conformados por éstos en modo conjunto, y que poseen capacidad jurídica propia distinta de la de cada uno de sus componentes. Así surge la idea embrionaria, y luego firme y sostenida, de la persona de existencia ideal. El aporte del derecho bizantino, y más tarde la labor de intérpretes y juristas, le dan forma concreta y moderna a la doctrina de la idea romana de la "persona de existencia ideal", "jurídica", "moral" o "ficticia", cualquiera sea la preferencia de su denominación.

Lo cierto es que el virtual pragmatismo de los juristas romanos advierte que el sujeto de derecho puede ser de dos modos, visible o de existencia ideal. Este último es avizorado primitivamente en el campo del derecho público en la figura del Estado, que personifica el pueblo romano (populus romanus), considerado un ente autónomo distinto a la sumatoria de sus integrantes. Más tarde se le reconoce personalidad jurídica a los "municipios". Paralelamente, en el derecho privado aparecen las "corporaciones", "asociaciones" y "fundaciones", con lo cual el esquema jurídico de la doctrina, conceptos y clasificaciones efectuados por los modernos queda conformada⁽²⁾.

I. EL ESTADO. ERARIO (AERARIAUM) Y FISCO (FISCUS)

La configuración definitiva del Estado como sujeto de derecho de existencia ideal se debe en Roma a una evolución que lleva siglos. Se dijo más arriba que el Estado personificado en el pueblo romano (populus romanus) es considerado sujeto de derecho; luego, durante el período clásico, todo lo concerniente al ingreso y egreso del Estado recibe el nombre de "erario" (aerarium); más tarde, en el Imperio, esta denominación queda circunscripta al tesoro del pueblo romano administrado por el Senado, mientras que el patrimonio personal del emperador pasa a llamarse "fisco" (fiscus). En las postrimerías del Bajo Imperio, como consecuencia de la consolidación mayor de las facultades del emperador, el término "fisco" (fiscus) absorbe al de "erario" (aerarium), pasando a conformar directamente el patrimonio del Estado. Es aquí donde definitivamente queda establecido este último como "ente ideal" susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones⁽³⁾.

II. LOS MUNICIPIOS

Aparecen nítidamente en el mundo romano como fruto de las conquistas territoriales, puesto que se le otorga dicha categoría a los distintos "estados o comunidades libres" que son anexadas al Estado romano por medio de guerras, alianzas o tratados. Los municipios pierden su soberanía, pero conservan cierta autonomía concedida por Roma; poseen bienes propios, caja común, pueden ser acreedores, deudores, adquirir toda clase de bienes entre vivos (inter vivos) o por "causa de muerte" (mortis causa), etc., por lo que se erigen en verdaderos "sujetos de existencia ideal"⁽⁴⁾.

III. LAS CORPORACIONES O ASOCIACIONES

Desde tiempos muy antiguos existen en Roma las corporaciones o asociaciones de artes y oficios, que cobijan a los artesanos y obreros de una misma especialidad, acentuando su finalidad religiosa más que la defensa de la actividad, las cuales gozan de cierta autonomía propia, siendo las más antiguas las de los orfebres, forjadores, alfareros, carpinteros, zapateros, curtidores, tintoreros y músicos. Luego comienzan a extenderse, siendo numerosas y de variados fines, v.gr., colegios sacerdotales; asociaciones para funerales y sepulturas (collegia funeraticia), destinadas a brindar socorro mutuo; gremios de distintos oficios; agrupaciones de empleados asalariados del Estado (apparitores, viatores, scribae), etc., que adoptan distintas denominaciones según los cargos que desempeñan sus integrantes, v.gr., cofradías para determinados cultos (sodalicia), etc.

Particular mención merece durante la República la aparición de corporaciones o asociaciones encargadas de la percepción de impuestos, ejecución de obras públicas, explotación de minas de plata, oro y salinas (societas publicanorum o vectigalium). Estas sociedades, verdaderas empresas comerciales, tienen a su cargo la realización de la mayor parte de las obras públicas más importantes encaradas por el Estado, y la percepción de la renta pública. Son para el derecho comercial las precursoras de las "sociedades colectivas" actuales.

De todas las asociaciones o corporaciones indicadas se puede extraer la necesidad de cumplir determinadas condiciones para su operatividad y existencia. Así se requiere para su nacimiento la reunión de por lo menos tres individuos, un fin lícito y estatutos. En su organización se encuentran ciertas semejanzas con las corporaciones públicas, de tal modo que el conjunto de los asociados forma la masa de miembros, distinguiéndose los cargos directivos del resto de los asociados; existe una caja común y la asociación actúa legalmente a través de sus representantes⁽⁵⁾.

1. La "ley julia de colegios" (lex Iulia de collegiis). Su influencia en nuestra legislación

Esta ley es de suma importancia, por cuanto establece la facultad del Estado en la concesión de las autorizaciones correspondientes para el nacimiento de nuevas sociedades. Hasta su aparición, son contados los casos en los cuales para el inicio de una nueva sociedad se requiere la autorización previa del Estado. Por lo general, el requisito inicial es la plena libertad de sus componentes en erigirse en corporación o asociación. En las postrimerías de la República, a causa de la inestabilidad política del momento, proliferan los abusos cometidos por estas sociedades, desvirtuando la finalidad de su creación e inmiscuyéndose en la vida política romana, comprometiéndose activamente en conspiraciones, aportes económicos a partidos políticos, fraudes y alianzas electorales, etc.

El camino para la sanción de la "ley Julia de colegios" (lex Iulia de collegiis) comienza en el año 64 a.C., cuando el Senado ordena la disolución de distintas corporaciones por los motivos indicados. No satisfechos con esta decisión, los intereses afectados por la ley presionan por conseguir la vuelta al sistema anterior, logrando que el tribuno Clodio hiciera votar en los comicios la llamada lex Clodia (58 a.C.), que restablece ampliamente el antiguo principio de libertad de asociación. Los abusos reaparecen al amparo de esta nueva normativa y un nuevo senadoconsulto del año 56 a.C., unido a la sanción de la lex Licinia (año 55 a.C.), pone coto a las corporaciones constituidas por ciudadanos indeseables, que tienen sólo en mira la corrupción electoral. De manera tal que el panorama se encuentra listo para la sanción de la "ley Julia de colegios" (lex Iulia de collegiis) que reglamenta acabadamente la constitución de las "asociaciones".

Las fuentes discuten la autoría de la ley, no resultando claro quién propone su sanción. La principal referencia se encuentra en Cayo Suetonio, que habla indistintamente de su sanción por parte de Julio César, situándola entre los años 49 y 44 a.C., y de Augusto, entre los años 7 y 21 de nuestra era⁽⁶⁾. Es mi opinión, luego de estudiar detenidamente las fuentes, que es Julio César quien en un principio adopta severas penas administrativas para castigar a quienes violan el fin perseguido en la constitución de la asociación. Luego, estas medidas son confirmadas y renovadas legalmente

por Augusto. Pero lo cierto, dejando de lado la determinación del autor, es que ella rige de allí en más la conformación de las asociaciones, incorporando el principio moderno de la "autorización previa del Estado para su funcionamiento".

Esta ley ordena la disolución de los colegios existentes hasta su sanción, excepto aquellos de muy antigua y noble tradición, que datan de los albores de Roma. Así, sólo subsisten las antiguas corporaciones religiosas, los primitivos gremios de artes y oficios, y las grandes asociaciones de comerciantes y financistas (societas publicanorum) por su gravitante importancia en la economía. Todas las demás son disueltas y sólo se permite la constitución de nuevas asociaciones si son autorizadas por el Estado. El funcionamiento futuro de éstas también queda sujeto a su contralor.

La "ley Julia de colegios" es adoptada sólo originalmente para la ciudad de Roma, y luego es extendida a toda Italia a través de senadoconsultos, alcanzando más tarde a las provincias por medio de constituciones imperiales. En Roma le corresponde al Senado entender respecto de todo lo concerniente a la constitución y funcionamiento de las asociaciones. En las provincias de rango senatorial, ejercen la facultad los gobernadores, y en las de rango imperial, el Príncipe.

IV. LAS FUNDACIONES

Consisten en la personificación de un patrimonio destinado al cumplimiento de la finalidad dispuesta por su fundador, ya sea por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad.

En Roma, originalmente, las fundaciones no se consideran sujeto de derecho por sí mismas, alcanzando dicha categoría recién a partir de Justiniano. Primitivamente, cuando un individuo desea realizar actos de beneficencia o de ayuda al prójimo, suele destinar parte de su patrimonio a tal fin mediante donación o legado (fundaciones piae causae). La autoridad pública emplea este mismo método, aunque son específicamente los emperadores Antoninos Nerva y Trajano quienes utilizan la figura incipiente de la "fundación", a semejanza de la actual, para sus planes de sostén de la niñez y juventud desvalida, a través de las denominadas fundaciones alimentarias. En la etapa cristiana se produce el auge de este tipo de ayuda, motorizada por la Iglesia, a quien el fundador destina el capital para que lo administre. Finalmente, después de Justiniano se abre paso el concepto de la figura de la fundación, a semejanza del conocido en la actualidad, reconociéndosele capacidad jurídica propia.

V. LA HERENCIA YACENTE (HEREDITAS IACENS)

Se entiende por ella el estado que presentan los bienes hereditarios durante el lapso comprendido entre el fallecimiento del titular y el momento en que aquéllos son adquiridos por los herederos. Los juristas romanos conocen perfectamente esta institución y le otorgan titularidad jurídica en representación del causante. Por tal motivo, la "herencia yacente" (hereditas iacens) goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones de modo similar a un sujeto de derecho^[7].

I. BREVE INTRODUCCIÓN AL TEMA

La institución del matrimonio tiene suma importancia en los pueblos de la Antigüedad dada su implicancia jurídica, social y económica. Particularmente, en Roma, el matrimonio tiene gran relevancia, por cuanto la convivencia entre los esposos asegura procreación legítima, trato, respeto mutuo, movilidad económica y social a través de la dote. Los juristas romanos se preocupan por conceptualizarlo jurídicamente, legislando formas, efectos, impedimentos y finalmente brindando una lección de progreso cultural, avizorando que éste no debe ser necesariamente perpetuo si los esposos pierden "la intención de vivir como marido y mujer" (affectio maritales), previendo su disolución mediante el divorcio⁽²⁾.

El derecho romano distingue el matrimonio del concubinato, diferenciándolo en cuanto a efectos legales, sociales y económicos, pero a su vez reconociéndolo y respetándolo a la par del matrimonio legítimo.



II. LAS DEFINICIONES DEL MATRIMONIO EN LAS FUENTES

En las fuentes hallamos la preocupación de los juristas en definir el matrimonio, aunque primitivamente se lo considera como una simple situación de hecho, imbuida de la intención de los esposos de vivir en matrimonio (affectio maritales), a la que se le conceden efectos legales.

Modestino lo define como "la unión del varón y la hembra y consorcio de toda la vida, comunicación del derecho divino y humano"⁽³⁾. Justiniano lo enseña como "la unión del varón y de la hembra que comprende el comercio indivisible de la vida"⁽⁴⁾.

Ambas definiciones son concordantes en su esencia, pero sin profundizar acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio. Esto es así, por cuanto los juristas, apegados a brindar soluciones prácticas a los casos concretos que se les presentan, dejan de lado la teoría. Sin embargo, cuando Modestino habla de "consorcio de toda la vida" no se refiere a perpetuidad o indisolubilidad del vínculo, sino a que ambos contrayentes, cuando se unen en matrimonio, deben hacerlo con ausencia en su ánimo de periodicidad. Es decir que su intención al momento de contraerlo debe ser "para siempre" y "no por un tiempo determinado". Ello no significa que no puedan separarse luego debido a las contingencias de la vida en común. Si ésta resulta en cierto momento intolerable, se puede poner fin a la unión matrimonial, ya sea mediante el divorcio (por decisión de ambas partes) o el repudio (por voluntad de uno solo de los contrayentes).

El otro aspecto de la definición de Modestino, relativo a la "comunicación del derecho divino y humano", presenta distintas interpretaciones a la luz de las fuentes. Por un lado, parece que no resulta apropiado aceptar en este autor, por ser un jurista clásico, la idea de igualdad material y espiritual entre los contrayentes, sino que, por el contrario, se trata al parecer de un resabio antiguo, producto de la conventio in manu, que permite dicha "comunidad", no advirtiéndose contradicción en ello. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se trate de una interpolación cristiana destinada a humanizar la relación entre los contrayentes. Me inclino por esto último, más aún después de tener en cuenta la mentalidad libre romana, sobre la que influencia posteriormente el cristianismo⁽⁵⁾. No debe extrañar, entonces, que se trate de una interpolación tendiente a nivelar la relación esposo-esposa. En este último sentido es interesante la postura de Grimal que, desprovisto de sentido religioso, sostiene que ambos contrayentes "conformarían las dos mitades de un único ser", puesto

que ése es el verdadero significado que debe darse a la "conocida frase pronunciada por la novia en el momento de celebrarse la boda: 'Que tú seas Gayo, que yo sea Gaya'". Según Grimal, esta expresión indica que la posición de ambos contrayentes es equivalente, sin preponderancia del marido sobre la mujer⁽⁶⁾.

III. EL CONCEPTO ROMANO DE MATRIMONIO. CARACTERÍSTICAS

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, defino al matrimonio romano como la "unión o convivencia de dos personas de diferente sexo con la intención mutua de considerarse marido y mujer, procreando y educando a los hijos nacidos de dicha unión, constituyendo entre ambos una comunidad absoluta de vida".

Para entender mejor el concepto, debe tenerse en cuenta que el matrimonio en Roma no se considera un acto jurídico sino, por el contrario, una situación de hecho, dada por la convivencia de dos personas de distinto sexo con la intención de ser marido y mujer (*affectio maritales*)⁽⁷⁾. Esto implica la conjunción de dos elementos, uno demostrado por la convivencia (elemento objetivo) y otro evidenciado en la intención común de ser marido y mujer (elemento subjetivo).

También resulta primordial destacar la importancia del consentimiento, por cuanto en éste radica una de las diferencias con el matrimonio moderno⁽⁸⁾. En las legislaciones actuales, por lo general, el consentimiento es el requisito que origina el matrimonio, puesto que se lo considera un acto jurídico. En cambio, en Roma, no tiene relevancia como acto inicial, sino como continuación o perduración de la relación matrimonial. De tal modo, cuando éste falta, ya no existe matrimonio, dando lugar al divorcio⁽⁹⁾. Posteriormente, debido a la influencia cristiana, contraria al divorcio, el consentimiento constituye el elemento primordial, porque origina el matrimonio, siendo otorgado una vez y para siempre.

Con el fin de que se comprenda mejor la institución, debe dejarse en claro que en Roma el matrimonio puede llevarse a cabo aun en ausencia del marido; considerándose incluso que también así comienza la vida en común. En cambio, ello no ocurre si no se encuentra presente la mujer⁽¹⁰⁾. Al respecto, basta simplemente con la introducción de la mujer en la casa del marido. Esto es así por la tipicidad del matrimonio romano, ya que el marido adquiere por lo general la potestad sobre la mujer (*manus*).

El matrimonio en Roma es considerado "cosa de hecho" (*res facti*) y no "cosa de derecho" (*res iuris*). Por ello, como en el caso de la posesión, no es de aplicación en el caso del *ius postliminii*. Este último es el derecho del ciudadano romano que cae prisionero o esclavo de guerra y que luego, por el motivo que fuese, vuelve a su hogar, recuperando todos los derechos a excepción del matrimonio, si la esposa contrajo nuevas nupcias⁽¹¹⁾. Esto es así por cuanto se considera al matrimonio una "situación de hecho con determinados efectos jurídicos", y no un acto jurídico en sí mismo. Se aplica el criterio similar a la posesión, guardando ciertas similitudes, puesto que a un hecho externo (convivencia) se le añade uno interno (*affectio maritales*). A propósito, debe señalarse que toda aquella manifestación que acompaña a la celebración del matrimonio, como entrega de la mujer, convivencia de ambos esposos, escritura dotal, ritos, ceremonias sociales o religiosas, etc., no son sino medios de prueba que los juristas romanos tienen en cuenta para la exteriorización del consentimiento.

Por esta razón, los emperadores Teodosio y Valentiniano deciden que, en ausencia de alguna de estas manifestaciones y tratándose de personas de la misma condición, siendo ambos honorables, la vida en común lleva aparejada la presunción de matrimonio⁽¹²⁾.

En Roma se destaca como característica del matrimonio el "honor matrimonial" (*honor matrimonii*), es decir, su honorabilidad, que consiste en la exteriorización en el trato público que se dispensan los esposos, especialmente el que le otorga el marido a la mujer, que le permite a ésta ocupar el rango social del esposo (*affectio maritales*).

Finalmente debo señalar que el matrimonio romano siempre es monogámico, y que la sociedad vela por esto, considerando de mucha estima social mantener tal principio. La bigamia aparece la inhabilitación para ejercer cargos públicos (tacha de infamia)⁽¹³⁾.

IV. LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

Si bien el matrimonio romano no es un acto jurídico, sino más bien una situación de hecho dada por la cohabitación unida a la intención de ser marido y mujer, es necesario cumplir determinados requisitos para poder contraerlo y que tenga validez. Éstos son los siguientes: 1) aptitud biológica; 2) aptitud jurídica; 3) consentimiento de los contrayentes; 4) consentimiento de los respectivos pater familias.

1. Aptitud biológica

Se refiere a que ambos contrayentes tienen que ser púberes para poder contraer matrimonio. Es decir que deben tener aptitud biológica para procrear. Esto se exige por la finalidad misma del matrimonio, destinada a perpetuar la especie. No todas las personas inician la pubertad a la misma edad, pero es necesario determinarla misma como parámetro para evitar que cada individuo se convierta en un caso particular, con los inconvenientes que ello acarrea. Así lo entienden los juristas romanos que, guiados por la experiencia, legislan que la mujer a los 12 años adquiere la aptitud natural para concebir, mientras que el hombre a los 14 años para engendrar.

Pero respecto de este último, la situación no es pacífica y existen posiciones disímiles. Las escuelas jurídicas de los proculeyanos y sabinianos discrepan en cuanto a ello. Los primeros siguen las antiguas costumbres, por las cuales es incumbencia del pater familias determinar cuándo un hijo varón es púber. Los segundos, por su parte, defienden el criterio de que se fije una edad para todos los varones, acordándolo en la edad de 14 años. Finalmente, Justiniano adopta la solución propuesta por los sabinianos⁽¹⁴⁾. Debo destacar el pragmatismo de los juristas romanos que, guiados por el sentido común, consideran que si no se respeta la edad y el matrimonio se celebra cuando ambos, o cualquiera de los contrayentes, aún no son púberes, igualmente es válido si la unión subsiste después de que el cónyuge incapaz alcanza la edad legal⁽¹⁵⁾.

2. Aptitud legal

Este requisito implica que los esposos deben gozar del "derecho a contraer justas nupcias" (ius connubii). Únicamente los ciudadanos romanos gozan de este derecho privado, aunque también se les reconoce a los latini veteres y a determinadas personas por concesión especial⁽¹⁶⁾. El matrimonio que se contrae sin gozar de este derecho es considerado "matrimonio injusto" (matrimonium iniustum), llamado también "matrimonio del derecho de gentes" (matrimonium iuris gentium). Este tipo de matrimonio no es considerado tal por la legislación romana, aunque sí lo es para el Estado al que pertenece la persona extranjera⁽¹⁷⁾. Como se multiplican las uniones entre ciudadanos romanos y peregrinos, comienza a plantearse la situación jurídica de los hijos habidos de estas uniones. En el siglo I a.C. se dicta la lex Minicia, por la cual se determina que en tales casos los hijos adquieren la condición jurídica del padre no ciudadano⁽¹⁸⁾. Esta situación finaliza en el año 212, con la promulgación de la "Constitución Antoniana" (Constitutio Antoniana), que otorga el ius connubii a los extranjeros. Particular consideración merece la unión de patricios y plebeyos, puesto que tampoco contraen justas nupcias (iustae nuptiae) hasta el año 445 a.C., en que la lex Canuleia les reconoce la facultad de poder casarse. Tampoco celebran justas nupcias libres y libertos hasta las postrimerías de la República, en que la prohibición cae en desuso, aunque luego Augusto vuelve a imponerla para las uniones entre aquellas personas que tienen rango senatorial y los libertos⁽¹⁹⁾. Finalmente cabe añadir que no se considera matrimonio válido la unión entre esclavos (contubernium). Igual consideración se tiene a la cohabitación entre una persona ingenua y otra esclava⁽²⁰⁾.

3. Consentimiento de los contrayentes

Es necesario que ambos contrayentes otorguen el consentimiento para contraer matrimonio. La voluntad de los esposos no tiene que estar invalidada por ningún tipo de vicio, es decir que tiene que ser plena⁽²¹⁾. Este requisito en los comienzos de Roma no tiene tal importancia, por cuanto la figura poderosa del pater familias decide prácticamente por las personas que están bajo su potestad. De tal modo, muchos matrimonios y divorcios se llevan a cabo por la propia conveniencia del jefe de familia que, con el fin de tejer alianzas, acrecentar poder, influencia o patrimonio, decide el futuro matrimonial de sus hijos, nietos o cuanta persona se encuentre bajo su potestad. Luego, avanzado el Imperio, ante el debilitamiento de los poderes del pater familias a raíz del cambio de las costumbres y la humanización del derecho por injerencia del cristianismo, se tiene en cuenta especialmente el consentimiento de los futuros esposos, y que además éste se otorgue sin ningún tipo de vicio de la voluntad, es decir, libremente. Debe destacarse que el consentimiento brindado por los esposos debe ser voluntario y duradero, por cuanto la base del matrimonio romano descansa precisamente en mantener la voluntad de ser esposos, traducido en affectio maritales. Suspendido o interrumpido este último, se produce el divorcio. El consentimiento no está sujeto a ningún tipo de formalidad, bastando sólo que se lo otorgue libremente. Las formas o modos de brindarlo, entendiéndose por ello la ceremonia o acontecimiento social, no son precisamente un requisito, sino, en todo caso, un modo de prueba futura en cuanto a que se ha emitido voluntad para contraer matrimonio. Entonces, por lo expuesto, no puede contraer matrimonio el insano (furiosii)⁽²²⁾, considerándose inválido el matrimonio en el cual la voluntad se obtiene mediante cualquier forma de violencia⁽²³⁾. Asimismo, el consentimiento debe ser brindado en forma seria y no en broma o jugando (iocandi gratia), puesto que de lo contrario el matrimonio es nulo⁽²⁴⁾.

3.1. La publicidad del acto en el caso del matrimonio

Lo expuesto respecto del consentimiento de los contrayentes se relaciona con la necesidad de "la publicidad del acto". Es mi opinión que los juristas romanos entienden muy bien su significado, y esencialmente su efecto inmediato, "la oponibilidad a terceros". Una de las características que forja la grandeza del derecho romano es el espíritu práctico de sus juristas, que brindan solución inmediata al problema concreto que se les presenta en análisis, es decir, decidir frente a la vida misma que pasa ante sí en el caso a juzgar, por cuanto el derecho no es otra cosa que la vida misma. De la practicidad, o casuística, de la jurisprudencia romana se desprende una coherencia significativa que se manifiesta en los principios rectores de todo el derecho futuro del mundo occidental. Los juristas romanos comprenden desde el inicio que el derecho debe manifestarse (publicidad de los actos) para que el resto de la sociedad tome debida cuenta de ello (oponibilidad). Por tales fundamentos, me parece oportuno efectuar esta aclaración al tratar el tema del matrimonio, sin perjuicio de que además tiene aplicación en otras instituciones del derecho romano: la exteriorización de la voluntad para contraer matrimonio por parte de los futuros contrayentes en Roma no es sólo un requisito para su validez, sino una necesidad de dar a conocer al resto de la sociedad el inicio de la unión o cohabitación matrimonial. Queda claro que no se exige forma alguna, y que se puede adoptar la que se desea, según el efecto que se le quiere dar al matrimonio. Por eso he manifestado ut supra que el modo o forma utilizada (ceremonia, rito, fiesta) sirve como oportuno medio de prueba. Modernamente, estos principios rectores emanados del derecho romano (publicidad del acto y oponibilidad a terceros) se ven reflejados en el derecho registral, v.gr., de las personas, prendario, catastral, etc., que, por otra parte, también tienen su origen en Roma tiempo después.

4. Consentimiento de los respectivos pater familias

Como es sabido, especialmente en la primitiva época romana, el jefe de familias tiene verdadero poder ilimitado que lo faculta a brindar, o negar, su consentimiento en el matrimonio de cualquiera de sus hijos. Es más, pacta con el pater de la otra familia el matrimonio de sus respectivos hijos, según conveniencias económicas o políticas. Luego, con el transcurso del tiempo se recortan los amplios poderes del jefe familiar y su consentimiento pierde la gravitación que tenía en un principio, pasando a tener relevancia la voluntad de los contrayentes⁽²⁵⁾. Debo destacar que el consentimiento del "jefe de familias" es necesario siempre que se trate de un hijo bajo su potestad (aliena iuris), puesto que si éste es sui iuris, no hace falta su aprobación⁽²⁶⁾. Entonces, según he señalado, como consecuencia de la evolución que lleva a cabo la sociedad romana, disminuyen paulatinamente los ilimitados poderes del pater familias, y se deja de exigir el consentimiento expreso de este último, bastando tan sólo su falta de oposición o silencio.

En el caso de las hijas mujeres, la voluntad del pater familias es esencial, salvo que aquélla demuestre que el elegido como esposo no es una persona de mala conducta⁽²⁷⁾. En tiempos de Augusto (18 a.C.), cuando la oposición del pater familias al matrimonio es injustificada, los contrayentes pueden acudir al magistrado para que supla la venia paterna (lex Iulia de maritandis ordinibus)⁽²⁸⁾. También el magistrado otorga el correspondiente consentimiento en lugar del pater familias a pedido de los contrayentes cuando aquél no esté en condiciones de otorgarlo, afectado por demencia o idiotez. El procedimiento requiere que el magistrado escuche la opinión del curador del padre de familia y de los parientes directos más importantes⁽²⁹⁾. Similar tratamiento requiere el supuesto de que el pater familias se encuentre prisionero o ausente, de modo tal que no se sepa nada de él, aunque en este último caso se exige que la ausencia fuese por lo menos de tres años⁽³⁰⁾. Particular situación suscita en el período clásico el caso de la mujer sui iuris que se encuentra bajo tutela permanente, puesto que, a pesar de su máxima condición jurídica, requiere del consentimiento del tutor. Más tarde, suprimida la tutela perpetua, sólo se exige para la mujer menor de 25 años el consentimiento del pater, incluso si son viudas, o a falta de éste, de la madre o parientes, y si no, por último, de la autoridad judicial⁽³¹⁾. Para completar el tema es menester hacer referencia al caso singular de que el hijo y su padre biológico se encuentren bajo la potestad de un mismopater familias, v.gr., el abuelo. En este supuesto, no sólo hace falta la aprobación del pater, sino también la del padre biológico, por cuanto, de suscitarse la muerte del primero, el segundo pasa a ser "jefe de familias" y de tener descendiente el filius, sus hijos pasan a depender directamente del nuevo pater familias, siendo, por lo tanto, importante el consentimiento porque, de producirse loexpuesto, tiene bajo su potestad a los mismos. Por dicho motivo se requiere el consentimiento del pater familias y del padre biológico⁽³²⁾.

V. LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

Son impedimentos (impedimentum) aquellos obstáculos y prohibiciones que no permiten contraer matrimonio a alguno o ambos contrayentes.

Puedo decir que para el sentido práctico de los juristas romanos los impedimentos no son otra cosa que "requisitos negativos" para poder celebrar nupcias legítimas. Luego, circunstancias éticas, sociales, políticas y religiosas originan en debida forma a los impedimentos. Éstos pueden ser absolutos y relativos.

1. Los impedimentos absolutos

Son los que obstaculizan al contrayente que los padece contraer matrimonio con cualquier persona, es decir que se encuentra a causa de éstas invalidado siempre a contraer nupcias legítimas. Se consideran impedimentos absolutos la subsistencia de matrimonio anterior, esclavitud de uno de los contrayentes, castración y esterilización, voto de castidad o ingreso a las órdenes mayores.

a. Subsistencia de matrimonio anterior. El matrimonio anterior no disuelto es un impedimento absoluto que no permite al afectado contraer nuevas nupcias mientras dicho vínculo tenga vigencia. El modo de subsanarlo es únicamente el divorcio o la viudez del afectado. El fundamento de este impedimento es que el derecho romano no acepta la coexistencia de doble vínculo, como bigamia o poligamia⁽³³⁾.

b. Esclavitud de uno de los contrayentes. Ambos contrayentes tienen que ser libres y la condición de esclavo de uno de ellos no permite la concreción del acto. Más tarde, en el derecho justiniano se admite el matrimonio de un hombre libre con una esclava⁽³⁴⁾.

c. Castrados y esterilizados. Están afectados de manera absoluta para contraer matrimonio los castrados (castrati) y los esterilizados (spadones). Es así por cuanto este tipo de incapacidad guarda plena coherencia con el concepto de matrimonio romano, en el cual es relevante la procreación⁽³⁵⁾. El castrado es aquel a quien se le han suprimido los órganos genitales y, por ende, no puede ejercer debidamente el acto sexual. El esterilizado, en cambio, conserva intactos sus órganos de reproducción, pero si bien pueden llevar a cabo normalmente el acto sexual, es inválido para procrear. Con respecto a los esterilizados, es menester dejar en claro que la jurisprudencia romana permite contraer matrimonio normalmente a aquel que es estéril desde el nacimiento; en cambio, no lo permite cuando ha sido esterilizado de algún modo con posterioridad. Entiendo, tras la atenta lectura de las fuentes, que la mencionada distinción se refiere fundamentalmente a que el estéril de nacimiento puede contraer casamiento libremente, siempre que no supiera su condición, cosa, por otra parte, muy poco comprobable en la época; de saberlo, se encuentra también invalidado. En cambio, no existe duda respecto de aquel que sufre la esterilización, puesto que no median dudas de la existencia de su invalidez.

d. Los que hubieran hecho voto de castidad o ingresado a las órdenes mayores. Con la influencia decisiva del cristianismo, no pueden contraer de modo absoluto matrimonio aquellos que han hecho voto de castidad o ingresado a las órdenes mayores⁽³⁶⁾.

2. Los impedimentos relativos

Son aquellos que obstaculizan al contrayente que los padece para contraer matrimonio con determinada persona, o sea que se encuentra a causa de dicho impedimento invalidado para contraer legítimas nupcias con determinada persona, pero no con cualquier otra. Estos impedimentos se originan por las siguientes causas: parentesco, moral o ética, religión, interés público o privado.

a. Parentesco. En principio, he de diferenciar el parentesco en línea recta del parentesco en línea colateral. El primero es infinito, ya que no pueden casarse bajo ningún concepto, sean parientes naturales o adoptivos, sin distinción de cognación o agnación⁽³⁷⁾. En línea colateral la jurisprudencia romana efectúa las siguientes diferenciaciones. El matrimonio entre hermanos está absolutamente prohibido, sin distinguir si son de ambas partes o de uno solo de ellos⁽³⁸⁾. También está prohibido el matrimonio entre tíos y sobrinos. La razón radica en que los tíos, en cierto modo, se encuentran en el mismo lugar que los padres. Destaco que en ciertas oportunidades, por conveniencia, este principio jurídico se deja de lado para permitir, por ejemplo, que Claudio se pueda casar con su sobrina Agripina, hija de su hermano Germánico; luego, los descendientes de Constantino vuelven a implantarlo⁽³⁹⁾. Según Tácito, el matrimonio entre primos hermanos está en principio prohibido, pero en la práctica es permitido hasta que los primeros emperadores cristianos expresamente lo prohíben hasta el cuarto grado. Con posterioridad, los emperadores Honorio y Arcadio en el año 405 levantan tal prohibición⁽⁴⁰⁾. El parentesco por afinidad también obsta para celebrar el matrimonio, aunque comienza a tenerse en cuenta cuando aquél se disuelve. En primer lugar, el parentesco por afinidad en línea recta (suegro y nuera, suegra y yerno) es un impedimento hasta el infinito. En segundo lugar, el parentesco por afinidad en línea colateral (cuñados) es impedimento hasta el segundo grado. Pero es menester considerar la evolución que experimenta esta prohibición: hasta la época clásica no hay obstáculo y pueden contraer matrimonio sin problema alguno; luego Constantino impone la citada limitación, que posteriormente es ratificada por Justiniano⁽⁴¹⁾. Los padrastros no pueden casarse con sus hijastras, ni tampoco las madrastras con sus hijastros, pero en cambio tal prohibición no alcanza a estos últimos (hijastros), ya que no existe lazo de parentesco alguno entre ellos. Por el contrario, los hermanastros no pueden casarse entre sí⁽⁴²⁾. Estos principios se aplican por razones análogas cuando media lazo de

parentesco agnaticio derivado de la adopción. Es decir, como se considera al adoptado en un mismo pie de igualdad con el hijo legítimo, le alcanzan los principios y limitaciones expuestas anteriormente⁽⁴³⁾.

b. Moral o ética. Entre estos impedimentos tenemos los siguientes casos: se prohíbe el matrimonio del esposo divorciado con la hija de su ex esposa habida en un matrimonio posterior. También se prohíbe el matrimonio entre el hijo y la prometida o concubina de su padre⁽⁴⁴⁾. Particular consideración merece el tema del adulterio y el rapto. La lex Iulia de adulteriis, confirmada luego por la lex Iulia et Papia, prohíbe el matrimonio entre la mujer adúltera y su cómplice⁽⁴⁵⁾. Luego esta prohibición pierde su sentido cuando Constantino castiga directamente con la pena de muerte al adulterio. También prohíbe el matrimonio entre el raptor y la mujer raptada, sin diferenciar si media resistencia o consentimiento de la víctima⁽⁴⁶⁾. La prohibición alcanza también al caso del rapto de una viuda o de una religiosa. La razón de estas prohibiciones se fundamenta en el respeto debido a la mujer y también en razones de orden y tranquilidad pública.

c. Religión. Por motivos religiosos se prohíbe el matrimonio entre cristianos y judíos, y entre cristianos y herejes. Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio dictan una constitución al respecto⁽⁴⁷⁾. La prohibición surge cuando avanza considerablemente la influencia del cristianismo en el imperio, especialmente cuando se la sostiene como religión oficial.

d. Interés público y privado. Entre los impedimentos originados por estas razones, encontramos los siguientes: al comienzo del Imperio se prohíbe a los militares contraer nupcias con la finalidad de favorecer el mantenimiento de la disciplina en el ejército. Más tarde, a fines del siglo II, tal prohibición se deja sin efecto. Los emperadores, además, vedan a los funcionarios provinciales la posibilidad de casarse con mujeres oriundas o domiciliadas en el lugar en que ejercen su mandato. También alcanza a sus hijos. Con este impedimento se busca no aumentar el poder, ya de por sí importante, del magistrado, y a la vez, sustraer de presión y violencia a las familias afectadas⁽⁴⁸⁾. Por otra parte, desde muy antiguo se prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos, hasta el año 445 a.C., cuando se sanciona la lex Canuleia. Tampoco se permite el matrimonio entre hombres libres y manumitidos hasta la época de Augusto (leyes Iulia et Papia Poppae), con la finalidad de favorecer las uniones y combatir el celibato. Pero si bien se levanta esta prohibición, se mantienen otras, estableciendo el impedimento para contraer matrimonio entre los senadores, sus descendientes en primer grado y demás descendientes por vía masculina con los manumitidos; y con aquellos que ejercen actividad o profesión reputada como deshonorosa (personae adiectae), como por ejemplo los comediantes, meretrices, propietarios de posadas, gladiadores, etc.⁽⁴⁹⁾. El emperador Justino dicta una constitución por la cual la actriz que abandona su profesión queda purificada, y por lo tanto puede contraer libremente matrimonio con cualquier magistrado del Estado⁽⁵⁰⁾. Toma esta determinación para permitir que su sobrino Justiniano pueda contraer legítimas nupcias con Teodora, cuya reputación está en duda, según las costumbre de la época, por pertenecer a familia de cirqueros. Justiniano, una vez nombrado emperador, deja sin efecto todas estas limitaciones⁽⁵¹⁾.

Durante el gobierno de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo se prohíbe mediante un senadoconsulto el matrimonio entre el tutor y su pupila; y también entre el curador y la mujer menor de 25 años colocada bajo su potestad. Esta prohibición alcanza al padre y a los hijos del tutor y del curador. Se persigue con esta limitación la transparencia en el proceder de los tutores y curadores, evitando que mediante el matrimonio se soslaye la obligación de dar cuentas y recibir su finiquito. Hay que destacar que la prohibición prácticamente desaparece cuando la mujer alcanza los 25 años y vence el plazo para ejercer la "acción de restitución de bienes" (actio in integrum restitutio)⁽⁵²⁾ si no se está de acuerdo con la gestión de su tutor o curador.

VI. LOS ESPONSALES⁽⁵³⁾

Consisten en la promesa recíproca dada por los novios de que en un futuro próximo contraerán matrimonio⁽⁵⁴⁾. La costumbre en Roma hace muy común celebrar los esponsales de modo previo al matrimonio. Se lleva a cabo mediante una de las figuras contractuales más antiguas, la estipulación (sponsiones). De aquí derivan los términos empleados para la promesa (sponsalia), el novio (sponsus) y la novia (sponsa). Debe destacarse que si bien se utiliza un contrato del derecho civil para plasmar los esponsales, éstos no generan ninguna vinculación jurídica. Con esto quiero significar que su celebración tiene más bien carácter moral, o de uso social de la época. Éstos no facultan jurídicamente a los novios a someterse a la celebración del matrimonio. El novio que se arrepiente no puede ser forzado jurídicamente a cumplir su promesa de contraer nupcias.

1. Los requisitos para contraer esponsales

A pesar de no implicar obligación alguna entre las partes, los juristas romanos igual consideran prudente establecer requisitos que deben cumplir los novios para la celebración de los esponsales. La razón de la exigencia radica en que, a pesar de no originar un vínculo, si luego la promesa se concreta, efectivamente éste nace. Y por ende debe regularse. Son requisitos para contraer los esponsales los siguientes: a) El *ius connubium*. Éste ha sido explicitado al enunciar los requisitos para contraer matrimonio, y me remito a lo expuesto. b) El consentimiento de los novios. Sólo basta que lo otorguen⁽⁵⁵⁾. No importa que sean púberes⁽⁵⁶⁾. Aunque después de Justiniano se exige que tengan como mínimo 7 años⁽⁵⁷⁾. c) El consentimiento del pater familias. Se encuentra librado de todo formalismo y es necesario que lo otorgue, o que al menos no manifieste oposición en contrario⁽⁵⁸⁾. d) Ausencia de impedimentos. Por supuesto, dado que la promesa está dirigida a contraer matrimonio en el futuro, ambos novios no deben estar afectados por ningún impedimento de los considerados permanentes. Los temporarios están permitidos, por cuanto necesariamente desaparecerán al momento de celebrarse el matrimonio; caso contrario, éste no puede celebrarse⁽⁵⁹⁾.

2. Efectos de los esponsales. Las arras esponsalicias

La celebración de los esponsales no apareja para los novios ningún efecto jurídico gravitante. Debe entenderse entonces que no puede exigirse el cumplimiento, es decir, concretar matrimonio. Los futuros contrayentes pueden arrepentirse luego de formalizar los esponsales y ello es perfectamente válido, no pudiendo ser obligados a contraerlo si no es su voluntad. Pero si bien no derivan consecuencias jurídicas de importancia, median otras menores, que son las siguientes: no pueden celebrarse otros esponsales mientras subsisten los anteriores, bajo pena de infamia; el novio tiene derecho de ejercitar la "acción de injurias" por las ofensas ocasionadas a la novia; deber de fidelidad de la novia; la consideración de un vínculo de cuasi afinidad entre los parientes de los futuros esposos que les impide contraer matrimonio entre ellos⁽⁶⁰⁾.

La falta de exigibilidad jurídica de los esponsales apareja en Roma, con el correr del tiempo, que se desvirtúen, y muy pocos terminan cumpliéndolos. La situación se complica mucho más, por cuanto la celebración de los esponsales va acompañada de obsequios importantes entre los prometidos (*donatio propter nuptias*) y, normalmente, si el matrimonio no se concreta, deben restituirse.

Los esponsales en sus comienzos funcionan a la perfección como futura alianza entre las familias de los novios, para acrecentar el poder político o económico de ambos "padres de familias" o de alguno de ellos. Por tal motivo, cuando la intervención del pater familias es decisiva para que el matrimonio se celebre, los esponsales tienen gran importancia. Pero con el cambio de costumbres y la debilitación de los poderes del pater, acompañado con la mayor importancia otorgada a la voluntad de los futuros contrayentes, comienza la decadencia de la institución, por cuanto nadie la respeta, y, menos aún, procede en consecuencia a la devolución de los bienes recibidos. Muchas veces estos últimos importan verdaderas fortunas, asimilables a una dote.

Los juristas romanos, siempre prestos a solucionar los problemas que se presentan en el derecho, advierten las injusticias patrimoniales que se suscitan ante la falta de cumplimiento de la palabra dada en la celebración de los esponsales y buscan una solución. Éste es, a mi entender, el origen de las "arras esponsalicias" (*arrae sponsaliciae*) que surgen en el período posclásico, derivado de una institución aplicada originalmente en la parte oriental del imperio y que luego se extiende a su totalidad.

El tema admite la siguiente evolución. Previamente encontramos la preocupación en el tema de Constantino, quien dispone que los obsequios intercambiados entre los novios debe considerarse que se efectúan bajo condición de que el matrimonio se lleve a cabo y, en caso contrario, se admite el reclamo de su devolución. Esto último sólo lo puede realizar aquella parte perjudicada, la que no se arrepiente, y tiene derecho a exigir la devolución de lo entregado y retener lo recibido.

Constantino sabe distinguir el caso en que el matrimonio no se concreta por arrepentimiento, sino por muerte de uno de los prometidos. Para este supuesto dispone que los obsequios recibidos deben repartirse entre el novio sobreviviente y los herederos. También contempla la excepción que establece que sólo debe devolverse la mitad de los bienes para el supuesto de que en la celebración se cumpla con la formalidad del "beso esponsalicio" (ósculo interviniente)⁽⁶¹⁾.

El paso siguiente es la aceptación de las "arras esponsalicias", que deben ser concertadas por los futuros contrayentes juntamente con la celebración de los esponsales⁽⁶²⁾. Una vez concertados, se aplica la norma que sostiene que el arrepentimiento de la promesa dada en los esponsales apareja sanciones económicas. Estas últimas sólo tienen cabida respecto del intercambio de regalos efectuados por los futuros contrayentes, lo que significa concretamente que la parte que incumple injustificadamente su promesa de futuras nupcias pierde todos los bienes que le hubiera entregado a la otra parte en la celebración de los esponsales. Y tiene, además, que devolver lo que hubiera recibido. Esto último no es simple, por cuanto se exige la devolución del valor del cuádruplo (derecho prejustiniano) y más tarde del doble (derecho justiniano). Únicamente los menores proceden a la devolución de lo recibido sin ninguna sanción⁽⁶³⁾.

De este modo se consigue sanear la cuestión, por cuanto los interesados pueden celebrar directamente el matrimonio sin necesidad de concertar previamente los esponsales. Pero si éstos se celebran, por lo general van acompañados de un intercambio de obsequios de significativo valor, asimilables a una dote. De aquí que se afiance la idea de conseguir el cumplimiento del fin perseguido por los esponsales, o sea, celebrar el matrimonio a través de las arras esponsalicias. En otras palabras, que el matrimonio se lleve a cabo según la promesa dada y, para el caso de arrepentimiento injustificado, que las partes lo sientan económicamente, evitando así la corruptela de las especulaciones económicas.

VII. LAS DISTINTAS FORMAS DE CONTRAER MATRIMONIO Y SUS CONSECUENCIAS⁽⁶⁴⁾

Se explicó al desarrollar el concepto de matrimonio que basta tan sólo el mero consentimiento de los esposos para que éste exista. Las formas de contraerlo no están dirigidas a enmarcar su comienzo sino, por el contrario, a indicar los distintos efectos que emanan del acto. Es decir, la diversidad de formas genera las distintas consecuencias jurídicas.

El matrimonio romano, en esencia, es uno solo, pero puede tener respecto de la mujer dos efectos disímiles. Ambos se refieren a la adquisición o no de la manus sobre ella. Estos efectos surgen según el modo en que se pacta el matrimonio. El matrimonio cum manu importa la adquisición de la manus sobre la mujer, mientras que el sine manu significa lo contrario⁽⁶⁵⁾.

Una vez que se decide el tipo de matrimonio en cuanto a los efectos que se quiere concertar, se elige la forma de llevarlo a cabo. Esto no es otra cosa que el modo de evidenciar ante el resto de la sociedad el tipo de matrimonio que se contrae. No debe olvidarse que en Roma no existen en las primeras épocas registros públicos, y por ello la publicidad del acto tiene vital importancia para seroponible a terceros.

Precisamente, las distintas formas de contraer matrimonio son un medio de darle publicidad, hacer saber al resto de la sociedad que el matrimonio se celebra con adquisición de la manus (cum manu) o no (sine manu). La forma indica la decisión que adopta el pater familias respecto de la manus de la mujer. En realidad, en los albores de Roma, y por mucho tiempo, especialmente mientras el pater familias mantiene su gran concentración de poderes, los matrimonios se llevan a cabo a través de acuerdos entre los "jefes de familias". Éstos, al sellar el pacto matrimonial de sus hijos o de las personas que se encuentran bajo su potestad, deciden el futuro de la mujer, lo que tiene singular importancia para la subsistencia o no de la vocación hereditaria. Por tal motivo se decide, o pacta, la adquisición de la manus sobre la mujer según la conveniencia de las familias involucradas en el matrimonio. Muchas veces es más importante para la mujer perder la manus de origen, pero ganar aquélla de la familia a la que pertenece el marido, y otras, y no perder la suya. Este juego de intereses es velado celosamente por los pater familias que intervienen en la concertación del matrimonio. Luego, ante el avance del cristianismo y la gradual pérdida de los poderes del "jefe de familias", este sistema se desvanece hasta desaparecer.

1. Los modos de contraer el matrimonio cum manu

El matrimonio aparece el efecto jurídico cum manu a través de tres formas de celebración, a saber: confarreatio, coemptio y usus⁽⁶⁶⁾.

1.1. La confarreatio

Consiste con el usus en una de las formas más antiguas de contraer matrimonio, teniendo auge durante la época monárquica y parte de la República. Este tipo de matrimonio va acompañado de pomposidad y gran despliegue material y personal, que se acrecientan cuanto más acaudaladas son las familias intervinientes. La celebración de este tipo de matrimonio se inicia al alba, donde la actividad en las casas de ambos contrayentes es febril a la luz de las antorchas que las iluminan por doquier. Los aposentos, engalanados mediante la exhibición de los bustos e imágenes de los antepasados, dan mayor solemnidad a la escena, mientras familiares, clientes e invitados departen alegremente. La costumbre exige que la noche previa la cabellera de la novia se sujete con una redcilla de color bermejo. El día de la boda, ésta luce una túnica blanca que simboliza la pureza, sin dobladillos, que abarca todo su cuerpo (tunica recta). Ésta se ajusta en su cintura mediante un cinturón de lana de doble nudo (cingulum herculeum) que da prueba de su pudor, y sobre sus hombros un manto color azafrán (palla). Lleva sandalias del mismo color y un collar de metal en la garganta. Sobre la cabeza porta seis rodetes postizos, separados unos de otros por ínfulas que significan el sometimiento a su esposo, y encima un velo anaranjado y reluciente (flameum), en conmemoración de las vestales que deben portarlo durante todo su largo ministerio. Este tocado cubre pudorosamente la parte superior de su rostro. Una corona trenzada, que simboliza la fecundidad y cuya composición varía según las épocas (verbena, mejora, arrayanes, azahares, etc.), va por encima del velo anaranjado. La novia así vestida, acompañada por sus padres, familiares y amigos, recibe al novio y a su parentela. Una vez reunidas ambas familias, comienzan a celebrarse los distintos rituales que dan forma al matrimonio romano conocido como confarreatio. La ceremonia comienza con un sacrificio a los dioses, v.gr., oveja, cerdo, y excepcionalmente un buey, que puede llevarse a cabo en el atrio (atrium) de la casa, o en algún santuario vecino. La ceremonia religiosa se desarrolla en presencia del gran pontífice y diez testigos. Se examinan las entrañas de la víctima inmolada, prediciendo la voluntad favorable de los dioses sobre el futuro de la pareja. En caso de que el auspicio no sea bueno, la ceremonia no puede continuar y se suspende. Comprobada la acogida favorable de los dioses, el sacerdote comunica la buena nueva a los presentes, quienes guardan respetuoso silencio.

A continuación, ambos esposos otorgan mutuo consentimiento al acto. Ello se cumple mediante una fórmula sacramental de mucho significado, por la cual parecen confundirse no sólo las voluntades, sino también sus vidas. Dicha fórmula consiste en una interrogación mutua entre los contrayentes por la cual se dicen: "Donde tú seas Gayo yo seré Gaya" (urbi tu Gaius, ego Gaia). Con esta afirmación termina el silencio que enmarca el misterio del rito religioso y los presentes profieren calurosas aclamaciones de buenos augurios, diciendo: "¡Que la felicidad sea con vosotros!" ("Feliciter!"). La celebración de la ceremonia se acompaña con libaciones efectuadas por los novios, el pronunciamiento de otras oraciones religiosas y la comida mutua de una torta de harina (panis, farreus) en homenaje al dios Júpiter Farreo. De allí deriva el nombre de confarreatio.

Luego se realiza un festín, en el cual la comida, la bebida y el baile continúan sin interrupción hasta el anochecer. Finalmente, el ritual continúa con la despedida de la esposa de la casa paterna, especialmente de su madre, quien la sujeta como impidiéndole irse, hasta que la arrancan simbólicamente de sus brazos.

La comitiva parte de la casa de la novia precedida de dos flautistas y cinco portadores de antorchas. El trayecto se matiza con alegres y picarescos canciones entonadas por los integrantes de la comitiva y la gente que se les une a su bullicioso paso. El cortejo continúa de dicho modo hasta llegar a la casa del novio. Allí se cumple otra parte del ceremonial. El novio arroja a la muchedumbre un puñado de nueces que significan la fecundidad. A continuación se adelantan hacia

la pareja tres amigos del esposo, quienes continúan con el ritual, uno de ellos, el pronobus, algo así como el padrino de la boda, esgrime la antorcha nupcial hecha de ramas de oxiacanta cuidadosamente entrelazadas. Los otros dos toman a la esposa y la levantan en brazos haciéndola cruzar el umbral del nuevo hogar sin que toque el suelo.

Una vez traspasada la puerta de la casa, la esposa avanza hacia el interior seguida por tres amigas. Dos de ellas portan una rueca y un huso que representan su laboriosidad y virtud doméstica. La restante, la pronuba (madrina de la boda), espera pacientemente que el esposo ofrezca el agua y el fuego para conducir luego a la esposa hasta el lecho nupcial. El esposo invita a su cónyuge a recostarse, quitándole la palla y le desata el cinturón de lana de doble nudo (nodus herculeus) de su cintura. Es el momento en que los invitados se retiran, dejando gozar a los recién casados de su privacidad nupcial⁽⁶⁷⁾.

Con el transcurso del tiempo, la *confarreatio* pierde importancia, quedando relegada por las otras formas de contraer *matrimonium cum manu*. Cicerón, durante la República, sólo cita a la *coemptio* y el *usus*. Por su parte, Gayo señala que en su época se utiliza la *confarreatio* sólo para las ocasiones muy excepcionales⁽⁶⁸⁾.

1.2. La *coemptio*

Consiste en la compra ficticia de la mujer por parte del marido. El acto se lleva a cabo mediante la *mancipatio*, participando en él las personas requeridas a tal efecto; es decir, los cinco testigos y el *libripens*, todos ciudadanos púberes. La compra se realiza pesando en una balanza un pedazo de cobre que luego el esposo entrega al padre de la novia como forma simbólica de pago por la potestad de la mujer⁽⁶⁹⁾. Esta venta imaginaria requiere también la presencia del marido y del *pater* bajo cuya potestad se encuentra la novia. Para el caso de que esta última revista la calidad de *sui iuris*, hace falta el consentimiento de su tutor (*auctoritas*)⁽⁷⁰⁾. La *coemptio* reemplaza prácticamente a la *confarreatio*, constituyéndose en el modo normal de adquisición de la *manus* de la mujer durante el período Clásico, hasta que también con el paso del tiempo cae en desuso⁽⁷¹⁾.

1.3. El *usus*

Es uno de los modos más antiguos de contraer matrimonio *cum manu*, junto con la *confarreatio*, dado que se encuentra referencia a él en la ley de las XII Tablas⁽⁷²⁾. Consiste en la adquisición de la *manus* sobre la mujer mediante el simple e ininterrumpido transcurso del tiempo. El marido adquiere la posesión de la mujer mediante la convivencia mutua en la casa del primero, o de *supater* familias durante un año en forma continua, y sujeta bajo la potestas de aquel que la ejerza. Este modo de contraer *matrimonium cum manu* tiene fundamento en la adquisición de la propiedad sobre las cosas muebles (*usucapio*), para lo cual se asimila en este caso a la mujer.

Ahora bien, si ambos contrayentes, o sus respectivos *pater familias*, no desean que se concrete la adquisición de la *manus* sobre la mujer, basta simplemente con que la mujer interrumpa la posesión de su esposo pernoctando fuera del hogar conyugal durante tres noches antes del transcurso del año (*trinoctium*). Con ello, el plazo de posesión se corta y se comienza a contar nuevamente. Y, de ser necesario, antes de su vencimiento se debe efectuar otra vez el *trinoctium*. Ello, sucesivamente, todas las veces que se considere conveniente⁽⁷³⁾. Este acto trascendental (*trinoctium*) se realiza con la pomposidad necesaria para que cumpla el efecto de darle publicidad ante la falta de registros adecuados. Por lo general, basta con que la esposa se retire acompañada de testigos. Y la pernoctación de las tres noches fuera del domicilio conyugal se lleva a cabo en el correspondiente al *pater familias* originario de la esposa, demostrando así la potestad que continúa teniendo sobre ella. Por fin, debo destacar que el *usus* pierde importancia con el transcurso del tiempo, especialmente cuando el matrimonio comienza a gestarse sin el efecto *cum manu*, es decir, sin la adquisición de la *manus* sobre la mujer. Esto acontece en la época imperial, cuando lentamente cae en desuso.

VIII. LOS PRINCIPALES EFECTOS DEL MATRIMONIO CUM MANU

Implica la adquisición de la manus sobre la mujer, saliendo entonces ésta de su familia de origen e ingresando a la familia del esposo, aunque conserva los lazos de consanguinidad con la primera. Como desde los comienzos de Roma hasta la influencia ejercida por el cristianismo el lazo de parentesco que produce efectos legales es el agnaticio, la adquisición de la manus sobre la mujer es primordial. Esto importa la sujeción de la mujer al poder del pater familias de su esposo. Se trata de una potestas que posee aquél sobre la mujer. A pesar de los poderes amplios y absolutos que derivan de aquélla, la manus sobre la mujer tiene ciertas atenuaciones. Así, no se puede ejercer sobre ella el "derecho de vida y de muerte" (*ius vitae et necis*), tampoco el "derecho a venderla" (*ius vendendi*), ni el "derecho a entregarla como parte de pago" (*ius noxae dandi*). Solamente se ejerce sobre ella un derecho correccional, pudiendo castigarla con el consentimiento de un consejo integrado por los parientes más próximos.

La adquisición de la manus también ocasiona otros efectos, tales como, para el caso de que el pater familias sea al mismo tiempo el esposo, que se adquiera la manus sobre la mujer; en cambio, si el esposo es un *filius* (*aliena iuris*), la adquiere el padre de éste, o sea, el pater familias de quien depende el grupo familiar. En el primer supuesto, la mujer ingresa bajo la potestad del marido, revistiendo calidad jurídica similar a la de una hija (*filiae loco*) y pasa a ser hermana de sus hijos (*agnada*). Este ingreso importa efectos análogos a los de la adopción. Y para el supuesto de que la mujer tenga el carácter de *sui iuris*, al de la adrogación. Por su parte, en el segundo caso, la mujer reviste la calidad de nieta (*neptis loco*) del pater de su nueva familia. Y así sucesivamente (v.gr., si contrae matrimonio con un nieto, adquiere la calidad de bisnieta, etc.)⁽⁷⁴⁾.

Con esto puedo afirmar que la adquisición de la manus sobre la mujer importa para ella, no una equiparación con la posición de su esposo, sino una disminución de cabeza mínima (*capitis deminutio minima*). Pese a ello, resulta necesario aclarar que la esposa goza de los privilegios del "honor matrimonial" (*honor matrimonii*), por el cual adquiere el rango familiar de *mater familias*. Posteriormente, esta designación alcanza a toda mujer *sui iuris*⁽⁷⁵⁾.

Además, si la mujer es *sui iuris*, cuando el esposo adquiere su manus, también obtiene la transmisión de todos los bienes de la mujer, incluidos los créditos. Esto no abarca, claro está, las deudas o derechos contraídos a favor de terceros, quienes se ven defraudados al no poder cobrar sus créditos. Como esto último genera verdaderas situaciones injustas, con posterioridad se autoriza expresamente a los terceros para que puedan ejecutar sus derechos sobre los bienes de la mujer adquiridos por el marido⁽⁷⁶⁾.

IX. EL MATRIMONIO SINE MANU Y SUS EFECTOS

Concertado el matrimonio *sine manu*, su efecto primordial consiste en la no adquisición de la manus sobre la mujer, ya sea que el marido revista la calidad de *sui iuris* o de *aliena iuris*, conservándola el "jefe de familias" de ésta, con lo cual la mujer continúa bajo su dependencia jurídica, aunque conviva con su esposo.

X. LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO RESPECTO DE LOS CÓNYUGES Y DE LOS HIJOS

El matrimonio produce importantes consecuencias jurídicas respecto de los cónyuges y de los hijos por ser una institución sobre la que se apunala la familia. Se los conoce también como efectos

de carácter personal por las consecuencias que se derivan de él respecto de los cónyuges entre sí, y de cada uno de ellos respecto de los hijos.

a) Efectos del matrimonio respecto de los cónyuges. El principal efecto se produce cuando media la adquisición de la manus sobre la mujer por parte del esposo o el pater de éste, produciendo la sumisión de aquélla a éstos. Pero además, como consecuencia del matrimonio, el marido tiene derecho de ejercitar la llamada "acción de injurias" (actio iniuriarum). Ésta tiene lugar cuando se ofende a la mujer y su esposo reclama la reparación del daño ocasionado. El marido también goza del ejercicio del "interdicto de exhibición de la esposa" (interdictum de uxore exhibenda et ducenda) contra cualquier persona que se apodere ilegítimamente de su cónyuge, aun contra el pater de la mujer si se extralimita en el ejercicio de la patria potestas. En cuanto a esto último, la cuestión admite mayor complejidad cuando es el propio pater de la mujer, que muchas veces, de manera arbitraria, interpone el mencionado interdicto. Entonces, la jurisprudencia romana le otorga al marido el ejercicio de una "excepción" (exceptio) contra el "interdicto" del pater⁽⁷⁷⁾. El esposo tiene mayor autoridad que la mujer, y por ende puede aplicarle sanciones disciplinarias, aunque de modo mesurado. Para la aplicación de algún castigo tiene que consultar previamente la opinión de un conciliábulo familiar integrado por los parientes más próximos. La mujer adquiere el rango social que tiene su esposo y habita con él en el domicilio conyugal. Se castiga severamente el adulterio de la mujer, luego se extiende el castigo al esposo adúltero⁽⁷⁸⁾. No se admite entre cónyuges el ejercicio de acciones recíprocas, especialmente de carácter penal e infamantes⁽⁷⁹⁾. Ambos esposos pueden exigirse mutuamente alimentos⁽⁸⁰⁾ y tienen derecho a la sucesión hereditaria.

b) Efectos del matrimonio respecto de los hijos. El efecto primordial para los hijos habidos en el matrimonio es la filiación. Cuando el matrimonio es mediante "justas nupcias" (iustae nuptiae), la filiación es legítima, originando para el padre y para los hijos deberes y obligaciones recíprocas. Es conveniente aclarar que en los primeros tiempos de Roma, y debido al gran poder que posee el pater familias sobre los integrantes de su familia, estos deberes y obligaciones son incipientes, se encuentran casi desdibujados, dado que fundamentalmente éstos son del hijo para con el padre. Posteriormente, la situación lentamente cambia y, ante la paulatina moderación de los poderes del pater, comienza a delinearse la idea de que también los deberes y obligaciones están a cargo del padre para con sus hijos. De tal modo se genera el principio moderno de la patria potestad. Así, los padres o ascendientes tienen la obligación de prestar alimentos a los hijos y éstos a aquéllos en casos de indigencia⁽⁸¹⁾. Los hijos tienen también el deber moral de respetar y honrar a sus padres, lo que incluye la prohibición de demandarlos, salvo que mediara autorización judicial al respecto, y de no iniciarles acciones que les acarreen la "tacha de infamia"⁽⁸²⁾. Los hijos tienen el derecho de tomar el nombre, el domicilio y la ciudad de donde el padre es oriundo, como así también su condición social⁽⁸³⁾. En materia sucesoria, la filiación habilita jurídicamente a los hijos para heredar a sus padres en la sucesión ab intestato. Para los casos en que el pater deje testamento, sus poderes irrestrictos con el tiempo se limitan, con el fin de contemplar debidamente los derechos de los hijos de percibir su porción hereditaria, pese a lo dispuesto en el testamento en contrario (legítima).

XI. LOS EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO⁽⁸⁴⁾

El matrimonio en Roma produce importantes efectos de carácter patrimonial, debido a los aportes que realizan los cónyuges, incluso de terceros. En las épocas primitivas, dado el gran poder ejercido por el marido, y ante la ausencia del sentido moderno de bienes "conyugales" y "gananciales", el esposo dispone y administra a su antojo todos los bienes del matrimonio, ya sean originarios de la mujer o generados a posteriori. Con el avance del tiempo, la cuestión se va modificando, asemejándose al sistema actual. En primer lugar, si el matrimonio es celebrado cum manu, la mujer carece por completo de bienes propios, ya que todos, cualquiera sea su origen, son propiedad del esposo. Si éste fallece, la esposa en calidad jurídica de hija, accede a la herencia a la par de sus hijos (vínculo agnático). Por el contrario, si el matrimonio es concertado sine manu, los bienes entregados en calidad de dote continúan siendo propiedad de la mujer, y su esposo sólo puede administrarlos. Incluso, falleciendo el pater de la mujer, esta última hereda, convirtiéndose en propietaria exclusiva de los "bienes dotedales", coexistiendo dentro del matrimonio dos clases de bienes: por un lado, aquellos pertenecientes al esposo y, por otro, los de propiedad de la esposa⁽⁸⁵⁾.

XII. LA DOTE

La dote, conocida en Roma como dos y también como res uxoriae, consiste en el conjunto de bienes entregados al marido por la mujer, u otras personas en su nombre, destinados a solventar las cargas derivadas de la vida matrimonial⁽⁸⁶⁾. Las fuentes coinciden en afirmar que la dote se conoce desde los mismos orígenes de la ciudad-estado, siendo de gran importancia para la celebración de las nupcias de la mujer, dado que es un motivo de honor y distinción social dotar a una hija. Prueba de ello es la obligación de la clientela de proveer a la dote de las hijas del pater familias. Su origen probablemente se encuentra vinculado al matrimonio cum manu, puesto que la dote nace como una compensación por la pérdida de los derechos hereditarios de la mujer al pasar a pertenecer a la familia de su esposo. Lo que significa, en otras palabras, una especie de adelanto de herencia.

1. Las distintas clases de dote

Son las siguientes:

Dote necesaria. Es la constituida por la propia mujer, su padre, un ascendiente paterno y, excepcionalmente, cuando corresponda, por la madre. Se llama necesaria por cuanto emana de la ley la imposición de constituir la dote por parte de estas personas⁽⁸⁷⁾.

Dote voluntaria. Es la otorgada por cualquier persona que no esté obligada a hacerlo por ley.

Dote profecticia. Es la constituida por el padre o ascendiente paterno de la mujer⁽⁸⁸⁾.

Dote adventicia. Es aportada por cualquier otra persona que no sea el padre o ascendiente paterno de la mujer⁽⁸⁹⁾.

Dote estimada. Es aquella que, al ser entregada, es estimada (aestimata) en cuanto a su valor. La calidad de este tipo de dote, es decir, su valoración, se encuentra vinculada al problema de su restitución.

Dote recepticia. Es la dote cuya devolución se pacta en el momento de su entrega para el caso de la disolución del matrimonio⁽⁹⁰⁾.

XIII. LA CONSTITUCIÓN DE LA DOTE

Implica todo acto de la mujer, o de su familia, que ocasione el aumento del activo patrimonial del marido con motivo del matrimonio. Existen dos modos perfectamente diferenciados de constitución: uno denominado real y otro obligacional.

a) Modo real de constitución de la dote. Consiste en la entrega directa de los bienes que integran la dote. No es una promesa, sino el acto material de traspaso de los bienes al patrimonio del marido. Se la llama dotis datio. Se emplea para su constitución todo aquel medio jurídico que provoque la entrega efectiva de los bienes, por ejemplo, mancipatio, in iure cesio, traditio, "cesión de créditos", "remisión de deudas", "renuncias de herencias", "legados", "servidumbres", etc.⁽⁹¹⁾.

b) Modo obligacional de constitución de la dote. Existen dos modos de "obligarse" para la constitución de la dote, uno llamado dotis dictio y el otro, dotis promissio. El primero es la promesa asumida por la propia mujer cuando es sui iuris, o por quien tenga su potestad, y aun también por los deudores de la mujer, siempre que actúen con su mandato. El segundo consiste en la promesa de constituir dote que puede asumir cualquier persona que quiera beneficiar a la mujer. Se lleva a cabo bajo la figura jurídica de la "estipulación" (stipulatio)⁽⁹²⁾. En los primeros tiempos, y luego durante la época clásica, no existe otro medio de obligarse para la constitución de la dote que la dotis dictio y la dotis promissio. La promesa simple de dote (pollicitatio dotis) no causa obligación alguna. Luego, en el derecho posclásico, Teodosio II le otorga plena validez obligacional, despojando a la constitución de la dote de todo requerimiento formal⁽⁹³⁾. Finalmente, Justiniano admite la "constitución tácita de la dote". Esto es así, porque considera que si la mujer se divorcia y

no exige la restitución de la dote, de contraer nuevo matrimonio con su antiguo esposo, constituye nuevamente dote a su favor⁽⁹⁴⁾. La evolución en la liberalización de las formas de constitución de la dote finaliza tras la divulgación de la escritura, pudiendo realizarse por escrito y sin mayores formalidades. Este modo se denomina "instrumento dotal" (instrumentum dotale).

1. La administración de la dote

La constitución de la dote le otorga al esposo la propiedad sobre ella,⁽⁹⁵⁾ como tal, puede disponer de ella por actos entre vivos a título oneroso o gratuito y por disposición de última voluntad; además, puede adquirir todos los accesorios y los frutos que originen los bienes que la integran⁽⁹⁶⁾. El marido se convierte en el verdadero propietario de la dote, prescindiendo de los derechos que la mujer tiene sobre ella. Esto ocasiona abusos, por cuanto la ilimitada disponibilidad de los bienes dotales por parte del marido torna vana la posibilidad de su restitución en caso de que el matrimonio se disuelva. Por tal motivo, lentamente la jurisprudencia romana comienza a paliar esta injusta situación, limitando los poderes de disposición que posee el marido sobre los bienes dotales en salvaguarda de la mujer y de los hijos del matrimonio⁽⁹⁷⁾.

2. La restitución de la dote

Siendo el derecho romano eminentemente pragmático, comienza a perfilarse cada vez más en el trato cotidiano la idea de proteger la restitución de la dote. Se sabe que la legislación romana, en cualquier de sus manifestaciones, surge primordialmente ante la necesidad de brindar soluciones a casos concretos que se presentan en la vida diaria. Por dicho motivo, en los tiempos antiguos, disuelto el matrimonio, la dote por lo general vuelve a la familia de origen, posibilitando así que la mujer pueda volver a casarse. Las situaciones que se presentan al respecto se solucionan con cordura, v.gr., testamento, restitución directa, etc. Pero con el cambio de las costumbres y la proliferación de los divorcios, se pierde este modo pacífico y amigable de restituir los bienes dotales, generándose el hábito de permanecer el marido con su propiedad pese a la disolución del vínculo. De este modo se hace imperiosa la necesidad de que la jurisprudencia origine, a través de acciones y garantías, medios de protección que avalen la restitución de la dote a la mujer.

Una primera manifestación de ello es la denominada actio rei uxoriae, originada por la actividad de los pretores, aplicándose en caso de disolución por causa de divorcio en favor de aquel que constituye la dote, aunque luego se extiende a aquellos supuestos de disolución por causa de muerte⁽⁹⁸⁾. Con la protección pretoriana de la dote, que permite su restitución en los supuestos de disolución del matrimonio, cambia fundamentalmente la cuestión. Previamente a la creación de esta acción, el marido es el verdadero propietario de los bienes que componen la dote; luego, sólo tiene el usufructo de la dote mientras se mantenga vigente el vínculo matrimonial, dado que debe restituirla una vez disuelto este último. Así y todo, la restitución de la dote por parte del marido no es íntegra, sino que se lo autoriza legalmente a efectuar retenciones por distintas causas contempladas por la jurisprudencia, v.gr., gastos ocasionados para mantener los bienes, adulterio de la mujer, etc.; contemplando incluso los porcentajes de retención que corresponden, así, la quinta, sexta u octava parte. Además, la restitución no es inmediata, sino en cuotas que varían en cada supuesto, por ejemplo, tres cuotas anuales, seis cuotas mensuales, etc.⁽⁹⁹⁾.

En igual sentido, por disposición de la lex Iulia de adulteriis (18 a.C.), la mujer debe prestar su consentimiento para que el marido venda los fundos itálicos que forman parte de la dote. También la misma ley dispone que los mencionados inmuebles no pueden ser gravados con prenda, aun en el caso de que exista consentimiento de la esposa⁽¹⁰⁰⁾. Posteriormente, Justiniano extiende los efectos de esta ley a los fundos provinciales. Finalmente, la actio rei uxoriae cae en desuso y en la época de Justiniano es abolida definitivamente (constitución del 1º de noviembre del año 530).

Otro modo de restitución de la dote se realiza a través de la "acción de dote" (actio dotis). Esta última puede ser ejercida por la propia mujer o sus herederos, si fuera el caso. El fin inmediato es la

restitución de la dote una vez disuelto el vínculo, fundándose en que forma parte de la propia naturaleza jurídica de la dote por su característica obligacional. Es decir, la misma obligatoriedad en la constitución de la dote la torna luego exigible ante la disolución del vínculo. La evolución de la jurisprudencia clásica culmina con la constitución de la dote por estipulación⁽¹⁰¹⁾. Justiniano, con la finalidad de garantizar aún más la restitución de la dote a la esposa, ordena que se graven los bienes propios del marido mediante una hipoteca general con privilegio sobre otras constituidas con anterioridad. También suprime las retenciones en favor del marido y ordena que la devolución sea inmediata, cuando se trate de bienes inmuebles, y en el plazo de un año, en el de los muebles⁽¹⁰²⁾. Mediante estas disposiciones, la institución de la dote termina por configurarse en cuanto a su consentimiento jurídico y su modo de aplicación, culminando la larga evolución iniciada por el pretor y los jurisconsultos clásicos.

XIV. LA CUESTIÓN DE LOS BIENES PROPIOS DE LA MUJER (PARAFERNALES)

La jurisprudencia romana pronto advierte la existencia de una calidad de bienes que no forma parte de la dote y que se mantiene excluida de ella. Son verdaderos bienes propios de la mujer, no aportados al matrimonio en calidad de bienes dotales, y reciben la denominación de parafernales. Esta denominación proviene de las fuentes, precisamente de un pasaje del célebre jurisconsulto Ulpiano, que adopta la expresión griega parapherna y la traduce como "bienes dados fuera de la dote"⁽¹⁰³⁾. Estos bienes que pertenecen a la mujer son aportados al matrimonio por ésta, pero no en calidad de dote. Consisten en bienes de la más variada índole, como vestuario, joyas personales, vajilla, etc.; luego se añaden créditos e inmuebles. El esposo sólo los administra y, por lo tanto, los usufructa en beneficio del matrimonio, respondiendo por su desaparición injustificada⁽¹⁰⁴⁾. Disuelto el matrimonio, los bienes parafernales deben ser devueltos a la mujer, legislando la jurisprudencia romana los distintos supuestos que se pueden presentar al respecto⁽¹⁰⁵⁾.

XV. LA DONACIÓN ENTRE CÓNYUGES

La donación entre esposos (donationes inter virum et uxorem) consiste en regalos o liberalidades que se efectúan los esposos entre sí, o uno de ellos al otro. La diferencia con la dote estriba en que esta última es un aporte que realiza la mujer o su familia para contribuir a la subsistencia del matrimonio, siendo constituida con anterioridad o en modo contemporáneo a su celebración, mientras que la donación entre cónyuges se produce durante la vigencia del vínculo matrimonial.

También debe distinguirse la donación entre cónyuges de aquella que llevan a cabo los futuros novios cuando celebran los esponsales (donatio propter nuptias), pues ellas están regidas por una legislación diferente⁽¹⁰⁶⁾.

En un principio, las liberalidades entre cónyuges son aceptadas, pero después comienza a imperar el criterio de que éstas son nulas. Igualmente, la jurisprudencia romana indica prolijas excepciones que convalidan las donaciones otorgadas entre esposos; así, donación de la tumba, donación de la mujer al marido para que éste alcance honores o distinciones, donaciones efectuadas entre el emperador y su esposa, etc., aunque el criterio general sostiene su invalidez⁽¹⁰⁷⁾.

XVI. LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO⁽¹⁰⁸⁾

El matrimonio en Roma se disuelve por distintas causas, que pueden agruparse según medie o no la voluntad de los contrayentes al respecto. Entonces, la disolución puede darse por razones ajenas a la intención de los contrayentes y, por el contrario, por voluntad de los esposos⁽¹⁰⁹⁾.

1. Disolución del matrimonio por razones ajenas a la intención de los contrayentes

Tenemos los siguientes supuestos, a saber: 1) muerte de uno de los cónyuges; 2) padecimiento de "disminución máxima de cabeza" de alguno de los esposos (*capitis deminutio máxima*); 3) padecimiento de "disminución media de cabeza" de cualquiera de los esposos (*capitis deminutio media*); 4) surgimiento de un impedimento.

1.1. Muerte de uno de los cónyuges

Se la considera como la disolución natural del matrimonio. La muerte de uno de los esposos disuelve de inmediato el vínculo, autorizando el nuevo casamiento del esposo sobreviviente, aunque esto último se da para el varón, puesto que la mujer debe aguardar como mínimo diez meses para contraer nuevas nupcias, con la finalidad de evitar la incertidumbre sobre la filiación de la prole. Ello concuerda plenamente con la presunción derivada de la legislación romana, que considera concebido en el matrimonio al hijo que nace dentro de los trescientos días siguientes a su disolución⁽¹¹⁰⁾.

1.2. Padecimiento de alguno de los cónyuges de "disminución de cabeza máxima" (*capitis deminutio maxima*)

El supuesto implica la pérdida del "estado de libertad" (*status libertatis*) de una persona, que se configura cuando cae en esclavitud. La circunstancia de que uno de los esposos pierda su libertad provoca la ruptura del equilibrio social que debe tener el matrimonio, tornándolo impracticable, con lo que el vínculo entonces se disuelve.

Especial tratamiento merece el caso en que un ciudadano romano, soldado o no, cae en poder del enemigo, es decir, detrás de los límites romanos (*postliminium*). Esta situación evidencia matices peculiares que evolucionan con el transcurso del tiempo. En el período clásico se considera que el matrimonio no puede continuar y se autoriza el nuevo casamiento del consorte en libertad. Si el cautivo regresa en algún momento, el vínculo no se restablece. Es decir que si su esposa contrae nuevas nupcias, éstas deben ser mantenidas, si es el deseo de la mujer. Ahora bien, si ambos tienen la intención de restablecer el primer matrimonio, la esposa debe disolver el segundo y volver a celebrar nupcias con su primer esposo. Aun en el caso de que la esposa no se haya casado nuevamente, igualmente ambos deben contraer nuevas nupcias, puesto que las primeras se disuelven con la caída en cautiverio. Posteriormente, la legislación justiniana establece que el cónyuge en libertad no puede casarse nuevamente si existen noticias de que estuviese vivo el cautivo, y debe aguardar cinco años para contraer nuevas nupcias, contados desde el momento en que se produce la caída en cautiverio⁽¹¹¹⁾. Distinta es la situación que se presenta si ambos esposos caen en cautiverio continuando la cohabitación, puesto que el matrimonio subsiste en caso de regresar juntos⁽¹¹²⁾.

1.3. Padecimiento de alguno de los cónyuges de "disminución de cabeza media" (*capitis deminutio media*)

Implica la pérdida del "estado de ciudadanía" (status civitatis) y conlleva los derechos y atributos que posee el ciudadano romano, entre ellos el matrimonio.

1.4. Impedimento posterior

Se refiere a casos puntuales en que surge un impedimento posterior a la celebración del matrimonio. Estas situaciones, de producirse, son excepcionales y motivadas generalmente en razón de la adopción. Las fuentes citan el caso de "incesto sobreviviente" (incestus superviniens), originado cuando el suegro adopta al yerno sin antes emancipar a la esposa de éste (hija del primero), porque entonces serán considerados jurídicamente hermanos⁽¹¹³⁾.

2. Disolución del matrimonio por voluntad de los esposos

Consistiendo el matrimonio romano en una situación fáctica evidenciada en la convivencia mutua con la intención de ser marido y mujer, no puede ser otro modo que la falta o cambio del aspecto volitivo lo que autoriza, sin más, al divorcio.

La disolución del matrimonio por voluntad de uno de los esposos, o de ambos, se conoce en Roma desde sus inicios, prácticamente en la raíz del mismo acto del matrimonio. Dicho de otro modo, si sólo basta la voluntad de considerarse esposos y vivir juntos como tales para considerar que existe el matrimonio, nada obstaculiza para que, de ser necesario, su disolución se pueda dar a través del mismo consentimiento⁽¹¹⁴⁾. Lo que acontece es que, por la rudeza de las primitivas costumbres sociales romanas, se impone como rareza el divorcio por simple consentimiento, apelándose a él en casos muy especiales.

Luego, durante el final de la República y el comienzo del Principado, el modo de divorciarse por medio de la voluntad se populariza debido quizá a un relajamiento de las costumbres. Cosa del todo incierta, puesto que si el simple consentimiento da comienzo al matrimonio, su falta se supone suficiente para ponerle fin. El fundamento en el "relajamiento de las costumbres" es superado por la idea humanística del matrimonio romano, producto precisamente del período clásico. Es necesario estudiar el tema con los sentidos puestos históricamente en Roma, en la libertad de pensamiento y vida que les hace superar todo tipo de situaciones y discriminaciones. Tampoco se puede soslayar el pensamiento cristiano sobre el tema, dado que, al considerar al matrimonio como un sacramento, declara indisoluble el vínculo. De aquí el esfuerzo de los emperadores cristianos para limitar de algún modo la libertad imperante en su disolución. Lo cierto es que el efecto querido, en principio, se consigue lentamente ante la gran resistencia al cambio de concepción jurídica sobre el tema; nada menos que pasar de la libertad de ánimo a un sistema de indisolubilidad del vínculo. Luego, el pensamiento de la iglesia cristiana se impone y en muchas legislaciones modernas no se permitió el divorcio, sino la simple separación con subsistencia del ligamen. La moderna tendencia indica la casi inexistencia de legislaciones que sostengan actualmente la imposibilidad de disolver el matrimonio. Con esto quiero explicitar, sin entrar en consideraciones religiosas que pertenecen respetuosamente al ánimo de cada individuo, que el sistema libre de la disolución del vínculo matrimonial romano ha vuelto a renacer en la actualidad. Destaco igualmente que la libertad de disolución del matrimonio también provoca excesos que a la postre llevan a pensar en el relajamiento de las costumbres. Señalo al respecto que siempre han mediado excesos en la vida del hombre, aun hoy, pero ello no debe hacer pensar que determinada institución es nociva, sino buscar su perfeccionamiento o mejor desarrollo.

En el derecho justinianeo se brindan pautas más precisas en cuanto a la regulación del divorcio y sus causales⁽¹¹⁶⁾. Se distinguen dos formas: a) el divorcio por mutuo consentimiento; b) el divorcio unilateral.

Resulta necesario aclarar que la acepción "divorcio" (divortium) se reserva para los casos de mutuo consentimiento entre las partes, sin existencia de causales; y el término "repudio" (repudium) cuando se trata del divorcio unilateral con causales justificadas.

1. El divorcio por mutuo consentimiento (divortium)

Es aquel que se produce mediante el consentimiento de ambos esposos y en ausencia de causales imputables a alguno de éstos. Justiniano, siguiendo la idea restrictiva imperante en su época, legisla la prohibición de este tipo de divorcio fundándose en que siempre el consentimiento disolutorio debe estar cimentado en una causa. Con el fin de darle mayor fuerza a su decisión, ordena que aquellos esposos que vulneren la prohibición merecen un castigo, consistente en la internación en un convento y la pérdida de todos sus bienes, los cuales deben traspasarse a sus descendientes y, a falta de éstos, al monasterio elegido para su internación⁽¹¹⁷⁾. Esta decisión es sumamente resistida, y Justino II, sucesor de Justiniano, la deja sin efecto, restableciendo nuevamente la libertad de divorciarse por simple y mutua libertad⁽¹¹⁸⁾.

2. El divorcio unilateral (repudium)

Consiste en disolver el vínculo por pedido de uno de los consortes cuando media causa para ello. Estas causales deben ser estudiadas desde el punto de vista del esposo, la esposa y de ambos.

El marido puede fundar el pedido de divorcio, entre otras, en las siguientes causales: adulterio cometido por la esposa; concurrencia de la esposa a acontecimientos y lugares públicos acompañada de extraños sin la aprobación del esposo (v.gr., banquetes, baños públicos, espectáculos públicos, etc.); conversación mantenida por la esposa con desconocidos fuera del hogar.

La esposa, por su parte, puede solicitar el divorcio cuando el marido la acusa falsamente de adulterio, si el marido tiene la intención de inducirla a la prostitución y si el esposo tiene una concubina en el mismo hogar.

Son causales comunes a ambos esposos las injurias graves, los crímenes de falsedad, el delito de traición, el atentado contra la vida del otro cónyuge, las sevicias⁽¹¹⁹⁾.

Ahora bien, el cónyuge culpable es castigado con la pérdida de un tercio de sus bienes, la dote y las donaciones nupciales.

Adviértase que algunas de las causales han pasado a las legislaciones actuales y otras se han perdido en el tiempo, devoradas por el cambio de costumbres, o se han actualizado a las necesidades modernas. Lo importante es vislumbrar la existencia de causas graves que no permitan la vida en común, autorizando tal extremo a la disolubilidad del vínculo y la facultad de contraer nuevas nupcias, si así lo consideran, en el momento oportuno. Las distintas causales son producto del momento de la vigencia de cada legislación. La madurez del pensamiento romano permite ensamblar la cohabitación de distintas formas de pensar y vivir. En época de Justiniano, aquel que cree en la indisolubilidad del matrimonio puede vivirlo y disfrutarlo sin ningún impedimento; y, por el contrario, aquellos que padecen la pérdida de la affectio maritales tienen la solución que les brinda la ley. Pero como se desea evitar abusos, sólo se permite la disolución ante un motivo claro, concreto, y no por mero esnobismo o moda, que es lo que puede suceder en los casos del divorcio sin motivo alguno.

XVIII. EFECTOS DERIVADOS DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

La disolución del matrimonio apareja efectos que deben ser considerados respecto de los esposos, los hijos y los bienes.

a) Los esposos. La disolución del matrimonio faculta a ambos esposos a contraer nuevas y legítimas nupcias, aunque la mujer debe esperar un año para hacerlo.

b) Los hijos. Con respecto a los hijos, hay que discernir si la disolución se produce por muerte, capitis diminutio o divorcio de los esposos. En el caso de muerte o capitis diminutio máxima o media del esposo, los hijos revisten la categoría jurídica de sui iuris, es decir, se erigen en "jefes de su propia familia". Si la que muere o padece la capitis diminutio es la esposa, los hijos continúan bajo la potestad del esposo. Si la disolución del vínculo se produce por divorcio, los hijos deben permanecer con la madre por disposición de la legislación justinianeana y el padre tiene la obligación de alimentarlos, salvo que por razones económicas no pueda hacerlo⁽¹²⁰⁾.

c) Los bienes. Las consecuencias respecto de los bienes matrimoniales ya se han tratado oportunamente.

XIX. LOS ALIMENTOS EN EL DERECHO ROMANO Y SU INFLUENCIA EN NUESTRA LEGISLACIÓN⁽¹²¹⁾

La problemática de los alimentos hace pensar en un tema actual, pero también es cierto que esta institución nace en el derecho romano, y es fruto de su observación en las relaciones familiares cotidianas. Su preocupación al respecto es intensa, puesto que no solamente abarca el aspecto de fondo, sino también el procesal. Como corolario de esta introducción, diré que el derecho romano agota prácticamente la legislación sobre alimentos, arribando a soluciones que hoy en día se encuentran transcritas en la jurisprudencia, de tal modo que si se leen ambas sin prestar atención cuál es cuál, se encuentra identidad entre ellas, como si el tiempo no hubiera transcurrido o, mejor dicho, hablando con absoluta propiedad técnica, se observa que el derecho romano avanza tanto sobre el tema que aun hoy, después de dos milenios, no es superado.

El derecho romano dispone la obligación de pasar alimentos a los padres respecto de sus hijos y, en su caso, de estos últimos a los progenitores⁽¹²²⁾. El derecho a los alimentos alcanza incluso a los parientes maternos, como la madre y la hermana⁽¹²³⁾. También se faculta a la madre a pedir alimentos por el hijo concebido en su vientre⁽¹²⁴⁾, aun en el caso de que existan dudas sobre la paternidad, siendo más importante el derecho a ser alimentado que la legitimidad en cuestión⁽¹²⁵⁾.

Se dictan normas claras a los tutores para que en el cumplimiento de la tutela presten especial atención a la alimentación de los pupilos⁽¹²⁶⁾.

Se regula que la alimentación comprende no sólo comida, sino también bebida, vestido y habitación. Y que los alimentos deben guardar proporción a la riqueza y poder adquisitivo del alimentante, con el fin de que el alimentado reciba la misma dignidad y situación social que aquél⁽¹²⁷⁾. Y más aún, la jurisprudencia romana entiende que el pago de los estudios y demás gastos también es motivo de alimentos, siempre en proporción a los bienes y situación social del alimentante⁽¹²⁸⁾.

Además, se proporcionan recaudos procesales, puesto que se disponen medidas de ejecución para las sentencias de alimentos, con el fin de asegurar su prestación efectiva⁽¹²⁹⁾. Finalmente, debe dejarse en claro la suma importancia que el derecho romano le presta a la institución de alimentos, dado que advierte que el procedimiento civil en un juicio por alimentos no puede llevar el mismo régimen procesal que cualquier otro pleito, fundamentalmente por el hecho de que un problema de alimentos requiere una solución judicial inmediata o, al menos, lo más rápido posible, ya que, de lo contrario, el principio primordial del derecho alimentario se ve conculcado. El alimento es necesario prestarlo en modo súbito porque si no fuera así el alimentado puede sufrir calamidades, incluso la muerte. Por tal motivo, en el llamado "proceso formulario", el magistrado, generalmente representado por el pretor, posee las denominadas "facultades extraordinarias", por las cuales decide la cuestión él mismo, evitando una de las etapas del procedimiento general a efectos de acelerar la tramitación del alimento. Con el paso del tiempo, la simplificación procesal empleada en los juicios alimentarios inspira a Diocleciano (año 284) a reformar el procedimiento civil, dando paso